

제7절 그 밖의 재산권에 대한 압류

I. 서설

우리 민사집행법 제251조는 부동산을 목적으로 하지 아니하고 유체동산, 금전채권, 유체물의 인도 또는 권리이전을 목적으로 하는 청구권 이외의 재산권에 대한 강제집행에 관하여서는 민사집행법 제4절 제3관(채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행)의 규정 및 제98조 내지 제101조의 규정을 준용하도록 규정하고 있는바, 이와 같이 부동산집행의 대상이 되지 아니하는 재산 중 유체동산과 채권, 유체물청구권을 제외한 것을 널리 「그 밖의 재산권」이라고 통칭한다.

이러한 그 밖의 재산권은 경제생활과 법률생활의 진전에 따라 복잡화·세분화되는 경향을 가지고 있으며, 그 강제집행의 방법도 이에 따라 다양화될 수밖에 없어서 이를 모두 법정하기가 어렵다.

그래서 민사집행법 제251조는 그 밖의 재산권 집행에 대한 원칙으로서 각종 집행절차 가운데 가장 간이한 구성을 택한 채권집행의 예에 의하는 것으로 필요한 최소한의 개괄적 규정만을 두는 것에 그치고 그 대부분을 실무 운용에 맡겨두고 있다.

따라서 집행기관에 광범위한 재량권이 인정되기 때문에 개별적 구체적 집행절차를 운용함에 있어서는 그 대상인 재산권의 성질에 따라 개별적인 검토가 필요하게 된다.

II. 집행의 대상

1. 서

민사집행법 제251조에서 말하는 그 밖의 재산권이라 함은 부동산, 선박, 동산 및 채권 이외의 재산권을 말하는 것이고, 그 자체 독립하여 재산적 가치를 가지고 또한 그 현금화에 의하여 채권자의 만족에 공(供)할 수 있는 것, 즉 금전적 평가가 가능한 것이어야 한다.

따라서 위와 같은 요건을 갖춘 재산상의 권리인 한 그것이 조건부이거나 장래의 권리 내지 기대권이더라도 지장이 없고, 또한 그 재산권 자체의 현금화에 의하여 채

권자가 직접 만족을 얻을 수 있는 것임을 요하지 않는다.

2. 대상 여부가 문제되는 경우

가. 사실상의 이익 등

상인의 영업으로 인한 사실상의 이익·권능 등은 그 집행의 대상이 되지 않는다. 그리고 상속인이 될 수 있는 가능성과 같은 단순한 기대가능성⁵⁷¹⁾이나 재산적 가치가 없는 비영리법인의 사원권 및 순수한 신분상의 권리 등도 여기의 집행 대상이 될 수 없다.

나. 일신전속적 권리 등

권리에 재산적 가치가 있더라도 그 성질상 그 귀속 및 행사에 있어서 채무자의 일신에 전속되는 성명권, 초상권 등 인격권은 집행의 대상으로 되지 않는다. 또한 상호권은 일종의 재산권인데 그것이 자연인이 가지는 것이냐 법인이 가지는 것이냐를 묻지 않고 영업과 함께 하는 경우에 한하여 양도할 수 있으며(상법 제25조), 아래에서 보다시피营业을 압류할 수 없기 때문에 상호권만의 압류는 허용되지 않는다고 보는 것이 일반적이다.⁵⁷²⁾

다. 형성권, 영업 등

집행의 대상으로 될 수 있는 권리는 그 자체 독립하여 재산적 가치가 있는 것이어야 하므로 취소권·해제권·해약고지권·선택권 등의 형성권이나 재산관리권, 대리권이거나 저당권, 질권과 같은 담보물권 및 보증으로 인한 권리 등은 집행의 대상으로 되지 않는다.

다만 형성권 중 등기되어 있는 환매권(민법 제592조)은 독립한 재산권으로 볼 수 있으므로 위 집행의 대상이 된다. 또한 상인의 영업과 같이 여러 종류의 권리·이익을 포함하는 것은 - 그 내용인 개개의 재산에 관하여는 별도로 - 이를 전체의 포괄재산으로서는 강제집행의 대상으로 되지 않는다.

라. 광업권·어업권·댐 사용권 등

광업권, 어업권, 댐 사용권 등은 본래 그 밖의 재산권에 속하는 성질의 것이지만

571) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 659.

572) 홍광식, “각종 회원권·면허권 등 기타재산권에 대한 강제집행”, 민사집행에 관한 제문제(하), 재판자료 제72집, 법원행정처(96.06), 283-284.

법률이 이를 물권으로 보고 부동산(또는 토지)에 관한 규정을 준용하도록 하고 있기 때문에(광업법 제10조 제1항, 수산업법 제16조 제2항, 내수면어업법 제7조 제2항, 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제29조), 그 밖의 재산권에 대한 집행방법에 의할 것이 아니고 부동산집행의 방법에 따라야 한다.

마. 미등기의 입목

1) 입목에 관한 법률 제2조에 의하여 등기된 독립한 부동산으로 간주되는 입목은 지반인 토지와는 별도로 강제집행의 대상으로 되어 그 절차는 일반의 부동산집행의 예에 의해야 한다.

그러나 등기되지 않은 입목에 관하여는 그것은 토지의 구성부분에 지나지 않으므로 지반과 분리하여 독립으로 집행의 대상으로 될 수 있는가가 의문이고, 집행의 대상으로 될 수 있더라도 어떠한 집행절차에 의하여야 하는가가 또한 문제이다.

2) 현재 이에 관하여 등기되지 않은 입목에 대한 강제집행을 일체 부정하는 견해는 없어 보이고, 다만 그 강제집행의 방법에 대하여 종래부터 다음과 같이 견해가 나뉘어진다.

가) 유체동산집행설⁵⁷³⁾ : 이 설은 입목 그 자체를 동산으로 간주하여야 하는데, 입목의 권리변동의 요건인 명인방법이라는 것은 동산 권리변동의 대항요건인 인도와 같은 성질의 것이므로 그 강제집행도 유체동산집행에 의하는 것이 타당하다는 것이다.

나) 부동산집행설⁵⁷⁴⁾ : 이 견해는 입목이 지반과 독립하여 거래의 대상으로 되는 때에도 부동산으로서의 성질을 상실하는 것이 아니므로 이것에 대한 강제집행도 부동산집행에 의하여야 하는 것으로, 집행법원에서는 경매개시결정을 하고 등기소에의 등기의 촉탁에 대신하는 명인방법을 강구함으로써 그 절차를 지장없이 실시할 수 있다는 것이다.

다) 권리집행설⁵⁷⁵⁾ : 이 설은 이 경우 실제의 거래에서는 동산의 매매로서 관념되고 있더라도 법률상 동산 그 자체의 거래로 보는 것은 무리가 있으므로 오히려 「입목을 별채하여 동산으로 하는 권리」를 매매하고 있다고 보는 것이 합리적이라고 해석

573) 倉田卓次, “立木に對する假押留の執行”, 判例タイムズ 45号, 15.

574) 住吉君彦, “立木に對する金錢債權についての強制執行”, 金融法務事情 2号, 20.

575) 板倉松太郎, 強制執行法義海, 巖松堂(昭和5), 583.; 日最判 昭和 46(1971). 6. 24.(民集 25-4, 574)은 집행관의 위법집행을 원인으로 하는 국가배상사건에 있어서 立木을 목적으로 하는 강제집행은 집행관이 행한 유체동산에 대한 강제집행의 절차에 의하여야 하는 것이 아니고 집행재판소가 구 民事訴訟法 제625조에 기하여 입목을 별채하는 권리를 압류하여 이를 환가하는 방법에 의하여야 하는 것이라고 해석하는 것이 상당하다고 하여 권리집행설을 취하는 것을 명백히 하였다.

하며, 따라서 강제집행방법으로서도 이러한 실태에 비추어 입목별채권을 압류하여 이를 현금화하는 방법에 의하여야 하고, 그렇게 하는 것이 가장 간명하다는 것이다.

라) 소유자의 동일 여부에 의해 구별하는 설⁵⁷⁶⁾ : 이 설은 먼저 토지와 입목의 소유자가 다르나 입목의 소유자가 토지의 점유권원을 가지지 않은 경우에는 입목소유자는 토지소유자에 대하여 일종의 채권적 권리로서의 입목별채권을 가지는 것으로 볼 수 있으므로 이 별채권을 권리집행의 방법으로 압류·현금화해야 하는 것이지만, 토지의 소유자가 동시에 입목의 소유자인 경우에는 입목별채권과 같은 채권적 권리가 존재한다고 생각하기 어려우므로 입목 자체를 미분리의 과실과 동시(同視)하는 구 민사소송법 제568조를 유추하여 입목 자체에 대하여 유체동산집행절차에 의해야 하는 것으로 본다.

생각건대 민사집행법 제189조 제2항 제1호가 「등기할 수 없는 토지의 정착물」을 동산집행의 목적물로 하고 있는 점에 비추어 보면, 미등기입목에 대한 집행은 원칙적으로 동산집행의 방법에 의해야 하고, 관습법상 별채권의 존재가 인정되는 경우 등 예외적인 경우에 한하여 민사집행법 제251조에 의해 그 밖의 재산권으로서 압류할 수 있다고 봄이 타당하다고 본다.⁵⁷⁷⁾

바. 제3채무자의 작위를 목적으로 하는 청구권

채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 작위를 목적으로 하는 청구권은 그것이 독립한 권리인 이상 여기 집행의 대상이 된다. 예컨대, 도급계약 또는 물건의 제조, 가공계약에 기하여 채무자가 제3채무자에 대하여 갖는 물건의 제조, 가공 및 인도를 구하는 청구권, 발행되지 아니한 주권에 대하여 그 발행·교부를 구하는 청구권 등이 이에 해당한다.⁵⁷⁸⁾

그러나 채무자가 제3채무자에 대하여 부작위의 이행을 구할 수 있는 권리는 금전적 평가가 가능한 재산적 가치를 인정하기 어려우므로 집행의 대상이 되기 어렵다. 전기, 가스, 수도의 공급계약에 기초한 수요자의 권리 또한 같은 이유로 위 집행의 대상으로 되지 않는다.⁵⁷⁹⁾

576) 中野貞一郎, “未登記立木に對する強制執行の方法”, 判例問題研究強制執行法, 有斐閣, 109.

577) 다만 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 454.은 이를 그 밖의 재산권집행의 대상이 된다고 보고 있다.

578) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 661.

579) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 661.

사. 자동차중기선박 등의 공유지분 등

선박, 자동차, 건설기계, 소형선박(자동차 등 특정동산 저당법 제3조 제2호에 따른 소형선박을 말한다) 및 항공기의 공유지분에 대한 집행은 민사집행법 제185조, 민사집행규칙 제129조, 제130조, 제106조의 규정에 따라 모두 그 밖의 재산권에 대한 집행의 예에 따른다. 다만 부동산의 공유지분권에 대하여는 민사집행법 제139조 이하의 규정이 있으므로 위 집행방법의 대상이 아니다. 무체재산권의 공유지분에 관하여는 다른 공유자의 동의를 얻지 못하면 그 지분을 양도할 수 없는 것으로 하고 있으므로 그 공유지분이 집행대상으로 될 수 있는가에 관하여 소극적으로 보는 견해가 있기는 하나, 이러한 규정도 공유지분의 집행대상적격 그 자체까지 부정하는 것은 아니고 압류 후의 현금화절차에서 배려를 하면 족하다고 보이므로 이를 부정할 것은 아니라고 본다.⁵⁸⁰⁾

광업권 등의 공유지분에 대하여는 의문의 여지가 있으나, 부동산의 경우와 달리 공유지분등록이 불가능하므로 민사집행법 제139조의 방법에 의하기는 어렵고, 그 밖의 재산권에 대한 집행방법에 따른다.⁵⁸¹⁾ ⁵⁸²⁾

아. 그 밖의 권리

그 밖에 일반적으로 위 집행의 대상이 될 수 있는 재산권으로는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권⁵⁸³⁾ 등의 지적재산권, 양도가능한 전화의 전화사용권, 골프회원권·스포츠회원권·콘도회원권 등과 같은 설비의 이용을 목적으로 하는 재산권, 유체동산의 공유지분권, 합명회사·합자회사·유한회사의 사원권, 조합원의 지분권, 예탁증권, 전세권 등을 들 수 있다.

또한 백지어음보충권도 압류할 수 있다고 하며, 이사회의 결의로 주주가 취득한 구체적 신주인수권(상법 제416조, 제420조의2)은 추상적 신주인수권과는 달리 그 밖

580) 홍광식(주572), 290.

581) 대법원 1969. 6. 24. 선고 69다550 판결; 대법원 1969. 12. 23. 선고 68다1495 판결; 대법원 1970. 3. 10. 선고 69다2103 판결 【판결요지】광업권의 지분이전에 관한 등록을 할 수 있는 규정이 없는 만큼 그 지분양도의 경우에는 종전의 공동광업권자 전원으로부터 양도 후 공동광업권자가 될 전원에 대한 광업권 자체의 이전등록을 하여야 한다.

582) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 454.

583) 다만 저작권에는 저작자인격권이 포함되어 있는데, 그것은 저작자가 저작자인 자격에 기하여 인격적으로 가지는 이익에 대한 권리이고 또 저작자의 일신에 전속하여(저작권법 제14조 제1항) 양도할 수 없는 것이므로(대법원 1995. 10. 2.자 94마2217 결정), 저작자인격권은 위 집행대상이 되지 않는다고 해석된다.

의 재산권집행의 대상이 된다.

임차권을 위 집행의 대상으로 하기 위해서는 임대인의 동의가 있어야 하고(민법 제629조), 고용계약상 사용자가 노무제공을 받을 권리도 노무자의 동의가 있어야 위 집행의 대상이 된다(민법 제657조).

그리고 반도체배치설계권은 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률(1992. 12. 8.)에 의하여 새로이 성립된 무체재산권인데, 반도체집적회로의 회로배치의 적절한 이용의 확보를 도모함에 의하여 반도체집적회로의 개발을 촉진하는 것을 목적으로 하는 것이며, 회로배치 개발자의 권리를 무체재산권으로 구성하고 있다. 위 법에 의하여 보호의 대상으로 되는 권리는 기술혁신의 결과로서 출현되었고, 종래의 무체재산권에서는 보호될 수 없는 영역에 속하며, 위 법은 공업소유권, 저작권법에 이어 제3의 무체재산권으로 위치하게 된다. 설계권도 그 밖의 재산권의 집행대상이 된다.⁵⁸⁴⁾

그러나 소유권이전등기말소청구권은 금전집행의 준비행위로서 민법의 채권자대위권에 기하여 행사할 수 있으므로 금전집행의 직접적인 대상으로 될 수 있는 그 밖의 재산권에는 해당하지 않는다.⁵⁸⁵⁾

어음, 수표 등 지시증권에 화체된 금전채권에 대한 집행에 있어서는 배서가 금지된 것에 대하여만 특별현금화명령의 대상이 될 수 있고(민집 제233조), 배서가 허용되는 것은 유체동산으로 취급하여 민사집행법 제214조의 규정에 의한 특별현금화명령의 대상이 된다. 주권(株券)이 표창하는 주식도 민사집행법 제241조에 따른 특별현금화명령의 대상이 된다.⁵⁸⁶⁾

Ⅲ. 압류 및 현금화절차

1. 압류절차

가. 서

그 밖의 재산권에 대한 압류는 금전채권의 압류에 관한 규정(민집 제223조)을 준용하여 집행법원이 채권자의 신청에 의하여 압류명령을 발령하고 이를 송달함으로써 행한다.

584) 홍광식(주572), 289.

585) 日大阪高判 昭和 56(1981). 7. 27.(判例時報 1028号, 55.) 참조

586) 대법원 2011. 5. 6.자 2011그37 결정

관할 집행법원은 일반의 채권압류에 준하여 채무자의 보통재판적이 있는 곳을 관할하는 지방법원(민집 제224조 제1항)이다.

다만 특허권, 저작권 등의 지적재산권, 선박·항공기·자동차·건설기계·소형선박(자동차 등 특정동산 저당법 제3조 제2호에 따른 소형선박을 말한다)등의 공유지분, 등기된 임차권, 가등기상의 권리, 등기된 환매권, 합명회사 등의 사원권 등 그 권리 이전에 등기 또는 등록이 필요한 재산권에 대하여는 채무자의 보통재판적이 없는 때에는 압류할 채권이 있는 곳이라고 할 수 있는 그 등록 등을 하는 곳을 관할하는 지방법원도 보충적 관할 집행법원이 된다(민집규 제175조 제2항).

압류명령을 신청함에 있어서는 압류할 권리를 명확히 하면 되므로 그 존재나 채무자에의 귀속을 증명할 필요는 없다. 다만 권리이전에 관하여 등기 또는 등록을 요하는 그 밖의 재산권, 예컨대 등기된 임차권(민법 제621조 제2항, 부동산등기법 제3조 제8호, 제74조), 등록을 효력요건으로 하는 특허권, 실용신안권(특허법 제87조, 실용신안법 제21조), 등록된 저작권, 출판권(저작권법 제55조, 제63조) 등에 대한 압류명령의 신청에는 집행력 있는 정본 외에 그 기타 재산권에 관한 등기사항증명서 또는 등록원부의 등본이나 초본을 첨부하여야 한다(민집규 제175조 제1항).

또한 임차권 등과 같이 제3채무자의 동의가 있어야 압류가 가능한 권리의 경우에 그 동의 있음을 증명하는 자료를 제출하여야 한다.

나. 제3채무자 있는 재산권의 경우

1) 제3채무자의 의미

압류명령은 채무자에게 송달하여야 하며, 제3채무자가 있을 때에는 제3채무자에게도 송달하여야 한다(민집 제251조 제1항, 제227조 제2항). 압류명령은 그 송달로써 효력이 생긴다.

여기서의 제3채무자는 통상의 제3채무자(민집 제227조)에 비하여 넓은 개념으로 이해되는데, 압류된 권리의 행사에 있어 제3자의 급부가 필요하거나, 제3자의 법적 지위가 압류에 의하여 관련지워지는 그러한 모든 제3자를 말한다. 다시 말해, 채무자가 가지고 있는 재산권의 채무자 또는 그 재산권에 대하여 채무자 이외에 직접적인 이해관계에 있는 자를 말하며, 여기에서는 채권자와 채무자로서 대립되어 있는 것이 아니고 그 재산권에 대한 공유지분을 가진 자도 해당한다.⁵⁸⁷⁾

587) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 665.

구체적으로는 물건 또는 권리의 용익권에 있어서는 그 귀속자, 설비의 이용권에 있어서는 그 경영자, 사원권에 있어서는 회사 그 밖의 사단, 조합의 지분권에 있어서는 나머지 조합원, 공유지분에 있어서는 다른 공유자 등이 제3채무자가 된다.⁵⁸⁸⁾ 합자회사·합명회사 사원의 지분 등 사원권에 있어서는 그 법인이 제3채무자가 된다.

2) 제3채무자에 대한 지급금지 등

제3채무자가 있는 재산권의 압류에 있어서는 제3채무자에 대한 금지조항이 압류명령의 본질적 내용을 이루는 경우가 많으므로 채무자의 처분행위에 대하여 제3채무자가 승낙 기타의 협력을 하여서는 안된다는 취지를 명하고, 채무자에 대하여 추심을 금지하는 경우에는 이에 따른 제3채무자의 지급금지도 기재하여야 한다.

따라서 예컨대 골프회원권의 압류명령에는 골프장경영자에 대하여 회원권의 양도에 대한 승낙과 명의개서를 금지시키고 예탁금회원제의 경우에는 채무자에 대한 예탁금의 반환을 금지시킨다.

유체동산에 대한 공유지분의 압류에 있어서의 공유자처럼 채무자의 처분행위에 제3채무자의 협력이 필요 없는 경우에는 제3채무자에 대한 금지조항을 기재할 필요가 없다.

합명회사나 합자회사의 사원의 지분 및 민법상 조합의 조합원 지분에 대한 압류는 사원 또는 조합원의 장래의 이익배당과 지분의 환급을 받을 수 있는 권리에 당연히 미치므로(상법 제223조, 제269조, 민법 제714조), 그 추심이나 변제의 금지를 명하는 것은 주의적인 의미밖에 없다.

3) 등기·등록 등의 촉탁

권리이전에 관하여 등기 또는 등록을 요하는 그 밖의 재산권에 대한 강제집행에는 민사집행법 제94조 내지 제96조가 준용되므로(민집규 제175조 제5항), 법원사무관등은 압류명령 후 직권으로 그 사유를 등기기록 또는 등록원부에 기입하도록 등기·등록관계공무원에게 촉탁하여야 한다.

다. 제3채무자 없는 재산권의 경우

제3채무자가 없는 재산권으로는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등 지적재산권이 있다.

588) 민법상 조합의 경우 제3채무자는 조합원이 되지만, 업무집행사원이 있는 경우에는 그 자에 대한 송달로 충분하다고 볼 것이다(竹下守夫, 信用金庫の持分換價するとの可否“ジェリスト, No, 500, 120.).

이러한 지적재산권의 압류명령은 채무자에게 송달하여야 하고 권리처분의 제한에 관하여 등록을 하지 않으면 효력이 생기지 않으므로 압류의 효력은 압류명령의 송달과 압류 등록의 선후에 관계없이 언제나 등록을 한 때에 생기고, 등록 등이 처분제한의 효력발생요건으로 되어 있지 아니한 것(제3채무자가 없는 것으로는 저작권, 저작인접권, 회로배치이용권 등과 제3채무자가 있는 것으로는 특허권 등의 통상실시권, 출판권 등)은 제3채무자(제3채무자가 없는 경우에는 채무자)에 대한 송달과 압류의 등록 중 먼저 된 시점에 압류의 효력이 생긴다(민집규 제175조 제3항).

또한 특허권 등은 압류의 등록을 하도록 되어 있으므로 법원사무관등은 직권 또는 신청에 의하여 특허청 등에 결정등본을 첨부하여 등록을 촉탁하여야 한다(민집규 제175조 제5항, 민집 제94조). 이 경우 압류의 대상인 특허권 등을 등록번호와 명칭, 권리자의 주소, 성명 등을 명확히 표시하여 특정하여야 한다. 특허권 등의 압류가 있으면 특허권자 등은 당해 권리를 양도하거나, 질권 또는 전용실시권의 설정 등의 처분을 하는 것은 금지되나, 압류된 권리에 대하여도 통상의 이용관리를 하는 것은 허용되기 때문에 발명 등을 실시하는 권리까지 상실하는 것은 아니다.⁵⁸⁹⁾

라. 그 밖의 경우

그 밖의 재산권에 대한 압류의 효력발생 전에 등기 또는 등록이 되어 있는 담보권으로서 매각으로 소멸하는 것이 설정되어 있는 때에는 법원사무관등은 담보권자에게 압류사실을 통지하고, 그 담보권의 피담보채권액을 신고할 것을 최고하여야 한다(민집규 제175조 제4항).

이 경우에 동일재산권에 관하여 일반채권자의 신청에 의하여 강제집행절차가 개시된 때에도 담보권자가 우선변제를 받을 수 있음은 물론이므로 배당절차에서 담보권자에 대한 우선배당을 하기 위하여 담보권자에게 위와 같은 통지 및 최고를 하는 규정을 둔 것이다.

그 밖에 채권증서의 인도(민집 제234조) 및 제3채무자의 진술의무(민집 제237조)의 각 규정도 압류할 권리의 성질상 실익이 있는 한 위 압류에 준용된다.

2. 현금화절차

가. 서

압류된 그 밖의 재산권은 채권자의 신청에 따라 추심명령이나 전부명령 또는 민사집

589) 鹽崎勤, 注解 民事執行法(4), 第一法規出版株式會社, 699.

행법 제241조의 특별현금화방법에 따라 현금화된다(민집 제251조, 제229조, 제241조).

그런데 그 밖의 재산권은 그 종류가 다양하여 통상의 추심명령이나 전부명령 등 통상의 현금화방법으로는 현금화하기 어려운 경우가 많으므로 특별현금화방법에 의한 현금화가 적당한 경우가 많다.

특별현금화방법은 압류채권자의 신청에 의하여 발령되므로 그 구체적인 현금화 방법에 관하여도 압류채권자가 선택하여 신청하여야 한다. 그러나 압류채권자가 그 방법을 선택하지 않은 채 법원의 재량에 맡겨 신청한 때에는 집행법원이 그 방법을 선택할 수 있다고 본다.⁵⁹⁰⁾

양도명령 등 특별현금화의 요건은 첫째, 압류가 유효하여야 하고, 둘째, 집행 장애사유가 없어야 한다는 면에서 추심명령의 경우와 같으나, 그 밖에 특별현금화의 중심적 요소로서 피압류채권의 추심이 곤란한 경우⁵⁹¹⁾이어야 하고, 그 사유로서 조건부채권, 기한부채권, 반대의무의 이행과 관련된 채권⁵⁹²⁾ 등이 예시되어 있

590) 鹽崎勤(주589), 700.

591) '추심이 곤란하다는 것'은, 압류채권자가 피압류채권의 추심 또는 제3채무자의 공탁에 의해 배당등을 실시함으로써 직접, 그리고 확실하게 집행채권의 만족을 얻을 수 없고, 전부명령에 의한 현금화도 허용되지 않거나 상당하지 않은 사유가 있는 경우를 말한다고 볼 수 있다. 이러한 경우에 해당되는 채권으로는, ① 통상의 집행방법으로 추심이 곤란한 타인의 우선권의 대상이 되는 채권(질권 등 타인의 담보의 목적인 채권, 소송상 담보를 위한 공탁금반환청구권), ② 제3채무자가 유체물의 즉시인도를 거부할 수 있는 사유가 있는 유체물인도청구권 등, ③ 추심 또는 전부명령에 의해 집행의 목적을 달성하기 어려운 그 밖의 재산권, ④ 그 밖의 경우(제3채무자의 무자격, 파산, 거소불명, 외국거주, 국내재판권 불복종의 경우, 민사집행법 제233조의 지시채권에 관하여, 예컨대 어음의 만기가 이례적으로 장기간 후이거나, 제3채무자가 집행채무자에 대하여 반대급부의 인적항변으로 대항할 수 있는 경우 또는 어음·수표 금액이 집행채권액을 초과하는 경우 등) 등을 들 수 있겠다.

판례(대법원 2009. 2. 2.자 2007마1027결정)는, 여기서 '그 밖의 이유로 추심하기 곤란할 때'란 제3채무자의 무자격, 파산, 거소불명, 외국거주, 국내재판권 불복종의 경우 등을 비롯하여, 일반적인 집행절차를 통하여 채권자가 압류된 채권을 추심하기 어려운 사정이 있는 경우를 가리키는 것으로서, 매각명령을 할 것인지 여부는 집행법원이 해당 사건에 나타난 여러 사정을 종합적으로 고려하여 그 재량에 의하여 결정할 수 있다고 보고 있다. 위 판례는 채권자가 채권최고액 195억 원의 근저당권이 부착된 이 사건 채권 중 10억 원에 대하여만 압류 및 추심명령을 받았는데, 이 사건 채권에 대하여는 그 채권액이 131억여 원에 이르는 조세채권 뿐만 아니라 피보전채권의 합계액이 1,200억 원을 상회하는 채권이압류 및 압류가 되어 있는 경우에는 현실적으로 채권자가 스스로 추심권을 행사하여 강제집행하기 어려운 여러 사정이 있고, 이는 민사집행법 제241조 제1항 이 정한 특별현금화의 요건인 '그 밖의 이유로 추심하기 곤란할 때'에 해당한다고 보고 있다.

592) ① 조건부채권, 기한부채권 및 장래채권으로는, 임대차종료 후 건물등도 전의 임차보증금반환청구권, 장래의 임료(賃料)채권, 급료채권, 퇴직 전의 퇴직금청구권, 주주총회에서 배당금액이 확정되기 전의 이익배당청구권, 보험사고 발생 전의 보험금청구권 등이 이에 해당하고(이미 채권이 발생하여 채권액이 정해진 경우라도 변제기가 지나지 않는 것은 특별현금화의 대상이 된다), ② 반대의무의 이행과 관련되어 있는 채권으로는, 채권의 발생이 반대급부에 걸려있는 경우는 물론 반대급부에 의하여 비로소 채권이 확정되는 채권, 반대급부를 선이행으로 하는 채권 및 동시이행의 항변권이 붙은 채권도 특별현금화의 대상이 된다. 공사완성 전의 공사대금채권, 목적물인도 전의 매매대금채권 등이 그 전형적인 예이다.

다.⁵⁹³⁾

나. 추심명령 및 전부명령

추심명령은 그 밖의 재산권에서 생기는 금전채권, 예컨대 사원권으로부터 생기는 이익배당청구권, 지분환급청구권, 골프장회원권에 관련된 예탁금반환청구권 등에 대하여만 가능하다.

전부명령은 압류된 권면액의 채권을 집행채권의 변제를 위하여 압류채권자에게 이전하는 명령인데, 그 밖의 재산권으로서 권면액이 있는 것은 실제상 거의 찾아보기 어려우므로 압류된 재산권으로부터 생긴 지분권으로서의 금전채권에 대해 집행하는 경우 등에 한하게 된다.

다. 양도명령

1) 의의

피압류권리가 조건부, 기한부 또는 반대의무의 이행과 관련되어 있거나 기타 사유에 의하여 추심하기 곤란한 때에 집행법원은 압류채권자의 신청에 의하여 압류된 재산권을 집행법원이 정한 가액으로 지불에 갈음하여 압류채권자에게 양도하도록 명할 수 있는데(민집 제241조 제1항 제1호), 이를 양도명령이라고 한다.⁵⁹⁴⁾

전부명령이 피압류채권을 권면액으로 전부하는데 대하여, 양도명령은 당해 채권에 권면액이 없거나 이를 권면액으로 전부하는 것이 상당하지 않은 경우에 집행법원이 정하여 그 채권의 실질가액에 상당한 가액으로 지급에 갈음하여 양도하는 것이다.

그러나 이러한 양도명령은 압류채권자가 피압류채권을 대물변제적으로 취득함으로써 집행채권의 만족을 받는 점에서 전부명령과 같으므로 그 절차·효력 등에 관하여 전부명령의 규정이 준용되고 있다(민집 제241조 제6항, 제229조 제5항, 제231조).

2) 발령절차

가) 채무자의 심문

집행법원은 양도명령을 포함한 특별현금화의 신청을 허가하는 결정을 하기 전에 채무자를 심문하여야 한다.⁵⁹⁵⁾ 따라서 위 신청을 허가하는 결정을 하기 전에 채무자

593) 다만 이러한 조건부, 기한부채권 및 반대의무의 이행과 관련된 채권 등에 대하여도 전부명령을 널리 허용하는 것이 실무와 판례의 입장이므로 위 채권에 대해 특별현금화방법 이용될 여지는 그 만큼 줄어든다고 볼 수는 있다.

594) 별지서식 [3-13] 특별현금화명령 중 양도명령 참조(제3장 말미 수록)

595) 대법원 2009. 12. 24.자 2007마184 결정

에 대한 심문이 사실상 불가능하거나 채무자가 심문을 포기하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 필요적으로 채무자에 대한 심문절차를 거쳐야 한다.⁵⁹⁶⁾ 다만 채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 심문할 필요가 없다(민집 제241조 제2항). 신청을 기각하는 경우에도 심문할 필요가 없다.

심문기일의 기일 통지를 받고도 채무자가 정당한 사유의 신고 없이 기일에 출석하지 아니한 경우에는 자기의 이익을 포기한 것으로 볼 것이므로 다시 기일통지를 할 필요는 없다.

심문기일에는 심문조서를 작성하게 되어 있으나, 실무에서는 특별현금화명령을 발하기 전에 심문절차의 방식으로 심문서를 채무자 앞으로 송달하여 일정한 기간 안에 회답을 구하는 방법으로 이를 운용하고 있다.⁵⁹⁷⁾

만일 압류명령신청과 함께 양도명령을 신청한 경우에는 민사집행법 제226조에 의하여 먼저 심문 없이 압류명령을 하여 압류명령이 제3채무자와 채무자에게 송달된 후에 채무자를 심문하고 양도명령 등 특별현금화를 명하여야 한다.

나) 가액의 평가

집행법원은 양도명령 등 특별현금화를 명하는 경우에 필요가 있다고 인정하는 때에는 감정인에게 채권의 가액을 평가하게 할 수 있고, 이 경우 감정인은 법원이 정한 기일까지 평가결과를 보고하여야 한다(민집규 제163조). 특히, 양도명령은 전부명령에 준하는 것으로 집행채권이 소멸하는 범위를 확정하기 위해서도 감정이 필수적이다.

감정인으로는 당해 채권의 종류와 추심이 곤란한 사정에 따라 그 시장가격에 정통한 전문업자를 선정함이 바람직하다.

평가의 기준은 사안에 따라 다르나 피압류채권의 종류, 내용, 권면액, 추심이 곤란한 구체적 사정, 제3채무자의 자력 등을 고려하여야 한다.

3) 효력

가) 제3채무자에게 양도명령의 결정이 송달되어 확정되면 그 재판이 제3채무자에게 송달된 때에 소급하여 평가액(양도가액)의 한도 안에서 집행채권 및 집행비용청구권은 소멸하게 되고 채무자는 채무를 변제한 것으로 본다. 다만 재판의 송달시점에 피압류채권이 존재하지 아니한 때에는 집행채권 소멸의 효과가 발생하지 않는다(민집 제241조 제6항, 제231조).

596) 대법원 2009. 12. 24.자 2007마184 결정; 대법원 2010. 7. 26.자 2010마651 결정

597) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 411.

나) 법원이 정한 양도가액이 채권자의 집행채권과 집행비용의 액을 초과하는 때에는 집행법원은 양도명령을 발령하기 전에 채권자에게 그 차액(초과액)을 납부시켜야 하고,⁵⁹⁸⁾ 양도명령이 확정된 때에는 그 금액을 채무자에게 교부하여야 한다(민집규 제164조, 제82조).

집행법원은 금전납부명령을 받은 압류채권자가 양도가액과 압류채권자의 채권(이 채권에는 차액의 납부기한까지의 지연손해금을 포함한다) 및 집행비용액의 차액을 납부한 때에는 양도명령을 발령한다. 만약 차액을 정해진 기한까지 납부하지 않는 경우에는 양도명령의 신청을 각하하게 된다.

다) 위와 같은 양도명령은 압류채권자에게 우선적 지위를 주는 것이므로 채권자가 경합되어 있는 때에는 허용되지 않는다. 즉 양도명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 피압류채권에 관하여 다른 채권자가 압류·가압류 또는 배당요구를 한 경우에는 양도명령을 발령할 수 없고, 발령하더라도 그 양도명령은 효력이 없다(민집 제241조 제6항, 제229조 제5항).

또한 체납처분에 의하여 압류가 되어 있는 때에도 현금화를 위한 절차를 할 수 없고 양도명령을 발하더라도 그 효력이 생기지 않는다.⁵⁹⁹⁾

라) 양도명령이 확정되어 그 효력이 생기는 때에는 압류채권자는 압류된 채권을 취득하게 되므로 채권집행절차는 끝나고 압류채권자가 납부한 차액에 상당하는 금전은 채무자에게 교부하게 된다. 채무자에 대한 차액의 교부절차는 법원사무관등이 하고, 이 교부는 배당절차라고 할 수는 없으나 민사집행규칙 제164조 제2항에서 준용하는 같은 규칙 제82조를 적용하여 배당절차에 준하여 이루어진다.

마) 저당권부채권에 관하여 양도명령이 확정된 때에는 법원사무관등은 압류채권자의 신청에 의하여 등기관에게 채권을 취득한 채권자에 대한 저당권이전등기와 압류기입등기의 말소를 동시에 촉탁하여야 한다. 이 경우 촉탁서에는 양도명령의 정보를 붙여야 하고, 촉탁에 관한 비용은 채권자의 부담으로 한다(민집 제241조 제6항, 제230조, 민집규 제167조).

라. 매각명령

1) 의의

매각명령이란, 압류채권자의 신청에 따라 채권의 추심에 갈음하여 압류된 채권을

598) 별지서식 [3-28] 양도명령 전의 금전납부명령 참조(제3장 말미 수록)

599) 홍광식(주572), 297.

집행법원이 정하는 방법으로 집행관에게 매각하도록 하는 결정이다(민집 제241조 제1항 제2호).⁶⁰⁰⁾ 집행법원이 피압류채권의 매각을 집행관에게 명하여 현금화하는 점에서 부동산의 강제경매절차와 유사하나, 집행관에 의한 매각 자체는 유체동산집행의 그것에 준하여 행해지는 경우가 많다.⁶⁰¹⁾

또한 매각명령은 확정되지 않으면 효력이 생기지 않는다는 점에서 집행법원의 집행관에 대한 단순한 직무명령과 다르다(민집 제241조 제4항).

실무상 매각명령은 전화가입권, 골프회원권 등의 기타재산권에 대한 집행에 관하여 신청되는 것이 대부분으로 보인다.

2) 발령절차 등

가) 앞서 본 양도명령의 경우와 거의 같다. 다만 다른 채권자에 의하여 경합하는 압류, 가압류의 집행 또는 배당요구(교부청구를 포함)가 되어 있는 경우에도 발령할 수 있다는 점에서 양도명령의 경우와 다르다. 채무자의 심문, 평가, 발령시기 등은 양도명령의 경우와 같다.

나) 매각명령의 신청에 관하여 채무자, 제3채무자에게 송달하여야 한다는 취지의 규정은 없으나, 이에 대하여 즉시항고를 할 수 있으므로 실무에서는 양도명령의 경우와 같은 방법으로 고지절차가 취하여진다.

매각명령은 확정에 의하여 그 효력이 생기고, 확정 후 집행법원은 집행관에 대하여 명령의 내용을 고지하고 집행관은 매각명령에 따라 피압류채권의 매각을 실시한다.

다) 집행법원이 정한 매각방법에 관하여는 특히 제한은 없으므로 부동산의 강제경매의 경우와 같은 매각 외에 수의적(隨意的)인 방법(예컨대, 집행관이 특정한 자 또는 불특정한 자와 개별 절충하여 매매계약을 체결하는 방법이나 정가를 광고한 다음에 최초의 신청자에 대하여 매각하는 방법)에 의하여 매각을 명할 수 있으나, 매각명령에 대해 특별한 방법의 지시가 없으면 집행관은 위에서 본대로 유체동산집행에 준하여 채권을 매각하게 된다.

라) 그리고 매각명령의 경우에도, 초과매각이나 무잉여매각 금지규정(민집 제188조 제2, 제3항)의 저촉 여부를 미리 확인하기 위해 또 매각절차에서도 참고가 되므로 감정인에 의한 가액평가를 거치는 것이 바람직하다.

집행법원은 채권평가의 결과(민집규 제163조) 압류된 채권의 매각대금으로 압류

600) 별지서식 [3-14] 특별현금화(매각)명령 신청서 및 [3-15] 특별현금화명령 중 매각명령 등 참조 (제3장 말미 수록)

601) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 415.

채권자의 채권에 우선하는 채권 및 절차비용을 변제하면 남을 것이 없겠다고 인정하는 때에는 매각명령을 내릴 수 없다(민집규 제165조 제1항). 이것은 무잉여의 경우에 현금화를 금지한 것으로 민사집행법 제102조와 같은 취지이다.

마) 또한 집행관에 의한 매각에는 최저매각가격제도가 적용되지 아니하나 집행법원이 감정을 통하여 그 평가액을 최저매각가격이나 매각액으로 정할 수는 있다. 매각명령을 받은 집행관은 압류채권자의 채권에 우선하는 채권 및 절차비용을 변제하고 남을 것이 있을 가격이 아니면 압류된 채권을 매각하여서는 안 된다(민집규 제165조 제2항). 매각을 하더라도 남을 것이 없는 경우에는 집행관은 매각불능으로 보아 매각 실시절차를 마쳐야 한다.

매각을 함에는 집행관은 그 장소의 질서유지를 위하여 민사집행법 제108조의 규정에 의한 조치를 할 수 있다(민집 제241조 제6항). 집행관에게 임의매각이 명하여지면 가격은 그 매수인과의 계약에 의하여 결정되게 된다. 집행관은 매각함에 있어 권리 이전에 필요한 계약을 체결하는 등 실체법상의 처분행위를 할 수 있다.

바) 매수인이 당해 채권을 취득하는 것은 그 대금을 집행관에게 지불한 때라고 해석되고 있고,⁶⁰²⁾ 또 집행관이 이와 같이 매각대금을 영수하면 그 때에 채무자가 이를 지급한 것으로 보고 있다(민집 제208조 유추).

사) 집행관은 매각절차를 마친 때에는 스스로 배당할 수 없고, 바로 매각대금과 매각에 관한 조서를 집행법원에 제출하여야 하며(민집규 제165조 제4항), 매각대금이 제출된 때에는 집행법원에 의한 배당절차가 개시된다(민집 제252조 제3호).

압류된 채권을 매각한 경우에는 집행관은 채무자를 대신하여 제3채무자에게 서면으로 양도의 통지를 하여야 한다(민집 제241조 제5항). 저당권부채권에 대한 매각이 종료된 때에는 법원사무관등은 앞서 양도명령에서 설명한 바와 같은 절차로 저당권이전등기 등을 촉탁한다(민집규 제167조).

마. 관리명령

1) 의의

관리명령이란, 집행법원이 채권의 관리인을 선임하여 압류된 채권의 관리를 명하고 그 수익으로 집행채권의 만족을 얻도록 하는 것이다. 이 명령은 압류된 채권 자체는 채무자 이외의 자에게 이전하지 아니하면서 이를 관리인에게 관리하게 하여 그 수

602) 홍광식(주572), 303.

익으로 추심을 피하는 제도인바, 관리가 용이하여 그 수익이 확실한 채권에 적합한 현금화방법이고, 다수의 임료채권을 압류한 경우나 특허권 등 산업재산권, 저작권, 출판권 등의 현금화에 이용될 수 있다.

2) 발령절차 등

채무자의 심문, 평가에 관하여는 양도명령, 매각명령 등의 경우와 같다. 다만 관리명령은 채권의 관리를 명하여 그 수익을 가지고 변제에 충당하는 것이므로 양도명령이나 매각명령의 경우와 같이 평가의 필요가 생기는 일이 많지 않다. 관리명령은 양도명령, 매각명령의 절차와 비교하여 현금화절차 자체가 번잡하고 장기화되기 쉽고, 절차비용이 고액으로 되는 것이 많다고 생각되나, 다른 한편 이 절차에서는 채무자에게 그 채권의 귀속을 상실하지 않게 하면서 현금화할 수 있어 채무자에게 유리한 면도 있는 것이다.

그리고 매각명령과 달리 잉여가 생길 가능성이 없는 때에 있어서 발령을 금지하는 규정은 없으나, 채권의 관리에 의하여 얻어지는 수익액이 관리를 위하여 요하는 비용을 상회할 가능성이 없는 때에는 관리명령을 발령할 수 없다고 본다.⁶⁰³⁾

관리명령의 신청서에는 수익의 지급의무를 부담하는 제3자가 있는 경우에 그 제3자의 표시와 함께 지급의무의 내용도 적어야 한다. 집행법원이 관리명령을 함에는 적당한 사람을 관리인으로 선임하고 그에게 압류된 권리에 대한 관리수익금을 제출하도록 명하여야 하며, 수익의 지급의무를 부담하는 제3자에게 그 수익을 관리인에게 지급하도록 명하여야 한다. 이 경우에 필요하면 수익금의 처리에 대한 자세한 사항을 정할 수 있고, 관리인의 보수도 정할 수 있다.

3) 채권의 관리

관리명령에 기한 채권의 관리에 대하여는 민사집행법 제222조 제2항, 제3항이 준용되는 외에 부동산강제관리규정이 널리 준용된다(민집 제241조 제6항). 결국, 그 절차는 관리명령의 대상으로 된 채권에 관하여 관리인이 채무자를 대신하여 관리수익권을 행사하고, 수익금부담무를 부담하는 제3자로부터의 수익을 추심한 다음 이를 배당재단으로서 집행법원이 정한 기간마다 관리인이 배당등을 실시하고, 그 배당등 절차에 있어서 채권자들 사이에 협의가 조정되지 않은 때 등의 경우에는 집행법원이 배당등 절차를 진행하여 집행채권의 변제에 충당하게 된다.

그리고 관리인은 관리명령이 된 재산권에 관하여 관리, 수익의 수취·현금화를 하는 것이 가능하고, 일정기간마다 배당에 충당하여야 하는 금전의 액을 계산하여 배당을 실

603) 홍광식(주572), 305.

시하며, 임무가 종료한 경우에는 집행법원이 계산의 보고를 하여야 하는데, 관리를 위하여 필요한 비용의 선불을 받을 수 있고, 또 집행법원이 정한 보수를 받을 수도 있다.

바. 그 밖의 상당한 방법에 의한 현금화

위에서 든 방법 이외에 특별현금화방법으로는, ① 피압류채권을 취득할 수 있는 자의 자격이 한정되어 있는 등 특히 그 제3자에게 채권을 양도하는 것이 상당하다고 인정되는 경우에 이용되어야 하는 방법으로서 특정의 제3자에 대하여 평가액에 상당한 대금을 납부시켜 채권을 양도하는 방법, ② 전화가입권을 목적으로 하는 질권의 실행에 있어서 특별현금화에 준하여 피압류채권 또는 제3자가 특정한 전문업자 등으로 현금화절차의 공정이 기대될 수 있는 경우에 한하여 발령하는 방법으로서 압류채권자 또는 제3자로 하여금 압류된 채권을 매각시켜 그 대금으로 변제에 충당하도록 하는 방법, ③ 압류채권자의 현금화권능을 추심권에 국한하여 그 대신으로 압류채권자, 제3채무자 사이에서 지불조건 기타에 관한 합의를 하는 것을 인정하는 방법, ④ 단위미달주식에 관하여 매수청구권을 행사시키는 방법 등을 생각해 볼 수 있다.⁶⁰⁴⁾

그 신청절차, 채무자의 심문, 평가, 즉시항고에 의한 불복신청, 확정에 의한 효력의 발생 등에 관하여는 특칙이 있는 경우를 제하고 양도명령 등의 경우와 같고, 다른 점에 관하여는 각 현금화방법의 성질에 맞추어 해석하면 될 것이다.

사. 현금화의 효력

양도명령, 매각명령 기타의 처분에 의한 압류물 양도의 효력은 실체법의 규정에 의하여 결정할 것이고 강제집행에 의하였다고 해서 특별한 효과가 생기는 것은 아니다.

따라서 그 양도에 관하여 제3채무자 등의 동의, 승낙 등이 있어야 하는 재산권(민법 제629조, 상법 제197조, 제276조, 제556조, 특허법 제99조, 실용신안법 제28조, 저작권법 제46조 제3항, 농업협동조합법 제23조)에 대하여는 그에 필요한 동의, 승낙 등이 없는 한 완전한 권리이전의 효과가 생기지 아니한다.⁶⁰⁵⁾

아. 특별현금화명령의 송달 및 불복방법 등

양도명령, 매각명령, 관리명령 등의 특별현금화명령도 압류명령과 마찬가지로 제3채무자와 채무자에게 송달하여야 한다(민집 제241조 제6항, 제227조 제2항). 특별현금화명령을 기각하는 결정은 신청채권자에게만 고지하면 된다.

604) 홍광식(주572), 306.

605) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 670.

위 특별현금화명령에 대하여는 즉시항고를 할 수 있고(민집 제241조 제3항), 위 명령은 확정되어야 효력을 가진다(민집 제241조 제4항).⁶⁰⁶⁾ 위 명령에 대하여 즉시항고를 할 수 있는 사람은 그 명령에 의하여 자기의 정당한 이익을 침해당한 자로서, 보통은 채무자와 제3채무자이다.

특별현금화신청을 기각한 결정에 대하여는 명문의 규정이 없어 보이나, 실무상 압류명령에 대한 민사집행법 제227조 제4항, 추심명령 등에 대한 민사집행법 제229조 제6항과 비교하여 볼 때 신청채권자에게 즉시항고권이 인정되어야 한다는 견해⁶⁰⁷⁾와 이를 부정하는 견해가 있다. 이에 관하여 대법원 2011. 1. 14.자 2010그185 결정은 이 경우 즉시항고가 아닌 특별항고를 해야 한다는 취지로 판시한 바 있으나,⁶⁰⁸⁾ 그 후 대법원 2012. 3. 15.자 2011그224 결정이, ‘민사집행법 제241조

606) 대법원 2010. 7. 23.자 2008마247 결정【결정요지】[1] 집행관이 질권에 기초한 채권특별환가명령에 따라서 매각절차를 진행하면서 당초 채권특별환가명령에서 정한 최저매각가격을 경정한 경정결정이 확정되지 않았음에도 그 효력을 가진다고 오인하고 그 경정결정에서 정한 바에 따라 당초 최저매각가격에 못 미치는 가격으로 매수 신청한 자에게 매각을 허가하였다고 하더라도, 매수인이 그 매각허가에 따라 매각대금을 납부하였다면 환가명령의 기초가 된 질권이 당초부터 부존재하였거나 환가명령의 효력 발생 이전에 피담보채무가 변제 등으로 소멸하였다는 등의 사정이 없는 한 매수인은 그 채권을 유효하게 취득하게 된다. 그리고 이러한 매수인의 채권 취득의 효과는 그 채권 취득 이후에 위 경정결정이 즉시항고에 의하여 취소되더라도 반복될 수 없다. [2] 질권에 기초한 채권특별환가절차에서 당초 채권특별환가명령에서 정한 최저매각가격을 경정한 경정결정에 따라 매각절차가 진행되어 매수인이 매각허가에 따라 매각대금을 납부하였으나 이후 위 경정결정이 즉시항고에 의하여 취소된 사안에서, 위 경정결정이 취소되더라도 집행법원이 정한 최저매각가격에 못 미치는 가격으로 매각한 하자만으로는 매수인이 매각대금을 납부함에 따라 채권을 취득하였다는 법률효과를 뒤집을 수 없으므로, 매수인이 재항고로 위 경정결정을 취소한 결정의 파기를 구할 이익이 없다고 한 사례.

607) 박두환(주6), 581.

608) 이 사건 원심법원인 인천지방법원 2010. 7. 23.자 2009라308 결정은, 민사집행법 제15조 제1항은 집행절차에 관한 집행법원의 재판에 대하여는 특별한 규정이 있어야만 즉시항고를 할 수 있다고 규정하고 있는데, 같은 법 제241조 제1항은 압류된 채권이 조건 또는 기한이 있거나, 반대의무의 이행과 관련되어 있거나 그 밖의 이유로 추심하기 곤란할 때에는 법원은 채권자의 신청에 따라 양도명령(제1호), 매각명령(제2호), 관리명령(제3호), 현금화명령(제4호)을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 제1항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다고 규정하고 있으므로 법원이 채권자의 신청에 따라 양도, 매각, 관리, 현금화를 명하는 결정을 내린 경우에 대하여 채무자가 즉시항고를 제기할 수 있지만, 그 밖의 경우 즉 법원이 채권자가 한 양도, 매각, 관리, 현금화 명령 신청을 기각하는 결정을 내린 경우 그 재판에 대하여는 즉시항고를 제기할 수 없고, 결국 이에 대하여는 민사집행법 제23조 제1항에 의하여 준용되는 민사소송법 제449조의 특별항고로서만 불복할 수 있다는 취지로 판시하고 있는바, 대법원 또한 이러한 논지를 그대로 받아들이고 있다. 그리고 특별항고만이 허용되는 재판의 불복에 대하여는 당사자가 특히 특별항고라는 표시와 항고법원을 대법원으로 표시하지 않았다고 하더라도 그 항고장을 접수한 법원으로서 이를 특별항고로 보아 소송기록을 대법원에 송부하여야 한다(대법원 1987. 12. 30.자 86마347 결정; 대법원 2009. 5. 20.자 2009그70 결정 등).

제1항에 의한 채권자의 특별현금화명령 신청에 대하여 특별현금화를 명할 것인지 여부나 그 방법의 선택은 법원의 재량에 맡겨져 있으므로 같은 조 제3항에서 즉시항고의 대상으로 규정하고 있는 “제1항의 결정”에는 특별현금화명령 신청을 받아들이는 결정뿐만 아니라 그 신청을 기각하는 결정도 포함된다고 볼 수 있다’라고 판시함으로써 이 경우도 즉시항고가 가능함을 인정하였다.

위 특별현금화명령의 취지에 따라 추심의 소를 제기하는 채권자는 채무자에 대하여 소송고지를 하여야 하고(민집 제238조), 그 명령의 신청이 취하되거나 이를 취소하는 결정이 확정된 때에는 법원사무관등은 압류명령을 송달받은 제3채무자에게 그 사실을 통지하여야 하는 것(민집규 제160조 제2항)은 추심명령, 전부명령 등에 대한 경우와 같다.

IV. 전화사용권에 대한 집행

1. 서

전화사용권이라 함은 전화가입자가 가입전화에 의하여 공중통신업무의 제공을 받는 권리를 말한다.

전기통신사업법(1991. 8. 10. 법률 제4394호)은 종래 양도가 가능하던 1970. 8. 31. 이전에 가입계약된 전화사용권의 양도 여부에 대하여 아무런 규정을 두지 아니하여 그 양도의 법적 근거가 없어졌으나, 주식회사 케이티(KT)의 실무에 의하여 명의변경 형식으로 사실상 양도를 허용하고 있으므로, 종래 양도 가능하던 전화에 대한 사용권은 그 밖의 재산권에 대한 집행의 방법으로 강제집행할 수 있다.⁶⁰⁹⁾

1970. 9. 1. 이후에 가입계약된 전화에 대하여는 원칙상 전화사용권 자체를 강제 집행의 대상으로 할 수 없으나, 전화가입자는 가입계약의 해지를 할 수 있고 그 계약을 해지할 때에는 가입자가 납입한 설비비를 상환받을 수 있으므로 전화가입자의 채권자는 채무자의 전화가입계약해지권을 대위행사하여 가입전화설비비반환청구권에 대하여 압류 및 전부명령신청을 할 수 있다는 것이 판례의 태도였다.⁶¹⁰⁾ 그런데 주식

609) 홍광식(주572), 345.

610) 대법원 1976. 2. 24. 선고 76다52 판결【판결요지】전화가입계약의 해지권은 일신전속적인 권리가 아니므로 채권자가 채무자의 전화가입 계약의 해지권을 대위행사한 행위는 적법하다.

회사 케이티(KT)의 실무는 1970. 9. 1. 이후에 가입계약된 전화에 대하여도 승계 또는 명의변경의 형식으로 사실상 그 양도를 용인하고 있는 실정이어서 이 또한 그 밖의 재산권에 대한 집행방법에 의한 강제집행이 허용될 여지가 있다.

이하에서는 양도가능한 전화의 전화사용권에 대한 집행에 대하여 보기로 한다.

2. 압류절차

가. 신청

전화사용권에 대한 압류명령신청의 방식은 채권압류명령신청의 경우와 대체로 같다. 압류명령의 신청서에는 전화번호, 가입자의 성명 및 주소, 가입전화의 설치장소, 그 가입전화가 양도가능한 사실에 관하여 가입전화의 소관전화국에서 발행하는 전화가입증명서 그 밖의 소명자료를 첨부하여야 한다. 또 제3채무자인 주식회사 케이티의 등기사항일부증명서를 붙여야 한다.

나. 압류명령

집행법원은 신청이 상당하다고 인정될 때에는 압류명령을 발한다. 위 압류명령의 기재내용은 금전채권에 대한 압류에 준한다(민집 제251조, 제227조).

압류명령 신청에는 전화번호, 가입자의 성명, 주소 또는 거소, 가입전화의 설치장소를 명시한다. 또 양도가능한 가입전화번호를 명확하게 하기 위해 전화관서가 발행한 가입사실증명서를 첨부한다. 전화가입원부상 가입자 주소와 압류명령상의 주소가 다르면 압류등록이 되지 않으므로, 집행채무자의 현주소와 전화가입원부상의 전화가입자 주소가 다르면 양자를 병기(併記)하도록 한다.

제3채무자는 “주식회사 케이티(KT)”로 하고 그 주된 사무소와 대표자인 사장의 성명 및 소관 전화업무취급국(구 공중전기통신사업법 제2조 제1항 제2호 참조, 현재는 전화사업경영자라고 함)을 부기함이 상당하다.

압류명령의 기재 내용은 금전채권에 대한 압류에 준하나 가입전화사용권의 특성상 채무자에 대한 채무자에 대한 영수의 금지나 제3채무자에 대한 지급의 금지는 별 의미가 없으므로 채무자에 대한 처분금지와 제3채무자에 대한 가입권명의변경금지를 명하면 족하다. 전화사용권에 대하여도 압류의 일반원칙에 따라 중복압류가 가능함은 물론이고, 상호 배당요구의 효력이 발생한다.

압류명령의 주문은 다음과 같이 적으면 될 것이다.

채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지목록 기재의 전화사용권을 압류한다.
제3채무자는 위 전화사용권에 대하여 채무자의 신고로 명의변경을 하여서는 아니 된다.
채무자는 위 전화사용권에 대하여 매매, 양도 그 밖에 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.

다. 압류명령의 송달

전화가입원부예의 등록(구 공중전기통신사업법 제27조 참조)은 소관 전화사업경영자가 그 의무로서 내부사무처리의 기본인 장부상에 기재하는데 불과하며, 압류의 효력은 제3채무자에게 송달된 때에 발생하고 이때에 대항요건도 갖추어지며 등록과는 관계없다. 따라서 압류명령이 송달되었으나 다만 원부상 등록이 되어 있지 않은 상태에서 압류된 전화사용권을 선의로 양도받은 양수인이라고 하더라도 압류채권자에게 대항할 수 없다.

압류명령은 채무자 및 제3채무자에게 송달하여야 하는바, 특히 제3채무자에 대한 송달은 소관 전화업무취급국으로 한다.

집행법원은 압류명령의 송달과 동시에 그 후의 절차를 원만히 진행하기 위하여 소관 전화업무취급국에 채무자가 당해 전화의 가입자가 아닌 경우에는 그 취지, 가입자인 경우에는 압류, 가압류, 가처분, 체납처분압류가 되어 있는 때에는 그 연월일, 처분청, 사건번호, 채권자의 성명, 주소, 처분서의 송달일, 전화요금체납이 있는 경우에는 그 액수 등을 회답하여 줄 것을 조회하는 것이 바람직하다.

3. 현금화(환가)

압류채권자는 압류한 전화사용권으로부터 집행채권의 변제를 받기 위하여서는 양도명령이나 매각명령 또는 기타의 특별현금화방법을 신청하여야 한다. 채권자는 현금화방법을 집행법원이 정하여 주도록 신청할 수도 있다.

가. 양도명령

양도명령은 전화사용권을 집행관 또는 적당한 감정인으로 하여금 평가하게 하여 그 가격으로 변제에 갈음하여 채권자에게 양도하는 것을 말한다.

앞서 보았듯이 이중압류나 배당요구 등으로 채권자의 경합이 있는 경우에는 양도명령은 허용되지 아니한다. 평가가 전제되어야 하므로 압류명령신청과 동시에 신청

된 경우에는 이를 동시에 발하기는 어렵다.

집행법원은 전화사용권을 평가한 결과 수개의 압류 전화사용권 중 일부로도 집행채권과 집행비용 등을 만족시킬 수 있는 것으로 판단되는 때에는 초과압류금지원칙(민집 제188조)에 따라 초과부분에 해당하는 가입권에 대하여는 양도명령을 기각하고, 압류명령을 취소하여야 한다.

양도명령을 함에 있어서 평가액이 채권자의 채권 및 집행비용과 연체전화요금을 초과하는 때에는 집행법원은 양도명령을 발하기 전에 채권자로 하여금 그 차액을 납부시켜 양도명령이 확정된 후 그 금액을 채무자에게 교부하여야 한다(민집규 제164조). 이 경우 실무상 채권자에게 일정한 기한을 정하여 납부명령을 내리는데 채권자는 이에 대해 불복할 수 없고 그 평가액에 대해 불만이 있으면 매각의 방법을 선택하여 신청할 것이다.

양도명령의 주문은 다음과 같이 적으면 된다.

위 당사자간 ○○지방법원 2○○○타채○○ 전화사용권 압류명령에 의하여 압류된 별지 기재의 전화사용권을 금 ○○○원으로 지급에 갈음하여 채권자에게 양도한다.

이 경우 양도가액은 평가액에서 집행비용 및 후에 채권자가 부담할 수밖에 없는 체납전화요금 등을 공제하고 실제로 집행채권이 소멸하게 되는 금액을 기재하며, 그 금액이 집행채권액을 초과하는 경우에는 차액을 납부시키고 양도가액으로는 집행채권액을 기재하면 될 것이다.

양도명령이 확정되면 채권자는 그 전화사용권을 취득하게 되고 양도명령에 명시된 양도가액에 상당한 집행채권은 소멸하게 된다.

위 양도명령은 제3채무자 및 채무자에게 송달하여야 한다. 위 명령에 대하여는 채무자나 제3채무자 등 자기의 정당한 이익이 침해되었음을 주장하는 자가 즉시항고를 할 수 있다(민집 제241조 제3항). 위 양도명령은 확정되어야 효력이 있고 효력발생시기는 제3채무자에게 송달된 때로 소급한다(민집 제241조 제4항).

나. 매각명령

매각명령은 법원이 정하는 방법으로 전화사용권을 매각할 것을 집행관에게 명하는 현금화방법이다. 매각명령은 압류명령과 함께 신청할 수 있다.

일반적으로 유체동산집행의 방법에 의한 매각을 명하게 되나, 매각 이외의 방법으로 임의매각할 것을 명할 수도 있다. 집행관은 집행법원의 특별한 지시가 없을 경

우 매각하여야 할 것이다.

집행법원은 압류된 전화사용권의 매득금으로 채권자의 채권에 우선하는 채권 및 절차비용을 변제하면 잉여가 없다고 인정하는 때에는 매각명령을 발하여서는 아니되며, 집행관도 잉여가 있을 가격이 아니면 전화사용권을 매각하여서는 아니된다(민집규 제165조 제1항, 제2항). 따라서 법원은 무잉여압류 여부, 초과압류의 여부(민집규 제188조 제2항) 등을 알아보고 매각에 참고하기 위해 매각명령 전에 전화가입권을 적당한 감정인에게 평가하게 하여야 한다.

집행관에 의한 매각에는 최저매각가격제도는 적용되지 아니하나, 집행법원은 그 평가액을 최저매각가격이나 매각액으로 정할 수도 있다.

매각명령의 주문은 다음과 같다.

위 당사자간 ○○지방법원 2○○○타채○○ 전화사용권압류명령에 의하여 압류된 별지 기재의 전화사용권을 매각할 것을 명한다.
채권자의 위임을 받은 집행관은 유체동산 매각에 관한 절차에 따라 매각하여야 한다.

매각명령은 채무자 및 제3채무자에게 송달하여야 하고 이해관계인은 매각명령에 대하여 즉시항고로 불복할 수 있다. 매각명령은 확정되어야 효력이 있다.

채권자의 위임을 받은 집행관이 매각절차를 종료한 때에는 지체 없이 매득금과 매각조서 등 관계서류를 집행법원에 제출하여야 한다(민집규 제165조 제4항). 매각대금은 법원보관금취급규칙에 따라 취급점인 은행에 납부한다.

매각대금이 제출되면 집행법원은 소관 전기통신사업자에 사실조회 등을 통하여⁶¹¹⁾ 당해 전화사용권에 대한 압류의 경합 여부를 조사하고 압류의 경합이 있는 경우에는 그 기록의 송부를 촉탁한 후 민사집행법 제252조의 규정에 따라 배당절차를 실시한다(민집 제252조 제3호).

다. 그 밖의 특별현금화방법

집행법원은 특정의 제3자(전화중개상 등)로 하여금 전화사용권을 임의매각하게 하거나 평가액으로 제3자에게 양도할 것을 명할 수 있다(민집 제251조, 제241조 제1항).

법원은 채권자가 그 현금화방법을 특정하여 신청한 경우는 물론 현금화방법을 특정하지 아니하였거나 또는 다른 현금화방법을 신청한 경우에도 그 방법이 전화사용권의 현금화방법으로는 적당치 아니하다고 판단되는 등의 사정이 있는 때에는 재량으

611) 별지서식 [3-9] 압류의 경합 여부 등에 관한 사실조회 참조(제3장 말미 수록)

로 적당한 현금화방법을 명할 수 있다.

이 경우 신청채권자는 즉시항고로 불복할 수 있다 하겠다(민집 제241조 제3항).

V. 골프회원권에 대한 집행

1. 서

골프회원권은 소속 골프클럽에 의해 상당히 고가로 거래되고, 그 재산적 가치도 높기 때문에 압류의 대상으로 되는 경우가 많이 있다.

그러나 골프회원권은 그 골프장의 경영형태와도 관련한 법적 성질 등 각종의 문제점이 있고, 집행절차상으로도 곤란한 문제가 생기는 경우가 있다. 그러므로 이하에서 골프장의 경영형태에 대해 개관한 후, 골프회원권의 집행적격, 압류 및 현금화 등에 대하여 검토하기로 한다.

2. 골프장의 경영형태 및 역사적 전개

가. 골프장의 경영형태는 여러 가지가 있지만 기본적으로는 ① 골프장회원이 골프장을 경영하는 사단법인의 구성원이 되는 사단법인회원제, ② 골프클럽에 입회하는 회원이 골프장을 경영하는 주식회사의 주주가 되고, 동시에 클럽의 회원이 되어 시설을 이용하는 권리를 취득하는 주주회원제, ③ 골프클럽에 입회하는 회원이 골프장을 경영하는 회사에 예탁금을 예탁하는 예탁금회원제의 3가지 종류가 있는바, 그 중 예탁금회원제가 가장 많고 주주회원제가 그 다음을 차지하며 사단법인회원제는 공익법인 등이 설치한 골프장의 경우에 예외적으로 존재하는 것으로 보인다.

나. 위 형태 중 어떤 경우이든 회원권은 골프장과 부대시설의 우선적 이용권을 중심으로 한 권리임에 틀림이 없으나, 예탁금회원제는 예탁금반환청구권이라는 채권과 결부된 것임에 비하여, 주주회원제 또는 사단법인회원제는 주주 또는 사단법인의 사원(社員)인 지위와 결합한 것이라는 점에서 차이가 있다.

다. 역사적으로는, 전전(戰前) 영미류의 프라이비트·클럽의 조직과 운영을 모범으로 한 회원제 클럽이 있었고, 당초 이것은 법인격 없는 임의단체였지만, 재산보유 등의 관계상 이후 법인화되어 사단법인의 형태를 취하게 되었다.

그러나 골프클럽에는 공익성의 점에서 문제가 있기 때문에 사단법인으로 설립

하는 것이 곤란하게 되어 주주회원제클럽의 형태가 출현하게 되었다. 그리고 주주회원제의 형태도 회원의 의사에 의한 컨트롤을 가능한 한 약하게 하겠다고 생각한 기업경영자의 생각에서 회원의 예탁금의 일부만이 주식화되고, 그 후는 예탁금으로 하는 주식·예탁금 병용형(併用型) 주주회원제 골프클럽 등이, 또 나아가 회원의 회사경영에 대한 관여를 부정하는 예탁금회원제클럽이 등장하여 기업주도형의 클럽형식으로 일반화됨으로써 현재에는 골프클럽의 대부분이 이러한 형태를 취하게 되었다.⁶¹²⁾

3. 골프회원권의 집행적격

가. 민사집행법은 채권이나 그 밖의 재산권에 대한 강제집행을 규정하고 있으나(민집 제251조), 골프회원권은 그 밖의 재산권으로서 그 집행의 대상이 되는지 여부가 문제로 될 수 있다.

즉 어떤 권리가 그 밖의 재산권으로서 집행의 대상이 될 수 있기 위해서는 ① 재산적 가치를 가지고 ② 양도성을 가지는 것이어야 한다는 2가지의 요건을 갖추어야 하는데, 골프회원권의 경우 재산적 가치를 가진다는 데에는 이론이 없지만, 그 양도성에 관해서는 골프회원권의 형태와 관련하여 문제가 있는 것이다.

나. 우선 사단법인회원제의 경우에는 공익법인의 사원의 지위와 밀접하게 결부되어 있고, 정관에서 지분의 양도를 인정하고 있는 경우 이외에 일반적인 양도성을 가지지 않으므로 원칙적으로 집행적격이 인정되지 않는다.⁶¹³⁾

예탁금회원제 골프회원권은 골프장과 부대시설을 클럽의 규칙에 따라 우선적으로 이용할 수 있는 권리, 예탁금반환청구권 등의 권리와 연회비납입 등의 의무를 포괄하는 일종의 계약상의 지위라고 해석된다. 일반적으로 골프클럽의 정관이나 회칙에서 회원권을 예탁금의 반환청구권과 함께 양도할 수 있다고 규정하는 경우가 많고, 실제 골프클럽이 발행한 입회보증금의 예탁금증서를 배서, 교부하는 등의 방법으로 자유롭게 거래되고 있다.

따라서 주주회원제나 예탁금회원제의 경우에는 회칙 등에서 양도, 상속이 부정되고 있는 것은 집행적격이 인정되지 않지만,⁶¹⁴⁾ 일반적으로 양도성이 인정되고 있으며

612) 藤井英男, 古賀猛敏 共著, ゴルフクラブ會員權の基礎知識, 5, 이하

613) 大石忠生, 岡田潤, 黒田直行 編, 裁判實務大系(7), 靑林書院社(昭和62), 440.

614) 주주회원제 골프회원권의 경우, 주식은 상법 제335조 제1항에 의해 양도성이 긍정되이기 때문에 회원권의 양도성이 부정되어 있더라도 주식(주권이 발행되어 있는 경우에는 주권, 주권미발행의 경우는 그 밖의 재산권으로서의 주주권)의 압류는 가능하다.

로 집행적력을 인정할 수 있다고 본다.⁶¹⁵⁾

이러한 경우에 양도에 관해서 이사회의 승인을 필요로 하는 경우가 많은데, 양도성 그 자체는 부정되어 있지 아니하고 또한 이사회의 승인도 현실적으로 비교적 완화되어 있는 것이 많은 것으로 보인다.

그런데 주주회원제 회원권의 경우에는 주권에 대한 압류도 함께 하지 않으면 집행의 실효를 거둘 수 없게 되는 사정 등에 비추어 집행의 대상으로서 예탁금회원제 골프회원권의 쪽이 간편하고, 예탁금회원제 골프회원권이 압도적으로 많으므로 실무에서 집행신청되는 것은 대부분 이와 같은 예탁금회원제 골프회원권이다.

다. 한편 골프회원권은 그 밖의 재산권에 대한 집행의 대상이 되지만, 회원이 탈퇴할 때 행사할 수 있는 정지조건부 채권인 예탁금반환청구권에 대하여 금전채권에 대한 집행의 방법 즉 압류 및 전부명령을 받는 방법으로도 집행할 수 있다.⁶¹⁶⁾

615) 대법원 1989. 11. 10. 선고 88다카19606 판결【판결요지】[1] 피고회사에 의하여 운영되는 컨트리클럽의 골프개인회원권은 입회희망자가 피고회사 이사회의 입회승인을 얻어 입회금을 납입함으로써 취득하게 되며 재산적 가치를 갖는 계약상의 지위로서 자유로이 양도할 수 있으나 그 회칙상 회원자격심사위원회의 심의와 이사회의 승인을 얻은 후 소정의 수수료를 납부하도록 되어 있다면, 그 회원권의 양수인이 위 이사회의 승인을 얻지 못한 단계에서는 그 회원권 양도양수계약은 계약당사자 사이에서만 효력이 있을 뿐 피고회사나 제3자에 대한 관계에서는 양수인이 아직 회원으로서의 지위를 취득하지 못하여 여전히 양도인이 회원권자라고 할 수 밖에 없고, 그 양도인의 채권자는 양도인이 보유하는 회원권이나 또는 회원으로서의 지위에서 피고회사에 대하여 가지는 입회금반환청구권을 가압류할 수 있을 것이며 그 가압류 후에는 그 회원권의 양수인이 피고회사 이사회의 승인을 얻어 회원의 지위를 취득하였더라도 위 가압류 채권자에 대해서는 그 회원권 취득의 효력을 주장할 수 없다. [2] 골프회원권은 민사소송법 제584조 소정의 강제집행방법에 의한 집행대상이 되지만 회원이 퇴회할 때 행사할 수 있는 정지조건부 채권인 예치금반환청구권에 대하여 압류 및 전부명령을 받는 방법으로 집행할 수도 있다. [3] 골프클럽회원의 회원가입계약 해지권이 일신전속적인 권리가 아니고 그 해지(탈퇴)에 특별한 제약이 없는 것인 이상, 입회금반환청구권은 비록 입회금반환사유가 발생할 것을 정지조건으로 하는 채권이라 할지라도 그에 대한 압류 및 전부명령이 제3자인 골프장운영회사에게 송달된 때에 채권자가 집행법원을 통하여 제3자에게 채무자를 대위하여 회원가입계약 해지권을 행사한 것이라고 볼 수 있으므로 입회금반환 사유는 그 송달시에 이미 발생하였다고 볼 것이다. ; 대법원 2010. 7. 26.자 2010마651 결정

616) 대법원 1989. 11. 10. 선고 88다카19606 판결【판결요지】[1] 피고회사에 의하여 운영되는 컨트리클럽의 골프개인회원권은 입회희망자가 피고회사 이사회의 입회승인을 얻어 입회금을 납입함으로써 취득하게 되며 재산적 가치를 갖는 계약상의 지위로서 자유로이 양도할 수 있으나 그 회칙상 회원자격심사위원회의 심의와 이사회의 승인을 얻은 후 소정의 수수료를 납부하도록 되어 있다면, 그 회원권의 양수인이 위 이사회의 승인을 얻지 못한 단계에서는 그 회원권 양도양수계약은 계약당사자 사이에서만 효력이 있을 뿐 피고회사나 제3자에 대한 관계에서는 양수인이 아직 회원으로서의 지위를 취득하지 못하여 여전히 양도인이 회원권자라고 할 수 밖에 없고, 그 양도인의 채권자는 양도인이 보유하는 회원권이나 또는 회원으로서의 지위에서 피고회사에 대하여 가지는 입회금반환청구권을 가압류할 수 있을 것이며 그 가압류 후에는 그 회원권의 양수인이 피고회사 이사회의 승인을 얻어 회원의 지위를 취득하였더라도 위 가압류채권자에 대해서는 그 회원권 취득의 효력을 주장할 수 없다. [2] 골프회원권은 민사소송법 제584조 소정의 강제집행방법에 의한 집행대상이 되지만 회원이 퇴회할 때 행사할 수 있는 정지조건부 채권인 예치금반환청구권에 대하여

그러나 골프회원권은 당초의 예약금에 비하여 고액으로 거래되고 있는 것이 보통이므로 예약금반환청구권에 대하여 금전채권으로 집행하는 것은 적당한 집행방법이 아닌 경우가 많고, 학설에서는 일종의 계약상 지위의 내용의 일부에 불과한 예약금반환청구권만에 대한 압류는 골프회원권의 재산적 가치를 파괴하는 것으로서 채무자가 탈퇴하거나 골프장이 폐쇄되어 있는 등의 특별한 사정이 있는 경우에만 허용된다는 견해도 주장되고 있다.⁶¹⁷⁾

라. 또한 골프회원권의 내용 중 플레이권의 경우에는 이를 골프회원권과 별개로 양도할 수 없고, 독립하여 재산적 가치를 가지는 것은 아니므로 이것만을 대상으로 한 압류는 허용되지 않는다.⁶¹⁸⁾

이하에서는 실무집행의 대부분을 차지하고 있는 예약금제회원권을 중심으로 검토하기로 한다.

4. 골프회원권의 압류

가. 신청

1) 예약금제의 회원권은 시설의 우선적 이용권, 예약금반환청구권이나 연회비지불의무 등의 각종의 권리의무를 포괄한 회원계약상의 지위이고, 회원권을 구성하는 각종의 권리의무는 어느 것이나 채권이다.⁶¹⁹⁾ 따라서 예약금제회원권은 부동산, 선박, 동산, 채권 이외의 그 밖의 재산권으로서 강제집행을 하게 되어 원칙적으로 채권집행의 예에 따른다.^{620) 621)}

압류 및 전부명령을 받는 방법으로 집행할 수도 있다. [3] 골프클럽회원의 회원가입계약 해지권이 일신전속적인 권리가 아니고 그 해지(탈퇴)에 특별한 제약이 없는 것인 이상, 입회금반환청구권은 비록 입회금반환사유가 발생할 것을 정지조건으로 하는 채권이라 할지라도 그에 대한 압류 및 전부명령이 제3자인 골프장운영회사에게 송달된 때에 채권자가 집행법원을 통하여 제3자에게 채무자를 대위하여 회원가입계약 해지권을 행사한 것이라고 볼 수 있으므로 입회금반환 사유는 그 송달 시에 이미 발생하였다고 볼 것이다.

617) 中野貞一郎, 위 民事執行法(下), 587.; 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(7), 25-26.

618) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(7), 25.

619) 앞서 본 대법원 1989. 11. 10. 선고 88다카19606 판결은 골프회원권이 민사집행법 제251조 소정의 강제집행방법에 의한 집행대상임을 명시적으로 인정하고 있고, 아울러 위 판결은 골프회원권에 대하여는 회원이 퇴회할 때 행사할 수 있는 정지조건부채권인 예치금반환청구권에 대하여 압류 및 전부명령을 받는 방법으로 집행할 수 있다고 하였다.

620) 이에 대하여, 예약금증서를 유가증권이라고 해석하는 견해에서는 이 예약금증서는 배서에 의하여 이전되게 되므로 민사집행법상은 동산집행의 방법으로 집행되게 된다(須藤正彦, 民事執行法下のゴルフ會員權の押留, 金融法務事情 第901号, 13.).

621) 별지서식 [3-19] 가압류로부터 본압류로 이전하는 골프회원권 압류 및 현금화명령과 [3-21] 골프회원권 현금화명령신청 등 참조(제3장 말미 수록)

2) 그 밖의 재산권으로서 회원권을 압류하는 절차는, 1차적으로 채무자(회원)의 주소지를 관할하는 지방법원, 그것이 없는 때에는 제3채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원을 관할법원으로 하여 위 법원에 압류명령신청서를 제출하여 한다.

압류명령신청서에 기재하여야 할 사항은 채권자, 채무자(회원), 제3채무자(시설경영회사)⁶²²⁾ 등의 표시, 집행권원의 표시, 압류목적물인 회원권을 특정함에 족한 사항의 표시 등이다(민집규 제159조 제1항). 또한 신청서에는 강제집행의 목적인 재산으로서 골프회원권을 표시하여야 하는데, 그 특정방법으로는 골프장의 명칭, 등록자의 이름, 회원번호, 예탁금액 등을 기재하여야 한다.⁶²³⁾

예탁금회원제의 회원권에 대한 압류의 효력은 당연히 예탁금반환청구권에도 미친다고 해석하여야 하는데,⁶²⁴⁾ 이론(異論)이 있을 수 있으므로 예탁금반환청구권도 대상으로 제기하는 것이 바람직할 것이다.⁶²⁵⁾ 마찬가지로 주주회원제의 회원권에 대한 압류의 경우는 주식도 그 대상으로 제기하여야 한다.⁶²⁶⁾

3) 압류하여야 할 재산권에 제3채무자 또는 이에 준하는 자가 있는 경우는 압류명령은 채무자 이외에 그 제3채무자등에도 송달되어야 하고, 제3채무자에의 송달시에 그 효력이 생긴다. 골프회원권의 경우는 골프장경영자가 여기서 말하는 제3채무자에 해당된다고 할 수 있다.⁶²⁷⁾

4) 압류목적물의 특징은 회원권의 명칭, 회원번호, 예탁금 액면금액을 기재하여 특정하게 된다. 그러나 이와 같이 상세한 특정방법을 요구하면 채권자가 채무자의 예탁금증서라도 보지 않는 한, 회원번호나 예탁금액을 아는 것이 불가능하므로 실제상 집행이 불가능하게 된다.

압류목적물의 특징을 요구하는 것은 채무자(회원)과 제3채무자(시설경영회사) 사이에서 다른 회원권과 식별할 수 있는 것이 목적이므로 이러한 식별이 가능할 정도의 특징이면 족할 것이다. 통상은 동성(同姓)·동명(同名)·동주소(同住所)의 회원이 있는 경우가 거의 없고, 회원권은 1개이므로 채무자의 표시가 되어 있는 이상 회원권의 특

622) 이 경우 제3채무자는 골프클럽이 아니라 골프장을 경영하는 회사가 되어야 하는 점에 유의하여야 한다.

623) 예컨대 “채무자가 제3채무자 경영의 ○○컨트리클럽에 대하여 가지는 개인정회원권(회원증번호)”의 방식이 될 것이다.

624) 鹽崎勤(주589), 698.

625) 이 경우는 예컨대 “채무자가 제3채무자로부터 제명되거나 회원계약을 해제당한 때 채무자가 제3채무자로부터 반환받을 예탁금반환청구권”의 방식이 될 것이다.

626) 大石忠生 外(주613), 441.

627) 鹽崎勤(주589), 698.

정으로서는 회원권의 명칭(예컨대, ○○컨트리클럽의 개인회원권이라는 명칭)으로도 가능하다고 본다.⁶²⁸⁾

5) 압류명령신청서의 첨부서류로는 집행력 있는 집행권원의 정본 기타 일반적인 서류 외에 회원권의 양도성을 증명하기 위하여 회칙이나 시세표 등을 첨부하는 것이 좋다. 다만 양도에 시설경영회사의 승인을 요하는 경우에도 압류에는 이러한 시설경영회사의 양도승인은 필요하지 않으므로 시설경영회사의 승낙서 등 첨부는 요구되지 않는다.

나. 압류명령

적법한 형식을 갖춘 신청이 있으면 집행법원은 채무자, 제3채무자를 심문하지 않고 채권자가 특정한 회원권이 존재하는 것으로 회원권의 압류명령을 발령한다.

위 압류명령에는 제3채무자에 대하여 채무자에 대한 예탁금의 반환이나(예탁금회원제의 경우), 회원권양도의 승낙 또는 명의개서를 금지(주로 주주회원제의 경우)하는 내용을 적어야 하는데, 그 주문례는 다음과 같다.

채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지목록 기재의 골프회원권을 압류한다.
제3채무자는 위 골프회원권에 대하여 양도를 승낙하거나 채무자의 신청으로 예탁금의 반환 또는 명의개서 그 밖의 일체의 변경절차를 하여서는 아니 된다.
채무자는 위 골프회원권에 대하여 예탁금의 반환을 청구를 하거나, 매매·양도·그 밖의 처분 행위를 하여서는 아니 된다.

사단법인회원제의 경우에 그 지분의 양도가 허용되는 경우에는 사원의 지분에 대한 압류의 방식으로 하여야 할 것이다. 그리하여, 그 주문은 다음과 같이 적는다.

채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 지분을 압류한다.
제3채무자는 채무자에 대하여 이익금의 배당, 지분의 환급, 잔여재산의 분배를 하여서는 아니 된다.
채무자는 위 지분을 추심하거나 기타의 방법으로 처분하여서는 아니 된다.

압류명령은 채무자와 제3채무자에게 송달하여야 하고, 제3채무자에 대한 송달로써 압류의 효력이 생긴다. 골프회원권 처분금지가처분결정의 송달 이후 실시된 가압류 등 보전처분 또는 그에 기한 강제집행은 그 가처분의 처분금지효력에 반하는 범위 내에서는 가처분채권자에게 대항할 수 없다.⁶²⁹⁾

628) 홍광식(주572), 313.

629) 대법원 2009. 12. 24. 선고 2008다10884 판결; 대법원 2009. 12. 24.자 2007마184 결정 등

집행법원은 압류명령의 송달과 함께 제3채무자에 대하여 채무자가 회원이 아닌 경우에는 그 취지, 회원인 경우에는 회원권에 압류나 체납처분 등의 경합이 있는지 여부나 체납회비 여부 등을 회답하여 줄 것을 최고하여 그 후의 집행절차에 참고하는 것이 바람직하다. 정관이나 규칙이 제출되어 있지 않은 경우에는 그 송부도 촉탁하고 회원권 양도절차 등도 조회할 수 있다.

위 압류명령에 위반한 채무자의 행위는 압류채권자에 대항할 수 없게 된다. 다만 채무자는 회원권을 압류하더라도 시설의 우선적 이용권의 행사가 금지되지 않으므로 그 시설을 이용하는 것이 가능하다. 또한 압류에 의하여 회원권은 소멸되지 않고 다른 사람에게 이전되는 것도 아니므로 채무자(회원)는 연회비지불의무를 면하지 못한다.

제3채무자는 압류명령에 위반하여 회원을 퇴회(退會)시켜 예탁금을 반환하더라도 채권자에게 대항할 수 없으므로 가 경우 채권자의 추심 등에 대하여 이중지불의 문제가 생길 수 있는 반면, 채무자(회원)에게 시설이용을 시키는 것에는 문제가 없고, 또한 채무자(회원)에게 연회비의 체납 등의 제명, 회원계약해제사유가 있는 경우는 회원을 제명하거나, 회원계약을 해제하는 것이 방해되지 않는다.

회원권의 압류 후에 채무자(회원)가 제명되거나 회원계약이 해제되거나 하면 회원권의 가치는 예탁금반환청구권의 액까지 하락하게 되므로 채권자로서는 이를 방지하도록 노력할 필요가 있는데, 제3채무자인 시설경영회사는 채무자(회원)를 제명하거나 회원계약을 해제함에는 미리 압류채권자에게 통지할 필요는 없으므로 이를 미연에 방지하는 것은 곤란하다. 다만 연회비등의 금전채무에 대하여는 채권자가 이를 대위변제할 수 있다.

압류채권자는 예탁금증서의 인도를 채무자에게 청구할 수 있고, 채무자가 이에 응하지 않는 경우는 동산인도의 강제집행의 방법에 의하여 증서의 인도를 받을 수 있다(민집 제234조).⁶³⁰⁾

5. 골프회원권의 현금화

그 밖의 재산권에 대한 집행은 채권집행의 예에 의한다고 되어 있다(민집 제251조 참조).

630) 예탁금증서는 유가증권이 아니고 또 현금화절차에 반드시 필요한 것이 아니나, 예탁금증서가 없으면 현금화에 의하여 회원권을 취득한 자가 시설경영회사로부터 명의개서(양도승인)를 받는데 있어 실제상 곤란하게 되므로 예탁금증서의 인도를 받아 두는 것이 좋다.

채권집행의 경우는 금전채권에 대한 집행이 일반적이고, 금전집행의 경우의 현금 화절차는 압류채권자의 추심이나 전부명령이 통상의 현금화방법인데, 예탁금제회원권은 회원계약상의 지위이고 금전채권이 아니므로 그 성질상 압류채권자의 추심이나 전부명령과는 친숙하지 않다. 예탁금제회원권의 현금화절차는 거의 예외 없이 양도명령, 매각명령에 의하고 있는 실정이다.

가. 양도명령

회원권의 양도명령은 회원권을 집행법원이 정한 가격으로 집행채권과 집행비용의 지급에 갈음하여 압류채권자에게 양도하는 명령이다.

이는 압류목적물을 집행채권의 대물변제로서 집행채권자에게 이전하는 명령으로서 전부명령과 유사한 것이다. 이러한 양도명령은 압류채권자에게 우선적 만족을 얻게 하는 제도이므로 다른 사람으로부터의 압류나 배당요구가 있는 경우는 발령될 수 없다. 시설경영회사에 의한 사전의 양도승인은 양도명령의 요건이 아니다.⁶³¹⁾

양도명령의 신청이 있으면 집행법원은 채무자를 심문하고, 통상은 평가인을 선임하여 회원권을 평가시킨 다음 평가액이 집행채권과 집행비용의 액을 초과하는 경우는 그 초과액을 채권자로 하여금 납부하게 한 후 그에게 양도명령을 발령한다.

위 양도명령은 확정되지 않으면 그 효력이 생기지 않고, 양도명령이 확정되면 회원권이 채권자에게 이전됨과 동시에 집행채권과 집행비용은 양도 전액의 한도에서 변제된 것으로 되어 소멸한다. 이때 양도명령의 주문은 다음과 같다.

위 당사자간 ○○지방법원 20 타채 골프회원권압류명령에 의하여 압류된 별지목록 기재의 골프회원권을 금 ○○○원으로 지급에 갈음하여 채권자에게 양도한다.

위에서 본 대로 양도명령에 대해 시설경영회사에 의한 사전의 양도승인이 요구되지 않으므로 양도명령에 의한 회원권의 이전을 가지고 당연히 그 시설경영회사에 대항할 수 있는 것은 아니다. 시설경영회사는 이 이전을 승인하는가 아닌가는 회원권 양도의 경우와 동일하게 보면 될 것이다. 따라서 시설경영회사의 승인을 받지 못할

631) 日東京高決 昭和 60(1985), 8, 15.(判例タイムズ 578号) 참조

위험은 압류채권자가 인수해야 한다.⁶³²⁾

나. 매각명령

매각명령은 압류목적물을 그 추심에 대신하여 집행법원이 정한 방법에 의하여 그 매각을 집행관에게 명하는 명령이다.

매각명령은 양도명령의 경우와 달리 압류가 경합된 경우나 배당요구가 있는 경우에도 발령할 수 있으므로 압류가 경합되거나 배당요구가 있는 경우 회원권의 현금화는 매각명령에 의하는 수밖에 없다. 채무자의 심문, 회원권의 평가는 양도명령의 경우와 같다.

집행법원은 매각명령의 요건이 있는 때에는 매각의 방법을 정하여 집행관에 대하여 그 회원권의 매각을 명한다.

매각의 방법은 입찰, 경매, 특별매각 등의 방법이 있을 수 있는데, 실무에서는 「동산집행의 매각의 방법에 의하여 매각하는 것을 명한다」라고 포괄적으로 정하는 것이 일반적이고, 집행관은 그 가운데 입찰의 방법으로 매각하는 것이 대부분이다. 회원권의 매수신청에도 시설경영회사에 의한 사전의 양도승인은 필요하지 않다.

이 경우 매각명령의 주문은 아래와 같다.

632) 한편 이에 대해 우리 판례는 대법원 1990. 12. 11. 선고 90다카25253 판결은, “골프장 및 부대시설을 이용할 수 있는 권리자들로 모집 구성된 골프클럽의 업무도 골프장을 운영하는 피고 주식회사의 영업에 관한 것이라고 보아야 할 것인바, 회사의 업무에 관하여 포괄적 대표권을 가진 대표이사가 설사 대표권에 터잡지 아니하고 원고에게 입회를 권유하고 입회금을 받은 다음 회원증을 발급하였다고 하더라도 골프클럽의 입회절차나 자격요건은 회사 내부의 준칙에 지나지 아니한다고 할 것이므로 거래상대방인 원고가 이를 알았거나 알 수 있었다는 특별한 사정이 없는 한 그 거래행위는 유효하여 원고는 회원자격을 취득한 것이라고 보아야 할 것이고, 또한 원고로서는 피고회사의 대표이사의 권유를 받고 소정의 입회금을 납부한 후 피고회사 대표이사 명의로 된 영수증과 회원증 등을 교부받은 이상 특별한 사정이 없는 한 내부절차는 피고회사가 다 마쳤으리라고 신뢰하였다고 보는 것이 경험법칙에도 합치된다.”이라고 판시한 반면, 대법원 1989. 11. 10. 선고 88다카19606 판결은, “피고회사에 의하여 운영되는 컨트리클럽의 골프개인회원권은 입회희망자가 피고회사 이사회의 입회승인을 얻어 입회금을 납입함으로써 취득하게 되며 재산적 가치를 갖는 계약상의 지위로서 자유로이 양도할 수 있으나 그 회칙상 회원자격심사위원회의 심의와 이사회의 승인을 얻은 후 소정의 수수료를 납부하도록 되어 있다면, 그 회원권의 양수인이 위 이사회의 승인을 얻지 못한 단계에서는 그 회원권 양도양수계약은 계약당사자 사이에서만 효력이 있을 뿐 피고회사나 제3자에 대한 관계에서는 양수인이 아직 회원으로서의 지위를 취득하지 못하여 여전히 양도인이 회원권자라고 할 수밖에 없고, 그 양도인의 채권자는 양도인이 소유하는 회원권이나 또는 회원으로서의 지위에서 피고회사에 대하여 가지는 입회금반환청구권을 가압류할 수 있을 것이며 그 가압류 후에는 그 회원권의 양수인이 피고회사 이사회의 승인을 얻어 회원의 지위를 취득하였더라도 위 가압류채권자에 대해서는 그 회원권 취득의 효력을 주장할 수 없다.”이라고 판시함으로써 약간은 상반된 취지의 결론을 내리고 있다.

위 당사자간 ○○지방법원 20 타채 골프회원권압류명령에 의하여 압류된 별지목록 기재의 골프회원권을 매각할 것을 명한다.

채권자의 위임을 받은 집행관은 유체동산 매각에 관한 절차에 따라 매각하여야 한다.

매각절차가 완료되면 집행관은 매득금을 집행법원에 제출하고, 매득금이 제출되면 배당절차가 개시된다(민집 제252조 제3호). 회원권의 매각절차에 의하여 매수인이 당연히 시설경영회사로부터 양도승인을 받게 되는 것은 아니라는 점은 양도명령의 경우와 같다.

다. 회원권의 평가

양도명령, 매각명령의 어느 경우에도 골프회원권 등의 평가를 하여야 한다. 경제신문에 시세표가 게재되어 있는 경우에는 그 금액에 의거할 수 있는데, 업자가 골프잡지나 스포츠신문 등의 광고란에 게재한 시세는 반드시 객관성을 가지지 않으므로 신뢰할 수 있는 업자에게 직접 문의할 필요가 있다.

시세표가 없는 회원권에 대한 평가는 상당히 곤란하지만, 당해 골프장경영회사에 직접 과거의 거래사례를 묻거나 신뢰할 수 있는 업자에게 조회하는 등의 방법에 의하는 수밖에 없을 것이다.

라. 예탁금반환청구권에 대한 추심전부

회원권의 집행을 개시하였는데, 채무자(회원)가 시설경영회사로부터 제명되거나 회원계약을 해제당한 경우는 예탁금반환청구권만이 잔존하고(이행기가 도래한다), 기타의 권리의무는 소멸하게 된다.

이 경우는 예탁금반환청구권의 압류의 효력은 금전채권인 예탁금반환청구권에 미치므로 압류채권자는 예탁금의 추심이 가능하게 되고, 예탁금반환청구권에 대해 전부명령을 얻는 것도 가능하다.⁶³³⁾

또한 회원권을 압류한 자에 대한 명의개서정지기간 중에 해당하고, 회원권의 시세가 예탁금의 액보다 가치가 낮은 등의 이유로 양도명령이나 매각명령에 비하여 예탁금을 추심하는 쪽이 경제적 가치가 있는 경우에는, 압류채권자는 압류에 기초하여 추심명령을 얻어 회원계약을 해제(退會)하는 것도 고려할 수 있다. 이 경우도 예탁금의 추심이 가능하다.

633) 東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 471.

6. 예탁금제회원권 이외의 회원권에 대한 집행방법

예탁금제 이외의 회원권은 강제집행의 방법상 문제가 있어서 실무상 그 집행의 예가 거의 없다. 아래에서 이를 간단히 보기로 한다.

먼저, 사단법인제 회원권 중 정관에서 일반적인 양도를 인정하고 있는 것은 강제집행의 대상으로 되고, 또 이 경우 회원권은 사단법인의 사원권과 같으므로 집행법상은 예탁금제회원권의 경우와 같이 그 밖의 재산권으로서 강제집행이 가능하며, 그 방법 또한 예탁금제회원권의 경우와 같다. 다만 사단법인제회원권에는 예탁금반환청구권이 없으므로 예탁금의 추심이라는 문제는 생기지 않는다.

다음으로, 주주제회원권의 경우에는 통상 회원에 대해 주권이 발행되는데, 이 경우 주권은 회원권을 구성하는 주주권을 표창하는 유가증권이다. 이러한 주주제회원권의 집행방법에 관하여는, 주권에 대한 집행으로서 동산집행에 의한다는 견해, 주권에 대한 집행은 동산집행에 의하고 주주권 이외의 권리에 관하여는 그 밖의 재산권으로서 양 절차를 일체적인 것으로 집행을 개시한 다음 현금화절차는 일체로서 양도명령 등의 현금화명령에 의해야 한다는 견해, 주주권을 포함하는 회원권 전체를 그 밖의 재산권으로 하나의 집행절차에서 행하고 주권은 채권증서의 인도의 예에 의한다는 견해 등이 있으나, 이러한 견해들은 모두 실체법상·절차법상의 장·단점을 가지고 있는데, 이 경우 실제상 주권을 발견하지 않으면 집행이 불가능하게 될 가능성을 가지고 있는 것이어서 이에 의한 집행은 거의 행해지지 않고 있는 실정이다.

7. 스포츠센터회원권, 콘도회원권에 대한 집행

스포츠센터회원권이나 콘도회원권 등의 경우도 골프회원권과 마찬가지로 여러 가지 형태가 있으므로 그 종류에 따라서 골프회원권에 대한 집행방법에 준하여 생각하면 될 것이다.

VI. 주권발행 전의 주식, 신주인수권에 대한 집행

1. 서

주권이 발행된 경우에 주식의 양도는 무기명주식이든 기명주식이든 주권의 교부를 필요로 한다(상법 제336조 제1항).

이 경우에는 주주의 권리가 주권에 화체(化體)되어 있고, 주권의 교부에 의해 주

식을 양도받은 양수인은 주권을 회사에 제시하여 단독으로 명의개서를 청구할 수 있어서 원칙적으로 유체동산인 주권 자체가 집행의 대상이 되므로 유체동산집행의 방법으로(민집 제189조 제2항 제3호) 현금화하게 된다.⁶³⁴⁾

주권이 발행되지 아니한 주식의 경우, 회사성립 후 또는 신주납입기일 후 6개월이 경과하기 전과 그 후에 따라 주식 양도의 효력이 달라지므로(상법 제335조 제3항 단서), 그 집행방법에도 차이가 있다.

2. 주권발행 전의 주식에 대한 집행

가. 6개월 경과 전의 주식

회사성립 후 또는 신주의 납입기일 후 6개월이 경과하기 전에는 주권발행 전의 주식의 양도가 회사에 대하여 효력이 없으므로(상법 제335조 제2항), 주식 자체를 압류·현금화하는 집행은 불가능하고, 이때에는 채무자가 회사에 대하여 가지는 주권교부청구권을 집행의 대상으로 삼을 수밖에 없다.⁶³⁵⁾ ⁶³⁶⁾

이 경우의 주문례는 다음과 같다.

채무자의 제3채무자에 대한 별지 목록 기재 주권교부청구권을 압류한다.
 제3채무자는 채무자에 대하여 위 주권을 교부하여서는 아니 된다.
 채무자는 위 청구권의 추심 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.
 제3채무자는 위 주권을 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
 채권자는 그가 위임하는 집행관으로 하여금 위 주권교부청구권을 추심하게 할 수 있다.

주권교부청구권에 대한 강제집행은 유체동산인도청구권에 대한 강제집행의 예에 따른다(민집 제251조 제1항, 제242조, 제243조).

즉 채권자는 주권교부청구권에 대하여 집행법원의 압류명령을 받은 후, 회사가 주권을 발행하면 그 압류명령에 부가되거나 따로 발령된 인도명령(민집 제243조 제1항)에 의하여 주주인 채무자의 주권을 회사로부터 채권자가 위임하는 집행관이 인도 받아 유체동산현금화의 방법으로 환가하여 그 매각대금을 집행법원에 제출하면 그로

634) 별지서식 [3-26] 주권압류 및 현금화명령신청 참조(제3장 말미 수록)

635) 대법원 1974. 12. 28.자 73마332 결정 【결정요지】주권발행 전 주식에 관한 권리에 대한 강제 집행은 민사소송법 제584조 제1항의 규정에 의하여 같은 법 제575조 및 제576조의 규정을 준용 하여 채무자인 주주가 회사에 대하여 가지는 주권교부청구권을 압류한 후 회사가 주권을 발행하면 채무자인 주주의 주권을 채권자의 위임받은 집달리에게 인도할 것을 명하여 이를 환가하는 방법에 의하여야 한다.

636) 별지서식 [3-25] 주권교부청구권 압류명령신청 참조(제3장 말미 수록)

부터 만족을 얻게 된다.

회사가 주권을 발행하지 않으면 채권자는 추심명령을 얻어 추심소송을 제기할 수 있다 할 것이나, 주권을 발행하라는 취지의 확정판결이 있더라도 이는 직접강제 또는 대체집행을 할 수 없는 성질의 판결이 되므로 회사가 끝내 거부하면 민사집행법 제261조에 의한 손해배상금으로 채권의 만족을 얻을 수밖에 없을 것이다.

나. 6개월 경과 후의 주식

회사성립 후 또는 신주의 납입기일 후 6개월이 경과한 후에는 주권이 발행되지 아니한 주식도 양도할 수 있게 되므로 이때에는 주식 자체를 압류목적물로 하여⁶³⁷⁾ 집행법원으로부터 압류명령을 받고 그에 대한 양도명령, 매각명령 등 특별현금화방법의 결정을 받아 현금화하면 된다.⁶³⁸⁾

이 경우 주문례는 아래와 같다(주권발행 후의 주식에 대한 경우와 마찬가지로).

채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지 목록 기재 주식을 압류한다.

제3채무자는 위 주식에 대하여 채무자의 청구에 의하여 명의개서를 하거나 채무자에게 주권을 교부하여서는 아니 된다.

채무자는 위 주식에 대하여 매매, 양도, 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.

3. 신주인수권에 대한 집행

신주인수권 중 구체적 신주인수권, 즉 실제 신주가 발행되어 그 신주를 청약하고 배정받을 수 있는 권리는 독립된 채권적 권리로서 이론상 양도가 가능하다.

그러나 정관의 규정으로 또는 이사회가 신주발행사항의 하나로서 주주가 가지는 신주인수권을 양도할 수 있는 것에 관한 사항을 정할 수 있으므로(상법 제416조 제5호), 주주가 가지는 신주인수권에 대하여 정관이나 이사회 결의로 양도를 허용한 경우에 신주인수권은 집행의 대상이 된다.

신주인수권의 양도가 가능한 경우에는 회사는 신주인수권증서를 발행하여야 하고(상법 제420조의2), 이 경우 신주인수권증서는 신주인수권을 표창하는 유가증권이므로 주권이 발행된 경우 주식에 대한 집행의 경우와 같이 원칙적으로 유가증권집행의 방법에 의하여 집행하게 된다.

신주인수권증서를 압류·보관 중 주식납입기일이 도래한 경우에는 집행관은 그 보

637) 권광중, “주식에 대한 강제집행”, 회사법의 제문제(上), 재판자료 제37집, 236-238.

638) 대법원 2011. 5. 6.자 2011그37 결정

관의무로서 주식납입금의 불입을 하는 경우도 있다(그 대금은 보관에 필요한 비용에 해당한다).⁶³⁹⁾

신주인수권증서가 발행되지 아니한 경우에는 집행법원은 신주인수권증서 교부청구권을 압류하고 집행관이 신주인수권증서를 교부받아 이를 현금화할 수 있는 등 주권발행 전 주식에 대한 집행의 예에 의하여 집행할 수 있다.

정관이나 이사회 결의로 주주의 신주인수권 양도에 관하여 아무런 정함을 하지 아니하거나 그 양도를 금지한 때의 주주의 신주인수권 및 제3자의 신주인수권은 회사에 대하여는 양도성이 없어도 주주 또는 제3자의 재산권으로 책임재산을 구성하므로 그 밖의 재산권에 대한 집행의 방법으로 집행할 수 있다고 보아야 할 것이다.

이 경우 현금화는 추심명령에 준하여 채권자에게 채무자를 대신하여 주식인수절차를 완결할 수 있는 권한을 부여함으로써 행하게 된다.

Ⅶ. 사원 또는 민법상 조합원의 지분 등에 대한 집행

1. 서

사원의 지분은 사원의 신분상의 권리를 동반하는 동시에 한편 사원이 그 법인에 대하여 출자를 이행하고 이익, 배당을 청구하며 잔여재산의 분배를 청구하는 등 재산상의 권리, 의무의 주체로서의 지위를 가지는 것이므로 재산상의 가치를 가지고, 이를 현금화하여 금전화하는 것이 가능하므로 강제집행의 대상이 된다.

합명, 합자회사의 사원의 지분에 대하여 상법은 압류의 절차를 규정하고 있고(상법 제223조, 제269조), 유한회사 사원의 지분권을 압류한 채권자는 양도명령, 매각명령 등에 의하여 지분의 현금화를 구할 수 있다(유한회사 사원의 지분의 양도에 관하여는 종래 일정한 제한이 있었으나, 2011. 4. 14. 법률 제10600호로 상법이 개정되어 이러한 제한규정이 철폐되었다).⁶⁴⁰⁾

그리고 민법상 조합계약에 기초한 조합원의 지분에 대하여는 조합원이 조합재산에 가지는 지분을 집행의 대상으로 하는 것은 공동목적을 수행하는 수단인 조합재산으로서의 의미를 잃게 하므로 허용되지 않고, 지분을 조합원으로서의 지위로 파악하여 이에 대하여 집행하는 것도 일신전속적인 권리에 대한 집행으로서 허용되지 않지만,

639) 김능환·민일영 편집대표, 위 주식민사집행법[V], 678.

640) 대법원 2004. 7. 5.자 2004마463 결정

장래 발생하는 각종의 지분권을 현금화하거나 탈퇴로 인한 지분환급청구권을 대상으로 하는 것으로서 지분에 대한 압류를 인정한다(민법 제714조).

2. 합명회사, 합자회사의 사원의 지분에 대한 집행

가. 압류절차

1) 사원의 지분권에 대한 압류절차는 민사집행법 제251조 제1항에 따라 민사집행법 제227조, 제241조를 준용하여 이루어진다. 신청서에는 채권에 대한 압류명령의 신청과 마찬가지로(민집규 제159조).

이 재산권에 대하여는 제3채무자가 있으므로 압류할 지분의 특징은 “채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지 기재의 지분(무한책임인가, 유한책임인가를 구별하여)을 압류한다.”는 방식으로 표시하여야 한다.

2) 압류의 효력은 제3채무자에게 송달된 때에 생기고(이 경우 제3채무자는 다른 사원이라는 설도 있으나 회사라고 해석해야 한다⁶⁴¹⁾), 압류에 의하여 채무자인 사원은 지분의 양도, 질권설정 등의 처분을 할 수 없게 된다.

사원 지분의 압류는 사원의 장래 이익의 배당 및 지분환급청구권에도 그 효력이 미치고(상법 제223조), 그 밖에 해산한 경우에 생기는 사원의 잔여재산분배청구권에도 미친다.

이러한 청구권은 구체적으로 발생할 때까지 액수가 정해져 있지 않으므로 액수가 정해질 때까지 추심할 수 없고, 전부명령의 방법도 취할 수 없다. 즉 압류채권자는 이익배당, 지분환급청구권 등이 구체화되어 그 행사를 할 수 있는 시기가 도래할 때마다 그 채권에 대한 추심명령이나 전부명령을 얻어 채권의 만족을 얻을 수 있다.⁶⁴²⁾

3) 그 밖에 압류채권자는 영업연도 말에 당해 사원을 강제로 퇴사시킬 수 있다(상법 제224조 제1항). 이것은 압류채권자가 그 사원의 지분 자체를 집행법원으로부터 양도명령 또는 매각명령 등 특별현금화결정을 얻어 현금화할 수도 있으나, 사원의 지분의 양도에 대하여는 다른 사원의 동의를 요하기 때문에(상법 제197조), 동의가 있었다는 증명을 제출하기 전에는 위와 같은 현금화절차를 진행할 수 없고 지분을 압류하더라도 사실상 이를 현금화하는 것은 거의 불가능에 가까우므로 압류채권자에게

641) 홍광식(주572), 353.

642) 홍광식(주572), 353.

사원을 퇴사시키는 권리를 인정하는 것이며, 채무자가 퇴사함으로써 생기는 그 사원이 갖는 지분환급청구권으로부터 만족을 얻을 수 있다.

퇴사청구권의 행사는 압류채권자가 당해 법인에 대한 퇴사의 일방적 의사표시(형성권)를 함으로써 퇴사의 효력이 생긴다. 이 퇴사청구권은 일정기간(6월) 전에 회사 및 그 사원에게 예고하여야 한다.

이 경우 압류명령의 주문은 다음과 같다.

채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지 기재의 지분(권)을 압류한다.
제3채무자는 채무자에게 위 지분에 관하여 이익금의 배당 및 지분의 환급을 하여서는 아니 된다.
채무자는 위 지분을 추심하거나 그 밖의 방법으로 처분하여서는 아니 된다.

4) 합자회사에 대하여는 합명회사에 관한 규정이 광범위하게 준용되므로 합자회사사원의 지분 집행에 대하여도 합명회사의 경우와 다를 바 없다. 다만 지분을 특정함에 있어서 유한책임사원의 지분인지 무한책임사원의 지분인지를 구별하여 표시하여야 한다.

나. 현금화절차

사원의 지분권은 그 성질에 따라서 적당한 방법으로 현금화한다(민집 제251조 제1항, 제241조).

사원 지분권의 현금화는 그 밖의 재산권의 현금화방법과 약간 다르다. 즉 사원의 지분권의 양도에는 총사원(합자회사에서 유한책임사원의 지분의 경우에는 무한책임사원 전부)의 승낙이 없는 때에는 타인에게 양도할 수 없으므로(상법 제197조, 제276조), 신청서에는 이 요건을 인정할 수 있는 승낙서(동의서)를 붙여야 한다.

위 승낙서를 얻지 않으면 그 압류는 단순히 처분금지의 효과만 생긴다. 이익배당청구권, 지분환급청구권, 잔여재산분배청구권에 대하여는 지분권의 압류에 따라 그 효력이 법률의 규정에 의하여 당연히 생기므로 이러한 청구권에 관해서 다시 압류명령을 받을 필요는 없고, 압류채권자는 개개의 구체적인 각 청구권에 대하여 추심 또는 전부명령을 신청하여 채권의 만족을 얻을 수 있다.

3. 유한회사사원의 지분

유한회사사원의 지분권을 압류한 채권자는 양도명령, 매각명령 등에 의하여 지분의 현금화를 구할 수 있다.

사원은 그 지분의 전부 또는 일부를 양도하거나 상속할 수 있다. 다만 정관으로 지분의 양도를 제한할 수 있으므로(상법 제556조), 집행법원으로서 정관에 이러한 제한이 있는지 여부를 확인한 후에 양도명령 등을 발하여야 한다.

4. 민법상 조합에서 조합원의 지분에 대한 집행

가. 민법상 조합에 있어서 조합원이 조합재산에 대하여 가지는 지분을 집행의 대상으로 하는 것은 공동목적의 수행하는 수단인 조합재산으로서의 의미를 잃게 하므로 허용되지 않고,⁶⁴³⁾ 그 지분을 조합원으로서의 지위로 파악하여 이에 대하여 집행하는 것도 일신전속적인 권리에 대한 집행으로서 허용되지 않음이 원칙이다. 그러나 민법은 장래 발생하는 각종의 지분권을 현금화하거나 탈퇴로 인한 지분환급청구권을 대상으로 하여 그 지분에 대한 압류를 허용하고 있다(민법 제714조 참조).

여기서 조합원의 지분이란 전체로서의 조합재산에 대한 조합원 지분을 의미하는 것이고, 이와 달리 조합재산을 구성하는 개개의 재산에 대한 합유지분에 대하여는 압류 기타 강제집행의 대상으로 삼을 수 없다.⁶⁴⁴⁾

나. 민법상 조합의 조합원 지분에 대한 압류는 다른 조합원 전원을 제3채무자로 하여야 한다. 압류의 효력은 조합원의 장래의 이익배당청구권, 지분반환청구권, 잔여재산분배청구권에 대하여 미친다.

압류채권자는 집행법원으로부터 추심명령에 준하는 수권을 얻거나 채권자대위권에 의하여 집행채무자에 갈음하여 탈퇴의 의사표시를 한 다음에 지분반환청구권에 대하여 추심을 하거나 또는 전부명령 등에 의하여 현금화할 수 있다.

다. 조합의 지분은 다른 조합원의 승낙이 없는 한 양도할 수 없으므로(민법 제704조, 제272조) 원칙적으로 지분 그 자체를 현금화할 수 없으나, 조합원의 지위양도가 조합계약에서 허용되고 있는 경우 또는 다른 조합원 전원이 양도를 승낙하고 있는 경우에는 압류된 지분 자체의 양도명령, 매각명령 등의 특별한 현금화방법에 따라 현금화할 수도 있을 것이다.

라. 실무상 건설공동수급체의 공사대금채권에 대하여 개별 구성원의 채권자로부터 압류집행이 종종 행해지고 있으나, 이때 공동수급체가 민법상 조합을 이루는 경우

643) 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다68924 판결 참조

644) 대법원 2007. 11. 30.자 2005마1130 결정 참조

에는 조합원 중 1인을 집행채무자로 하여 조합재산인 공사대금채권에 대하여 행해진 압류는 채무자 소유 아닌 제3자 소유의 재산을 대상으로 한 것으로서 당연무효이다.⁶⁴⁵⁾

그런데 채권자가 압류신청 이유에 제3채무자 사이의 공동수급체 관계를 설명할 뿐 아니라 압류할 채권에 관계된 계약서를 제출하는 경우가 있는바, 이러한 경우에는 공사대금채권의 기본원인이 공동이행방식인지 분담이행방식인지를 검토하여 결정할 필요가 있다.

판례는 공동이행방식인 경우에 대하여는 공동수급인 사이에 민법상 조합의 법률관계가 있다고 보는 것이 기본입장으로 보인다.⁶⁴⁶⁾ 또한 도급인이 공동도급계약 운영요령에 따라 공사대금채권을 공동수급체 구성원 각자에게 지급하고 공동수급체가 그와 같은 지급방식에 따라 그 대금을 수령한 사정만으로 조합 구성원 사이에 민법규정을 배제하려는 의사가 표시되어 있다는 등 특별한 사정이 있었다고 할 수는 없으므로 공사대금채권은 조합원에게 합유적으로 귀속되는 조합채권으로서 조합원 중 1인이 조합의 채무자에 대하여 출자비용에 따른 급부를 청구할 수 없다고 한다.⁶⁴⁷⁾

반면 공동수급방식에 의한 도급계약이라도 분담이행방식이 채택된 경우에는 공동수급이 사이의 관계를 민법상 조합으로 보지 않고 도급인과 수급인 사이의 개별적인 도급계약관계가 있는 것으로 봄이 타당할 것이다.⁶⁴⁸⁾

645) 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다68924 판결

646) 대법원 1997. 8. 26. 선고 97다4401 판결; 대법원 2000. 12. 12. 선고 99다49620 판결(공동수급체는 기본적으로 민법상의 조합의 성질을 가지는 것이므로 그 구성원의 일방이 공동수급체의 대표자로서 업무집행자의 지위에 있었다고 한다면 그 구성원들 사이에는 민법상의 조합에 있어서 조합의 업무집행자와 조합원의 관계에 있다는 취지로 판시); 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다68924 판결(수급인인 6개 회사가 공동협정서에 터잡아 상호 출자하여 신축공사 관련사업을 공동으로 시행하기로 하는 내용을 약정한 경우 그들 사이에는 민법상 조합이 성립하므로, 세무서장이 조합의 구성원인 1개 회사의 부가가치세 체납을 이유로 6개 회사의 조합재산인 공사대금 채권에 대하여 압류처분을 한 것은 체납자 아닌 제3자 소유의 재산을 대상으로 한 것으로서 당연무효라고 본 사례)

647) 대법원 2000. 11. 24. 선고 2000다32482 판결

648) 윤재운, 건설분쟁관계법, 박영사(2003), 287-288.; 대법원 1998. 10. 2. 선고 98다33888 판결【판결요지】공동수급인이 분담이행방식에 의한 계약을 체결한 경우에는 공사의 성질상 어느 구성원의 분담 부분 공사가 지체됨으로써 타 구성원의 분담 부분 공사도 지체될 수밖에 없는 경우라도, 특별한 사정이 없는 한, 공사 지체를 직접 야기한 구성원만 분담 부분에 한하여 지체상금의 납부의무를 부담한다.

VIII. 출자증권에 대한 집행

1. 서

건설산업기본법상의 건설공제조합, 전기공사공제조합법상의 전기공사공제조합의 조합원에게 발행된 출자증권은 위 각 조합의 출자지분을 표창하는 유가증권이다.

따라서 이들 조합의 조합원 출자지분은 출자증권을 압류하는 방법으로 하고, 그로부터 파생되는 채권, 예컨대 출자한 금원의 반환청구권만을 압류할 수는 없다.

2. 압류절차

출자증권은 조합원인 채무자가 직접 점유하고 있는 경우는 거의 없고, 대부분 조합에 질권이 설정되어 조합이 점유하고 있기 때문에 조합을 제3채무자로 하여 압류명령을 발령한다.

출자증권의 압류에 관하여 건설산업기본법 제59조 제4항, 전기공사공제조합법 제11조 제4항은 출자증권의 압류는 민사집행법 제233조에 의한 배서금지 지시채권의 압류방법에 의하여 압류한다고 규정하고 있으므로 출자증권에 대한 압류는 집행관이 위 출자증권을 점유함으로써 효력이 생긴다.⁶⁴⁹⁾ ⁶⁵⁰⁾ 그리하여 예컨대 출자증권에 대하여 채권자 甲, 乙, 丙이 압류명령을 발령받았더라도 집행관이 위 출자증권을 점유하지 않고 있는 동안에는 위 모든 압류의 효력은 발생하지 않으나, 위 채권자 중 1인 甲이 이를 현금화기 위한 매각명령을 발령받음에 따라 제3채무자인 조합이(질권을 행사하지 않거나 또는 질권행사 범위를 넘는 것에 관하여) 집행관에게 출자증권을 내어줌으로써 집행관이 이를 점유하게 되었다면 그때까지 압류명령을 발령받은 甲, 乙, 丙의 모든 압류의 효력은 이때 발생하게 된다.

이 경우 압류명령의 주문례는 다음과 같다.

채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지 기재 출자증권에 기한 조합원지분을 압류한다. 제3채무자는 채무자에게 위 지분에 관하여 이익금의 배당, 출자금의 반환, 잔여재산의 분배를 하여서는 아니 된다.

채권자의 위임을 받은 집행관은 채무자로부터 위 출자증권을 빼앗아 보관하여야 한다.

649) 대법원 1987. 1. 20. 선고 86다카1456 판결【판결요지】건설공제조합의 조합원의 출자지분은 유가증권인 출자증권에 표상되는 것이므로 국세징수법에 의한 압류는 동법 제38조에 의하여 세무 공무원이 출자증권을 점유함으로써 효력이 생긴다.

650) 별지서식 [3-27] 출자증권압류 및 인도명령신청 참조(제3장 말미 수록)

☞ 실무상 조합이 출자증권에 대하여 질권을 설정함으로써 제3채무자 겸 질권자의 지위에 있는 경우에는 주문 중 제3항을, “채권자의 위임을 받은 집행관은 제3채무자로부터 위 출자증권을 빼앗아(수취하여) 보관하여야 한다.”라고 표시해야 한다는 견해가 있으나, 이러한 견해는 다음과 같은 이유로 타당하지 않다고 본다.

즉 여기서 말하는 출자증권은 집행법상 동산에 해당하는바, 다만 그 압류에 관하여 건설산업기본법 제59조 제4항과 전기공사공제조합법 제11조 제4항이 민사집행법 제233조에 의한 배서금지 지시채권의 압류방법에 의하여 압류한다고 규정하고 있으므로 출자증권에 대한 가압류는 집행관이 위 출자증권을 점유해야만 효력이 생기게 된다(앞서 본 대법원 1987. 1. 20. 선고 86다카1456 판결 참조).

이 부분 설명을 위해 동산 중 일반 유체동산 인도청구권에 대한 집행의 예를 하나 들기로 한다. 예컨대, 乙이 丙에 대하여 유체동산에 관한 인도청구권을 가지고 있는데, 乙의 채권자 甲이 집행권원을 얻어 乙이 丙에 대하여 가지는 인도청구권을 압류하였다고 하자. 이러한 인도청구권 압류집행에 있어서 당초 유체동산의 「점유」는 바로 丙이 하고 있는 것이다. 그리고 甲이 위 인도청구권을 압류한다는 위 압류명령의 내용에는 ① 제3채무자의 채무자에 대한 인도금지, ② 채무자의 처분과 영수 금지, ③ 유체동산의 집행관에 대한 인도명령을 포함하는 것으로 되어 있다.

여기서 주의할 것은, 甲이 乙에 대해 집행권원을 얻었다고 해서 곧바로 점유자이자 제3채무자인 丙에게 그 동산을 「수취」할 수 있는 것은 아니라는 점이다. 「수취」란 목적물을 “빼앗아” 채권자가 원하는 쪽으로 점유를 옮기는 집행방법의 일종을 말하는데, 甲이 丙에 대하여 그럴 권한이 없는 것이다. 또 위 압류명령에 대하여 제3채무자인 丙은 위 甲에 대하여 임의로 목적물을 인도할 의무가 없고, 또 수취당할 이유도 없다. 따라서 위 인도명령이 포함된 압류명령에도 불구하고 제3채무자가 임의로 목적물을 인도하지 않을 경우 채권자인 甲은 다시 집행법원에 대해 추심명령을 신청해야 한다(민집 제243조 제2항). 그러나 나아가 甲이 추심명령을 얻는다고 해도 甲이 丙으로부터 유체동산을 「수취」할 수 있는 것은 아니며, 이 경우도 丙이 임의로 목적물을 인도하지 않으면 집행불능으로 될 수밖에 없고, 결국에는 위 추심명령을 기초로 직접 丙에 대하여 집행권원을 얻기 위해 甲은 추심의 소를 제기하여 승소한 다음 그 丙에 대한 집행권원을 가지고서야 비

로소 민사집행법 제257조에 따라 丙으로부터 이를 “빼앗아” 채권자에게 인도할 수가 있게 되는 것이다(이 때에야 제3채무자인 丙은 비로소 甲에 대해 채무자의 지위에 서게 되므로 甲이 그로부터 점유를 “빼앗을 수” 있게 되는 것임).

그런데 출자증권은 집행법상 동산에 해당되지만, 민사집행법 제189조 제2항이 규정하는 유체동산은 아니다. 즉 민사집행법 제189조 제2항 제3호는 “유가증권으로서 배서가 금지되지 아니한 것”을 유체동산으로 규정하고 있는데, 위 출자증권은 순수한 증거증권에 해당하므로,⁶⁵¹⁾ 위와 같은 유가증권이 아니어서 결국 위 규정이 정하는 유체동산은 아닌 것이다. 그리하여 위 출자증권은 민사집행법 제234조가 정하는 바에 따라 채권압류 후 강제집행의 방법으로 집행관이 그 증서를 인도받을 수 있을 뿐인바, 여기서 민사집행법 제234조가 정하는 “강제집행의 방법”이란 민사집행법 제257조 이하에서 정하는 집행의 방법을 말하므로 먼저 “채무자가 특정한 동산이나 대체물의 일정한 수량을 인도하여야 할 때에는 집행관은 이를 채무자로부터 빼앗아 채권자에게 인도하여야” 한다. 그리고 만일 인도할 물건을 제3자가 점유하고 있는 때에는 채권자의 신청에 따라 금전채권의 압류에 관한 규정에 의해 채무자의 제3자에 대한 인도청구권을 채권자에게 넘겨야 한다(민집 제259조).

이와 같이 인도청구권을 넘기는 방법은, 집행법원에 신청하여 금전채권의 압류에 관한 규정에 따라 제3자에 대한 채무자의 인도청구권을 압류하고 이를 채권자에게 넘기는 명령(移付命令)을 발령받으면 되고(민집규 제190조), 이러한 이부명령(移付命令)이 있는 경우에 만일 제3자가 채권자의 강제집행에 협력하여 임의로 채권자에게 인도하면 그로써 강제집행이 종료되나, 그렇지 않고 제3자가 채권의 인도청구에 불응한 때에는 채권자는 제3자를 상대로 추심의 소인 목적물 인도청구소송을 제기한 후 그 승소판결을 집행권원으로 하여 강제집행을 하면 될 것이다.

위와 같은 검토에 따르면, 집행법상 동산의 경우 채권자가 채무자의 제3채무자(또는 제3자)에 대한 인도청구권을 압류하였다 하더라도 그 압류명령(혹은 가압류명령)의 효력에 기해 직접 제3채무자로부터 그 동산을 수취할 권리는 없다는 결론에 이르게 된다.

이제 위에서 본 우리의 예로 돌아와서 보기로 하면, 건설산업기본법상의 건설공

651) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 132. 참조

제조합, 전기공사공제조합법상의 전기공사공제조합이 조합원에게 발행된 출자증권은 위 각 조합의 출자지분을 표창하는 유가증권을 말한다.

우선, 이 경우 조합이 위 출자증권에 대해 질권을 설정하여 점유하고 있는 것이 아닌 때를 가정하여 살펴보기로 한다(이 경우도 甲을 채권자, 乙을 채무자, 丙을 조합이라는 예를 들기로 함).

조합에 의해 질권이 설정되어 있는 않는 경우라면 위 출자증권에 기한 조합원지분의 「점유」는 바로 채무자인 乙에게 있다고 보아야 할 것이다. 따라서 이 경우 위 출자증권을 가압류 또는 압류한다면, 그 주문에는 ① 제3채무자의 지분에 관한 이익금 배당, 출자금 반환, 잔여재산 분배 금지, ② 채권자의 위임을 받은 집행관이 채무자로부터 위 출자증권을 수취하여 보관할 것 등의 내용이 포함되게 되며, 이 경우에는 점유가 있는 집행채무자 乙로부터 집행권원을 가진 甲의 압류 명령에 기해 점유를 「수취」하는 것이 가능하다고 할 수 있다.

그런데 이제 조합이 乙이 자신에게 가지고 있는 출자증권에 기한 조합원지분에 대해 질권을 설정한 경우를 생각해본다면, 질권의 경우 점유가 또한 효력발생요건이므로 질권이 제대로 설정되었다면 위 지분에 대한 乙의 점유는 조합인 丙에게 이전되고 만다. 乙이 점유를 빼앗기고 조합인 丙이 「점유」를 하게 되는 것이다(이와 같이 질권에 기해 위 출자증권을 점유하게 된 조합은 채권자에 대해 제3채무자적인 지위에 있게 됨). 이러한 경우에 일반적으로 甲이 乙에 대한 집행권원에 기해 丙으로부터 출자증권을 「수취」할 수 있는 것인가. 설사 이 경우 乙이 丙에 대하여 인도청구권을 갖고 있더라도 위에서 이미 자세히 살펴본 것과 같이 甲이 乙에 대한 집행권원만을 가지고 丙에 대하여 출자증권을 수취할 방법은 없으며, 또한 이 경우는 乙이 丙에 대하여 인도청구권을 가지고 있지도 않으므로 더욱 안된다고 보아야 한다.

이런 상황인데도, 앞서 보듯이 출자증권에 대한 압류는 배서금지시채권과 같이 점유를 해야만 효력이 생긴다는 것이 판례(위 대법원 1987. 1. 20. 선고 86다카1456 판결)의 입장인바, 위에서 살펴본 내용을 어떻게 하면 위 판레이론과 조화롭게 해석될 수 있도록 할 것인가. 이는 위와 같이 丙에게 점유가 옮겨진 상황에서는 甲이 丙에 대해 직접 출자증권을 수취하거나 혹은 집행관에게 수취하도록 할 수 없을 뿐만 아니라, 채무자인 乙에게는 아예 점유가 있지도 아니한데 어떻게 출자증권에 대한 가압류나 압류가 행해지고 있는 것인가에 대한 이유를 확인

해보면 되리라 생각한다.

그 이유는 바로 여기에 있다고 보면 될 것이다. 즉 위와 같이 조합이 채무자의 출자증권에 대해 질권을 설정하고 그 점유를 가지고 있더라도 그 질권이 가압류의 집행기간 내에 효력을 상실할 수도 있고, 혹은 질권자가 질권을 포기하고 그 점유를 채무자에게 넘길 수가 있기 때문에 이에 대한 가압류는 그 실익이 있는 것이다. 또 집행기간이 정해지지 않은 압류의 경우에는 가압류의 경우보다 더 오래도록 위와 같은 실익을 가지고 있게 된다(실무상 보면, 어떤 경우에는 아무 것도 바라지 않고 무조건 압류해달라고 떼를 쓰는 신청인이 있는데, 이는 출자증권 압류에 대해 조합 스스로 질권을 포기하고 채권자의 압류명령에 응하는 사례가 종종 있기 때문이다).

다시 말해, 언제든지 선행 질권이 실효하고 그 점유가 채무자에게 복귀할 것을 기대하면서 위와 같은 가압류 또는 압류의 신청행위가 행해진다는 것이다. 그래서 이는 어쩌면 선행 질권의 실효를 조건으로 가압류 혹은 압류를 하고 있다고도 볼 수 있을 것이다. 그때에 위 가압류나 압류에 기해 채권자에게 점유를 「수취」, 즉 “빼앗길 수” 있는 사람은 채무자인 乙이지, 질권 설정에 기한 점유로 인해 제3채무자의 지위에 서게 된 조합이 아닌 것이다.

따라서 위에서 본 주문례는 조합이 그 지분에 질권을 설정하여 점유하고 있는 경우에도 동일하게 적용되는 것으로 보아야 한다. 즉 마지막 주문은 “채권자의 위임을 받은 집행관은 채무자로부터 위 출자증권을 수취하여(빼앗아) 보관하여야 한다.”라고 되어야지, 이것을 “채권자의 위임을 받은 집행관은 제3채무자로부터 위 출자증권을 수취하여 보관하여야 한다.”라고 하면 안 된다 할 것이다.

한편 위 출자증권을 채무자가 아닌 제3자가 점유하고 있는 경우에는 채권자는 채무자가 제3자에 대하여 가지는 동산인 출자증권의 인도청구권을 (가)압류하는 방법으로 압류집행을 할 수 있다(민집 제242조, 제243조).⁶⁵²⁾

3. 현금화절차

가. 현금화명령의 신청이 있는 경우에는 제3채무자에게, ① 채무자가 조합원인 여부 ② 조합원이라면 출자증권계좌수, 출자증권번호, 1계좌당 금액은 얼마인지 ③

652) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016다35451 판결

채무자의 위 출자증권에 다른 제3자로부터 가압류, 압류, 체납처분에 의한 압류 등이 있는지 여부, 있다면 그 권리자 및 청구금액, ④ 질권의 설정 여부 등을 조회하여야 한다.

압류명령신청과 동시에 현금화명령신청이 있는 경우에는 압류명령을 발하면서 채권자에 의한 진술최고신청이 없더라도 위와 같은 조회를 할 수 있다.

나. 그런데 출자증권은 각 조합으로부터의 차입금을 담보하기 위하여 조합에 질권으로 제공되어 있고 질권의 피담보채권액도 출자증권의 출자가액을 초과하는 경우가 많다.

따라서 출자증권은 제3채무자인 조합이 집행관에게 인도하지도 않으므로 현금화 단계까지 나아가지 못하는 경우가 많고, 인도하더라도 질권자로서 배당요구를 하는 경우에는 질권자에게 우선배당하면 집행채권자에게 지급될 잔액이 없어 무잉여가 되는 경우가 많다.

집행관이 출자증권을 빼앗지 못하는 경우에는 현금화명령신청을 기각하는 것이 원칙일 것이나, 실무에서는 조합이 설정한 질권도 포기 등에 의해 효력이 소멸하거나 혹은 조합이 임의로 출자증권의 점유를 집행관에게 넘겨줄 수 있고, 또 그럴 경우에는 압류집행이 가능하게 될 여지가 있으므로 그러한 실익을 감안하여 집행관의 수취 여부와 관계없이 압류명령을 발해주고 있는 것으로 보인다. 다만 조합이 임의로 집행관에게 출자증권의 점유를 넘기더라도 다시 질권자로서 배당요구가 있는 경우에는 무잉여 여부를 조사하여, 무잉여인 때에는 민사집행법 제188조 제3항에 의하여 압류명령을 취소하고, 현금화명령신청 및 압류명령신청을 모두 기각하여야 할 것이다.

다. 출자증권에 대한 현금화는 민사집행법 제241조의 특별현금화절차에 의한 다.⁶⁵³⁾ 단, 건설산업기본법 제59조 제1항, 전기공사업제조합법 제11조 제1항에 의하면 조합원의 지분은 다른 조합원이나 조합원이 되려고 하는 자에게만 양도할 수 있고, 한편 조합원이 되려고 하는 자는 위 각 법에 의한 사업면허를 받은 자이어야 하므로 현금화로 인하여 출자증권을 취득하는 자는 이러한 요건을 갖춘 자이어야 한다.

653) 별지서식 [3-24] 전문건설공제조합 출자증권 양도명령신청 참조(제3장 말미 수록)

IX. 예탁증권등에 대한 집행

1. 집행의 기본구조(증권대체결제제도)

가. 증권대체결제제도의 의의

종래 주식을 양도하기 위해서는 주권의 교부를 요하는 것으로 되어 있었으나(상법 제336조 제1항, 제338조 제1항), 주식거래의 대량화에 따라서 주권의 보관과 교부의 사무량이 막대한 것이 되어 주권의 원활한 유통을 저해할 우려가 생김에 따라 주식 등 증권대체결제제도가 도입되게 되었다.

위와 같은 주식 등 증권대체결제(證券對替決済)제도는 주식 그 밖의 유가증권을 일정한 기관에 집중 보관하여 매매거래나 담보거래가 이루어지는 경우에 주식 등의 이전을 증권의 현실인도로 행하지 않고 장부상 계좌의 대체로 행하는 제도를 말한다. 이러한 증권대체결제업무를 전담하는 기관으로는 한국예탁결제원이 있고, 증권대체결제의 대상이 되는 것은 위 한국예탁결제원이 지정한다[자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’이라고 한다) 제308조]. 한국예탁결제원에 관하여는 자본시장법 제294조 이하에서 규율하고 있으며, 민사집행규칙 제2편 제3관에서 예탁증권등에 관한 강제집행에 관하여 필요한 사항을 정하고 있다(민집규 제176조부터 제182조).

나. 대체결제의 방법 등

1) 이 제도에 관련된 관계자로서는 ① 보관대체업무를 행하는 한국예탁결제원, ② 예탁자로서 관여하는 투자매매업자나 투자중개업자(이하 ‘투자매매업자 등’이라고 한다), 은행 등, ③ 고객으로서 이 제도를 이용하는 일반의 투자자 등 3자가 있다.

2) 증권의 대체결제는 증권의 소유자가 투자자로서 그 소유 증권을 투자매매업자 등(예탁자)에 예탁하고, 예탁자로부터 투자자계좌부를 개설받는다. 투자자계좌부에는 투자자의 성명과 주소, 예탁증권등의 종류 및 수와 그 발행인의 명칭 등이 기재된다(자본시장법 제310조 제1항).

예탁자는 투자자로부터 증권을 예탁받으면 이것을 한국예탁결제원에 예탁한다. 예탁자가 투자자로부터 예탁받은 증권에 자기소유 증권을 합하여 다시 한국예탁결제원에 예탁하는 때에는 투자자의 동의를 받아야 한다. 한국예탁결제원에는 예탁자별로

예탁자계좌부가 작성, 비치되어 있고, 이 계좌부에 그 예탁자로부터 한국예탁결제원에 예탁된 증권에 관하여 예탁자의 자기 소유분과 투자자예탁분을 구분하여 예탁자의 명칭 및 주소, 예탁받은 유가증권의 종류 및 수와 그 발행인의 명칭 등이 기재된다(자본시장법 제309조 제3항). 위 장부에 기재된 자는 그 증권을 점유하는 것으로 본다. 증권소유자는 투자매매업자 등의 투자자계좌부에, 투자매매업자 등은 한국예탁결제원의 예탁자계좌부에 각기 자기 계좌를 개설하면 예탁된 증권의 이전이나 담보권의 설정은 증권의 교부 없이 양도인의 계좌에서 양수인의 계좌로 대상이 된 증권을 대체하는 장부상의 기재만으로 이루어진다. 위 장부상의 대체 기재는 증권의 교부와 동일한 효력이 있다.

3) 투자자와 예탁자는 장부에 기재된 유가증권의 종류, 종목 및 수량에 따라 예탁증권등에 관한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다(자본시장법 제312조). 따라서 예탁증권등의 양도는 각 증권에 대한 권리가 아니라 공유지분을 양도하는 것이 된다.

4) 한국예탁결제원에 예탁된 예탁증권등에 대한 강제집행은 예탁된 증권의 공유지분(한국예탁결제원에 가지분으로 증권을 예탁한 예탁자, 또는 예탁자를 매개로 증권을 예탁한 투자자가 가지는 예탁결제원에 혼장상태(混藏狀態)로 보관되어 있는 증권의 공유지분, 자본시장법 제312조)에 대하여 그 밖의 재산권에 대한 집행방법에 따르는 것으로 되어 있고(민집규 제176조), 채권집행 등에 관한 규정의 대부분이 준용되고 있다(민집규 제182조).

2. 집행의 개시

가. 집행방법

민사집행규칙 제176조는, 자본시장법 제309조 제2항의 규정에 따라 예탁결제원에 예탁된 유가증권(자본시장법 제310 제4항의 규정에 따라 예탁결제원에 예탁된 것으로 보는 경우를 포함한다)에 대한 강제집행은 예탁증권등에 관한 공유지분에 대한 법원의 압류명령에 따라 개시한다고 규정하고 있다.

이것은 예탁증권등에 관한 예탁자 또는 투자자가 가지는 권리를 대상으로 하는 강제집행은 공유지분에 대한 강제집행, 즉 그 밖의 재산권에 대한 집행방법에 의해서 해야함을 명확히 한 것이다.

이는, 집행절차를 일원화시키는 것에 의해 다른 절차와의 혼란을 피하고 경합하는 압류채권자들 사이의 권리의 조정을 간명하게 하고자 한 것이다.

나. 집행의 대상

증권대체결제제도에 있어서 대체에 의한 권리이전의 대상으로 되는 것은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 예탁증권등의 공유지분이다.

주권의 경우 강제집행에 의한 압류의 대상으로 되는 것도 주식 또는 주식의 공유지분이 아니라 주권의 공유지분이다. 주권 이외의 증권인 경우에 있어서도 압류의 대상은 증권에 표창되어 있는 권리 또는 권리의 공유지분이 아니고 예탁되어 한국예탁결제원에 혼장상태(混藏狀態)로 보관되어 있는 증권의 공유지분이다.

다. 예탁증권 등 집행에 있어서 채무자

1) 예탁증권등에 대한 집행은, 증권대체결제제도에 있어서 장부의 기재에 의해 유가증권의 점유자라고 인정되는 자, 즉 위 제도에 있어서 공유지분을 가지는 예탁자 또는 투자자로서 예탁증권등의 공유지분권자라고 추정되고, 다른 계좌에의 대체를 청구하거나 또는 주권의 교부를 청구할 권리를 가지는 자를 집행채무자로 하는 강제집행절차이다. 다시 말해, 예탁증권등의 집행은 이러한 자가 자본시장법상 예탁증권등에 대하여 가지는 권리를 대상으로 한 강제집행의 절차를 정한 것이다.

한국예탁결제원에 예탁된 유가증권에 대하여 누가 공유지분을 가지는 예탁자 또는 투자자로서 권리를 가지는가는 오직 예탁자계좌부 또는 투자자 계좌부상의 명의를 의해 결정된다. 계좌부상의 명의인과 실질주주명부상의 실질주주가 다른 경우에도 계좌부상의 명의인을 채무자로 하여 공유지분의 압류를 한 후 예탁증권등 집행의 절차를 진행할 수 있다. 그리하여 계좌부상의 명의인 이외의 자가 당해 예탁증권등에 대한 진실한 권리자인 경우에는 위 강제집행을 배제하기 위해서는 제3자이의의 소를 제기하여 강제집행의 불허를 구해야 한다.

2) 신탁재산인 취지의 계좌부상의 기재가 있는 예탁증권등에 있어서는 수익자인 예탁자 또는 투자자를 채무자로 하여 당해 공유지분의 압류를 할 수 있다. 위탁자, 그 상속인, 수익자 또는 수탁자는 계좌부에 신탁재산인 기재가 되어 있고 진실로 신탁재산인 것을 이유로 하여 제3자이의의 소를 제기하여 강제집행의 불허를 구하여야 한다(신탁법 제22조 제2항).

3) 예탁증권등에 대하여 질권이 설정되어 있는 경우에는 계좌부(질권계좌부)의 기재에 의해 유가증권의 점유자로 간주되고 또 대체청구·주권등 유가증권의 교부청구를 할 수 있는 것은 질권자이나, 다른 한편 질권자는 어디까지나 질권을 가질 뿐

이고 공유지분을 가지는 자로 추정되는 것은 질권설정자이며, 또 피담보채권의 변제 등에 의해 질권이 소멸한 때에 예탁증권등이 다시 원상회복되는 질권설정자의 계좌는 반드시 존재한다. 채권·그 밖의 재산권에 대한 강제집행에 있어서는 일반적으로 질권이 설정되어 있는 재산권에 대하여도 강제집행에 의한 압류가 가능한 것으로 해석되고 있는데, 예탁증권등 집행에 있어서도 질권이 설정되어 있는 예탁증권등에 대하여 질권설정자를 채무자로 하는 압류를 하는 것이 가능하다고 볼 것이다.⁶⁵⁴⁾

다만 강제집행에 의한 압류로 인해 질권자의 권리를 해할 수 없으므로 집행법원이 한국예탁결제원 또는 예탁자로부터의 진술(민집규 제182조, 민집 제237조 제2항, 제3항)에 의해 질권이 설정되어 있는 것을 안 경우에는 질권의 소멸을 기다려 강제집행의 절차를 진행시켜야 할 것이다.

3. 압류명령

가. 서

집행법원이 예탁증권등지분을 압류한 때에는 채무자에 대하여는 계좌대체청구와 자본시장법 제310조 제2항의 규정에 따른 증권반환청구, 그 밖의 처분을 금지하고, 채무자가 자본시장법 제309조 제2항의 규정에 따른 예탁자인 경우에는 예탁결제원에 대하여, 채무자가 투자자인 경우에는 예탁자에 대하여 계좌대체와 증권의 반환을 금지하여야 한다(민집규 제177조).

위 규정은 민사집행규칙 제176조가 예탁증권등 집행은 예탁증권등에 대한 공유지분에 대하여 집행법원의 압류명령에 의해 개시한다고 규정하고 있는 것을 받아서 집행법원이 발하게 되는 압류명령의 내용을 정한 것이다.

나. 신청

1) 채권집행에 있어서와 동일하게 압류명령의 신청에 있어서는 강제집행의 목적물을 특정하는 것이 요구될 뿐이고 목적물의 존재에 대한 증명은 필요하지 않다.

2) 예탁증권등에 대하여 예탁자 또는 투자자가 가지는 공유지분은 당해 예탁증권등의 발행회사 및 그 종류마다에 1개의 권리라고 해석되고 있다(주권의 경우에는 주식의 발행회사·종류마다, 주권 이외의 유가증권에 있어서는 당해 유가증권에 표창된

654) 鹽崎勤(주589), 712-713.

권리의 발행회사·종류).

3) 압류명령의 신청서에는 채무자의 이름과 주소, 보관기관 또는 예탁자의 명칭과 소재지(예탁자가 채무자인 때에는 한국예탁결제원이, 투자자가 채무자인 때에는 예탁자가 제3채무자 내지 그에 준하는 자로서 취급된다), 당해 예탁증권등의 종류와 내용(주식수 등), 발행회사의 상호 등을 적어야 한다.

4) 압류명령에 있어서는 압류의 대상으로 되는 목적물을 특정하여 표시하여야 한다. 예탁증권등 집행은 채권집행과 같은 구조를 취하고, 집행법원은 압류명령을 발함에 있어서 압류목적물의 존부, 내용 등에 관하여 실질적 판단을 하지 않으므로 압류명령의 목적물 표시는 전적으로 압류명령의 신청서 기재에 의하게 된다.

목적물의 특정에 관하여, 증권대체결제제도에 있어서는 강제집행의 신청을 하려는 채권자가 계좌부를 열람하거나 계좌부 복사본의 교부를 청구할 수 없으므로 압류명령의 신청에 있어서 압류하여야 할 예탁증권등의 공유지분에 관하여 상세한 사항까지 명확히 하도록 하는 것은 채권자에게 불가능을 강요하는 것이 될 수 있다. 그렇지만 반면, 압류명령의 송달을 받은 대체결제기관 또는 예탁자가 압류명령의 대상으로 되는 공유지분에 관하여 그 존부 등을 판단할 수 있도록 하기 위해서는 신청의 단계에서 압류목적물의 표시로서 어느 정도 사항의 기재를 요구하는 것은 피할 수 없다. 위와 같은 사정에다가 현재 실시되고 있는 증권대체결제제도에서의 대체작업 구조 등을 고려한다면 지금 시점에 있어서 생각할 수 있는 압류목적물의 표시로서는 경우를 나누어 다음과 같은 정도를 요구할 수 있다 하겠다.

가) 압류하여야 할 예탁증권등의 종목이 특정될 수 있는 경우 : 이 경우의 목적물 및 한도로는 “채무자가 예탁자 ○○투자매매업자(○○지점취급)의 투자자로서 가진 아래 주식에 관계된 예탁주권에 관한 공유지분 가운데 다음의 순서에 따른 금 ○○○원에 이를 때까지”로 일응 기재하면 될 것이다.^{655) 656)}

나) 압류하여야 할 예탁증권등의 종목이 특정될 수 없는 경우 : 이 경우의 목적물 및 한도에 대하여는 “채무자가 예탁자 ○○투자매매업자(○○지점취급)의 투자자

655) 東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 442, 참조

656) 「1주의 가격은 압류명령 송달일 전날(그 날이 휴일인 경우에는 그 이전 가장 가까운 거래일)의 한국거래소(또는 한국금융투자협회중개시장)의 종가에 의하여 환산하는 것」으로 단서를 달아놓음이 적절하다. 또한 「압류된 예탁주권(유가증권)의 주식에 관하여 압류 후에 주식의 병합 또는 분할, 회사의 합병, 무상증자(주식배당) 등이 이루어져 새로이 주식이 발행된 때에는 그 새로이 발행된 주식을 대상으로 한 예탁주권도 압류의 대상으로 정하여 둬야 좋을 것이다.

로서 가진 주식에 관계된 예탁증권등에 관한 공유지분 가운데 다음의 순서⁶⁵⁷⁾에 따른 금 000원에 이르기까지”라고 기재하면 될 것이다.⁶⁵⁸⁾

5) 신청을 기각 내지 각하하는 재판에 대하여는 신청채권자가, 압류명령에 대하여는 채무자 및 한국예탁결제원 또는 예탁자가 각 즉시항고를 할 수 있다.(민집규 제182조, 민집 제227조 제4항).

다. 압류명령의 발령

1) 압류명령의 내용

가) 집행법원의 예탁증권등지분에 대한 압류명령에는, ① 채무자에 대하여 예탁증권등에 대한 계좌대체청구 또는 자본시장법 제312조 제2항에 따르는 증권반환의 청구 그 밖의 처분을 금지하고, ② 채무자가 예탁자인 경우에는 한국예탁결제원에 대하여, 채무자가 투자자인 경우에는 예탁자에 대하여 예탁증권등의 계좌대체와 증권반환을 금지하는 취지가 기재된다(민집규 제177조).

그 주문례와 압류할 예탁증권등의 기재례를 보면 다음과 같다.

[주문례]

채무자의 제3채무자에 대한 별지⁶⁵⁹⁾ 기재의 예탁증권등 공유지분을 압류한다.
채무자는 위 예탁증권등 공유지분에 대하여 계좌대체의 청구나 증권반환의 청구 및 그 밖의 일체의 처분행위를 하여서는 아니 된다.
제3채무자는 위 예탁증권 등 공유지분에 대하여 계좌대체를 하거나 채무자에게 이를 반환하여서는 아니 된다.

[압류할 예탁증권등의 기재례]

금 120,000,000원정

657) 압류의 순서를 정하는 방법으로 실무에서 사용하는 예는 대체로 다음과 같다.

「복수의 예탁주권(유가증권)이 있는 경우에는 다음의 순서에 의한다.

가. (1) 선행하는 ① 가처분의 집행 ② 체납처분에 의한 압류 ③ 담보권실행에 의한 압류 ④ 강제집행에 의한 압류 ⑤ 가압류의 집행 등이 없는 주식,

(2) 위 ①이 이루어지지 않은 주식(위 ② 내지 ⑤의 전부 또는 그 중 일부가 이루어진 주식, (3) 위 ①이 이루어진 주식

나. 종류를 달리하는 주식에 있을 때에는 다음의 순서에 의한다.

(1) 우선주 (2) 보통주」

658) 東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 442.

659) 이 경우 별지 기재에는 예탁증권등 공유지분이 표시될 것이다.

1. 압류할 목적물

채무자가 예탁자인 제3채무자의 투자자로서 가지는 다음 주식을 대상으로 하는 예탁계좌(계좌번호 : 0000000000)의 유가증권에 관한 공유지분 및 예수금반환청구채권

- 가. (1) ○○ 주식회사 보통주식
- (2) ◇◇ 주식회사 보통주식
- (3) ▲▲ 주식회사 보통주식

나. 위 가.항의 주식에 관하여 압류 후에 주식의 병합 또는 분할, 회사의 합병, 무상증자(주식배당), 유상증자 등이 이루어져 새로이 주식이 발행된 때에는 그 새로이 발행된 주식

다. 위 나.항의 주식에 관하여 다시 위 나.항에 든 사유에 의하여 새로이 주식이 발행된 때에는 그 새로이 발행된 주식

2. 압류의 한도

금 120,000,000원에 이를 때까지의 금액

다만 1주의 가격은 압류명령 송달일 전날(그 날이 휴일인 경우에는 그 이전 가장 가까운 거래일)의 증권거래소(또는 코스닥시장, 증권업협회중개시장)의 종가에 의하여 환산한다.

3. 압류의 순서

제1항의 예탁증권 중 선행하는 ① 가처분의 집행, ② 체납처분에 의한 압류, ③ 담보권 실행에 의한 압류, ④ 강제집행에 의한 압류, ⑤ 가압류의 집행 등이 이루어진 것이 있을 때에는 다음의 순서에 의한다.

- (1) 위 ① 내지 ⑤가 전혀 이루어지지 않은 주식
- (2) 위 ① 내지 ④가 이루어지지 않은 주식
- (3) 위 ① 내지 ③이 이루어지지 않은 주식
- (4) 위 ① 내지 ②가 이루어지지 않은 주식
- (5) 위(1) 내지(4) 이외의 주식

나) 압류채권자는 예탁결제원 또는 예탁자로 하여금 압류명령의 송달을 받은 날부터 1주 안에 서면으로 ① 압류명령에 표시된 계좌가 있는지 여부 ② 제1호의 계좌에 압류명령에 목적물로 표시된 예탁증권등지분이 있는지 여부 및 있다면 그 수량 ③ 위 예탁증권등지분에 관하여 압류채권자에 우선하는 권리를 가지는 사람이 있는 때에는 그 사람의 표시 및 그 권리의 종류와 우선하는 범위 ④ 위 예탁증권등지분에 관하여 다른 채권자로부터 압류·가압류 또는 가처분의 집행이 되어 있는지 여부 및 있다면 그 명령에 관한 사건의 표시·채권자의 표시·송달일과 그 집행의 범위 ⑤ 위 예탁증권등지분에 관하여 신탁재산인 뜻의 기재가 있는 때에는 그 사실 등을 진술하게 할 것을 법원에 신청할 수 있다(민집규 제178조).

다) 예탁자가 위 진술서에서 계좌의 명의인과 채무자의 동일성을 적극적으로 인

정하고 있는 경우에는 절차를 진행하게 되나 그 이외의 경우에는 압류채권자로부터 계좌의 명의인과 채무자의 동일성을 증명함에 족한 자료가 제출되지 않는 한 강제집행의 절차를 취소하여야 할 것이다.⁶⁶⁰⁾

라) 투자자가 가지는 공유지분에 관하여는 가령 동일한 발행회사 및 종류·종목의 유가증권에 관한 공유지분이라고 하여도 서로 다른 예탁자를 통하여 예탁한 것이라면 각각 별개의 권리라고 하여야 할 것이다. 또한 동일한 예탁자 중에서도 서로 다른 지점을 통하여 예탁한 경우에 예탁증권등의 공유지분이 예탁지점마다 각각 별개의 권리라고 하여야 할 것인가에 대하여는 증권거래의 실무상 개개의 지점마다 별개의 투자자계좌부를 비치하고 있으므로 은행에 대한 예금채권에 관한 강제집행에 있어서와 같이 별개의 권리로 취급하는 것이 나을 것이다. 그래서 강제집행의 목적물 특정을 위한 사항으로서 또한 송달장소로서 예탁을 행한 예탁자의 당해 지점명도 기재할 필요가 있다.

2) 일부 압류

가) 예탁증권등의 공유지분은 전술한 바와 같이 유가증권의 발행회사 및 종류마다 1개의 권리라고 해석되지만, 압류에 있어서는 그 전부를 압류하는 것도 가능하고 또 그 일부만을 압류하는 것도 가능하다.

나) 일부 압류를 한 경우에는 압류명령 목적물의 표시에 있어서 그 범위를 명확하게 해야 하는데, 압류해야 하는 범위를 명확하게 하는 방법으로서는 주권의 경우는 주식 수, 주권 이외의 유가증권의 경우에는 당해 권리의 수량적 내용[예컨대, 사채권(社債券)의 경우라면 사채권(社債券)의 액면 금액]을 표시하면 될 것이다.

다) 금전채권에 대한 강제집행에 있어서는 실무상 압류채권액을 청구채권액과 동액으로 하여 압류명령을 신청하는 것이 행해지고 있는데, 예탁증권등 집행에 있어서도 압류명령 신청서에 목적물의 표시를 청구채권 및 집행비용의 액에 상당하는 가액의 유가증권(주권의 경우 주식 수에 대한) 공유지분에 한정하는 식으로 할 수 있을 것이다. 또한 압류가 일부 경합한 경우의 효력에 대하여는 민사집행규칙 제188조 제1항에 의하여 민사집행법 제235조가 준용된다.

3) 초과압류의 금지

가) 채권집행과 동일하게 예탁증권등 집행에 있어서도 압류된 공유지분의 가액이 압류채권자의 채권 및 집행비용의 액을 초과한 때는 집행법원은 다른 공유지분을 더 압류하게 할 수 없다(민집규 제182조, 민집 제188조 제2항).

660) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 680.

나) 앞서 본대로 예탁주권의 공유지분에 관하여는 동일한 투자자계좌부에 기재된 예탁주권이라면 주식의 발행회사 및 종류마다 1개의 권리라고 해석되는데, 초과압류의 금지의 취지를 고려하면 채권집행에 있어서 예금 등 압류의 경우와 같이 압류의 목적물에 관하여 수량적인 한정을 하는 것이 상당하다. 그러나 예금 등의 금전채권과 달리 예탁증권등에 관하여는 현금화까지 사이의 주가의 변동을 고려하여야 한다.⁶⁶¹⁾

그리고 채무자인 투자자의 계좌부를 관리하는 참가자에 관하여 당해 투자자계좌부의 관리를 담당하는 지점명(취급하는 지점명)을 기재하는 것은, 이를 기재하는 것에 의하여 제3채무자에 준하는 자로서 압류명령의 송달을 받는 참가자가 빨리 채무자의 투자자계좌부를 검색하여 압류함으로써 처분제한 등에 필요한 조치를 취하는 것을 가능하게 하기 위한 것이다. 이는 채권집행에 있어서 은행예금에 대한 압류의 경우에 은행의 취급지점을 기재하는 것과 같은 취지이다.

4) 압류명령의 송달

가) 한국예탁결제원·예탁자의 지위

일반적으로 그 밖의 재산권에 대한 집행에 있어서 제3채무자 또는 이에 준하는 자는 채무자가 가지는 재산권에 대한 의무자 또는 그 재산권에 대하여 채무자 이외에 직접 이해관계를 가지는 자가 이에 해당한다고 해석되고 있다.⁶⁶²⁾

증권대체결제제도에 있어서는 예탁자가 가지는 권리에 대하여는 한국예탁결제원이, 투자자가 가지는 권리에 대하여는 예탁자가, 당해 권리에 관계된 계좌부를 관리하여 청구에 따라 대체 또는 주권등 유가증권의 반환을 청구할 지위에 있는 것이고, 채무자가 당해 재산권을 처분함에 있어서 그 협력이 불가결한 자라는 관점에서 보면, 예탁증권등 집행에 있어서는 한국예탁결제원 또는 예탁자가 제3채무자 또는 이것에

661) 이에 대하여, 현재의 증권금융실무에 있어서 주권을 담보로 차입하는 경우에 대개 주가의 7할 정도를 기준으로 담보가치를 평가하고 있음에 비추어 보면, 압류명령에 있어서는 압류채권자의 청구채권액의 1.5배 정도에 상당하는 예탁증권등을 압류목적물로 하여 취급하는 것이 상당할 것이라는 견해가 있고[홍광식(주572), 339.], 또 예탁증권등에 관하여 압류명령송달일 전날의 종치(終値)를 환산기준으로 하고 있다고 보이는바, 이는 직근시에 있어서의 시장가격이어서 환산기준으로서 가장 합리적이고 동시에 증권대체결제제도에 있어서 사무처리 시스템상으로도 이 환산기준으로 하는 것이 필요한 처리에 요하는 시간이 가장 짧고 신속한 대응이 가능하기 때문이라 한다[東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 438. 참조].

662) 유체동산 공유지분에 대한 강제집행에 있어서는, 채무자 이외의 다른 공유자 전원이 제3채무자에 준하는 자라고 해석되지만, 예탁증권등 집행에 있어서는 이 제도를 통하여 동종의 유가증권을 한국예탁결제원에 예탁하고 있는 전국의 예탁자 및 투자자를 다른 공유자라고 말할 수는 없으며, 이러한 자에 대하여 압류명령을 송달하는 것은 사실상 불가능하다. 또 증권대체결제제도상으로도 예탁증권등의 각 공유자는 다른 공유자가 가지는 공유지분이 처분되어도 자신의 권리에 대하여는 하등의 영향을 받지 않는 입장에 있는 것이어서 이러한 다른 공유자를 들어 채무자가 가지는 재산권에 대하여 직접 이해관계를 가지는 자라고 해석하기는 어렵다.

준하는 자의 지위에 있다고 볼 수 있다.

이에 따라 민사집행규칙 제182조는 예탁증권등 집행에 있어서는 한국예탁결제원 또는 예탁자를 제3채무자 또는 이것에 준하는 자로서 취급하고 있다.

나) 압류명령의 송달과 압류의 효력 발생

(1) 압류명령은 채무자 및 예탁결제원 또는 예탁자에게 송달하여야 한다(민집규 제182조 제1항, 민집 제227조 제2항).

여기서 「한국예탁결제원 또는 예탁자」라는 것은 예탁자가 채무자인 경우에는 한국예탁결제원에 대하여, 투자자가 채무자인 경우에는 채무자인 투자자의 계좌부를 관리하는 예탁자에 대하여 압류명령을 송달해야 한다는 취지이다(이하 설명에서도 같다).

(2) 압류의 효력은 압류명령이 한국예탁결제원 또는 예탁자에게 송달된 때에 발생한다(민집규 제182조 제1항, 민집 제227조 제3항).

(3) 그런데 예탁증권등의 공유지분에 대한 압류와 대체등에 의한 당해 공유지분의 양도 등의 우열은 어떻게 정할 것인가.

이에 대하여는, 압류명령의 한국예탁결제원 또는 예탁자에 대한 송달과 계좌부상의 대체기재와의 선후관계에 의해 결정하는 것이 타당하다고 본다.⁶⁶³⁾

그리하여, 양도인인 투자자가 증권대체결제제도 밖에서 다른 투자자와 예탁증권등의 양도를 합의하고, 예탁자에 대하여 양수인의 계좌에의 대체를 청구한 후 예탁자가 양도인의 투자자계좌부에서 감소의 기재를 하기 전에 양도인을 채무자로 하는 압류명령이 예탁자에게 송달된 경우에는 압류가 우선하는 것은 의심할 여지가 없다.

예탁증권등 공유지분 양도의 효력이 생기는 대체의 기재란 본래 양도인 계좌부의 감소 기재와 양수인 계좌부의 증가 기재 쌍방을 말하지만, 예탁자가 양도인의 투자자계좌부에 감소 기재를 한 후 압류명령이 송달된 경우에는 감소 기재에 의해 당해 예탁증권등은 양도인의 기재를 이탈하기 때문에 가령 양수인의 계좌부에 증가 기재가 되기 전이어도(예탁자를 달리하는 투자자에 대한 양도의 경우에는, 각 예탁자의 예탁자 계좌부의 감소 및 증가 기재 전이어도), 양도가 우선하고 압류는 목적물을 흡결하게 된다.⁶⁶⁴⁾

663) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(7), 136.

664) 채무자인 투자자가 A, B 등 다른 예탁자하에 있는 자기 계좌부에의 대체를 행한 경우에 있어서의 대체와 압류의 우열도 위와 동일하다[압류명령에 제3채무자에 준하는 자로서 기재되어 있는 예탁자 A가 아니라, 다른 예탁자 B의 투자자계좌에 대체되어버리면, 예탁자 A를 제3채무자로 한 압류명령은 목적물을 흡결하여 무위(無爲)로 된다].

(4) 질권계좌에의 대체에 의해 질권의 설정을 한 경우 질권설정과 압류의 우열도 위와 동일하다.

(5) 예탁증권등의 공유지분에 대한 압류와 주권등 유가증권의 반환에 의한 예탁관계의 종료와의 관계에 대하여도 압류명령의 한국예탁결제원 또는 예탁자에 대한 송달과 위 종료시와의 선후관계에 의한다.

그런데 주권등 유가증권의 반환에 의해 예탁관계가 종료하는 시기에 관하여, 예탁자가 자기 몫의 예탁증권등에 대해 한국예탁결제원으로부터 주권등 유가증권의 반환을 받은 경우에는 현실적으로 주권 등의 반환이 된 때에 예탁관계가 종료하는 것이 명확하지만, 투자자가 예탁한 예탁증권등에 관하여 예탁자에게 주권등 유가증권의 반환청구를 한 후 예탁자로부터 현실적으로 반환을 받기까지 사이에 투자자와 한국예탁결제원 사이의 예탁관계가 종료하고 투자자가 예탁증권등의 공유지분을 상실하여 개개의 특정 물로서의 주권등 유가증권에 대한 권리를 취득하는 것으로 되는지 여부는 명확하지 않고, 이 경우는 압류와 예탁관계의 종료와의 우열 판단에 관하여도 문제가 있다.

(6) 압류명령이 한국예탁결제원 또는 예탁자에게 송달되면 한국예탁결제원 또는 예탁자는 채무자의 계좌부에 그 취지를 기재하게 된다.

4. 압류의 효력

가. 압류의 효력이 미치는 범위

1) 먼저, 예탁증권등에 관하여 예탁자 또는 투자자가 가지는 공유지분은 당해 예탁증권등의 발행회사 및 그 종류·종목마다 1개의 권리로 해석되고 있으므로 압류명령에 있어서 목적물의 표시를 유가증권의 수량 등으로 그 범위를 한정하지 않는 한, 압류의 효력은 당해 종류·종목의 예탁증권등에 관하여 채무자가 가지는 공유지분의 전부에 미친다고 보아야 할 것이다.⁶⁶⁵⁾

여기에서 공유지분의 전부라 함은, 압류명령이 대체결제회사 또는 예탁자에게 송달된 시점에 있어서 채무자인 예탁자 또는 투자자가 당해 종류·종목의 예탁증권등에 관하여 가지는 공유지분의 전부라는 의미이고, 압류 후에 새로운 유가증권의 예탁 혹은 다른 계좌로부터의 대체에 의하여 채무자 계좌의 유가증권이 증가하였다고 하여도 그 압류 후의 증가분에 대하여는 압류의 효력이 미치지 않는다.⁶⁶⁶⁾

665) 홍광식(주572), 340.

666) 홍광식(주572), 340.

2) 동산인 주권에 대하여 압류가 된 경우에 있어서는 일반적으로 압류의 효력은 이익배당청구권에 미치지 않는 것으로 해석되고 있고, 예탁증권등 집행에 있어서도 예탁주권의 공유지분에 대한 압류의 효력은 실질주주명부상의 주주가 가지는 이익배당청구권에는 미치지 않는다고 해석된다.

3) 예탁증권등의 공유지분에 대하여 압류가 이루어진 경우 채무자인 예탁자 또는 투자자가 당해 공유지분의 대상인 전환주식에 관하여 전환권을 행사하는 것은 위 압류명령에 의하여 금지된다. 그러나 다른 한편, 채무자의 행위 이외의 사유에 의하여 압류의 대상인 예탁증권등의 권리의 내용에 변경이 생기는 경우, 예를 들어 압류의 대상인 예탁증권등의 주식에 관하여 유·무상증자,⁶⁶⁷⁾ 주식배당, 주식의 병합·분할, 회사의 합병에 의한 주식의 발행, 주주에게 인수권을 부여하는 주식의 발행(신주인수권증서가 발행된 경우를 제외하고) 등이 있는 경우에 있어서 그에 대해 압류의 효력이 미치는지 여부가 문제로 될 수 있다.

이에 관하여는 이론적으로 위 발행된 주식을 예탁증권등의 대체물 또는 증식물이라고 보아 당초 압류의 효력이 이에 대해 미친다고 보는 적극설과 이를 부정하는 소극설이 있을 수 있으나, 아직까지 우리 실무에서 이에 대한 구체적인 견해는 나타나지 않고 있다.⁶⁶⁸⁾

생각건대 우선 주식의 병합·분할, 회사의 합병에 의한 주식의 발행에 있어서는 이 경우 어느 것도 새로이 발행된 주식에 대한 예탁주권의 공유지분은 종전 압류의 목적물이 형태를 바꾼 것(대체물)이라고 볼 것이므로 종전 압류의 효력은 신주에 대한 예탁주권의 공유지분에 미친다고 볼 것이다. 다음으로 무상증자의 경우에 대하여도 반대설이 있을 수 있지만, 종전 압류의 효력은 신주에 대한 예탁주권의 공유지분에 미친다고

667) 무상증자로는, 준비금의 자본전입에 수반하는 신주발행 또는 권면액 초과부분에 대한 신주발행 등을 들 수 있다.

668) 일본에 있어서는 株券等の保管及び振替に關する法律(株券振替法이라 한다) 제19조가 예탁주권의 주식에 관하여 주식의 병합, 분할 혹은 전환, 회사의 합병에 의한 주식의 발행, 무상교부 또는 주주에 인수권을 주는 주식의 발행(신주인수권증서가 발행된 경우를 제외한다)이 있는 경우에는 그 새로이 발행된 주식에 관하여 당해주식이 발행되는 때에 株券振替法 제14조 제1항의 규정에 의하여 保管振替機關에 주권의 예탁이 된 것으로 간주한다는 취지를 규정하고 있는데, 이것은 위 발행된 주식이 예탁주권에 관한 주주의 공유지분과 실질적 동일성을 가지고 있으므로 주식수의 증감 또는 주식의 내용의 변경이 있는 경우, 그에 의하여 새로이 발행된 주권(종래의 예탁주권의 대체물 또는 증식물)을 保管振替制度에 끼워 넣은 것이고, 압류된 예탁주권의 주식에 관하여 압류 후에 이러한 사유가 생긴 경우에도 마찬가지로 압류의 효력은 종래의 예탁주권의 대체물 또는 증식물이므로 새로이 발행된 주식의 예탁주권에도 미침을 명백히 하는 취지이다[東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 441, 참조].

보고 싶다. 이에 반해 주식배당의 경우에는 주식배당의 본질을 상법상 어떻게 해석하는 가라는 점과 관련하여 종전 압류의 효력이 미치는가 어떤가에 대하여도 견해가 나뉘어 진다.⁶⁶⁹⁾ 또한 주주에게 신주인수권을 부여하는 주식발행의 경우에는 종전 압류의 효력은 신주에 대한 예탁주권의 공유지분에 대하여는 미치지 않는다고 볼 것이다.

나. 압류에 의해 금지되는 행위

1) 집행법원은 압류명령에 의하여, ① 채무자에 대하여 예탁증권등에 대한 계좌 대체청구 또는 자본시장법 제312조 제2항에 따르는 증권반환의 청구 그 밖의 처분을 금지하고, ② 채무자가 예탁자인 경우에는 한국예탁결제원에 대하여, 채무자가 투자자인 경우에는 예탁자에 대하여 예탁증권등의 계좌대체와 증권등의 반환을 금지하게 된다(민집규 제177조).

압류의 대상으로 된 예탁증권등에 대하여 대체 또는 주권등 유가증권의 반환이 되어버리면 강제집행은 그 목적물을 잃어버리기 때문에 압류명령으로 이러한 행위를 금지하는 것은 당연하다. 질권 설정을 위한 대체도 압류명령에 의해 금지되는 것은 말할 것도 없다.

2) 여기에서 말하는 「그 밖의 처분」이란 법률행위를 포함하고, 또한 압류의 목적에 반하는 채무자의 행위 일체를 금지하는 취지이다.

증권대체결제제도에 편입된 주권등 유가증권의 공유지분에 대하여 압류가 된 경우 채무자가 실질주주로서 위 주식에 대해 의결권(상법 제369조 제1항) 등 공익권을 행사하는 것은 방해되지 않지만, 압류된 주권등 예탁증권등에 관계된 단주(端株)에 대해 한국예탁결제원 또는 예탁자를 경유하여 발행회사에 대하여 매수청구를 하는 것 또는 압류된 예탁주권등 유가증권이 전환주식에 관계된 것인 경우에 한국예탁결제원에 전환권행사의 신청을 하여 전환권을 행사하는 것 등은 어느 것도 압류에 의해 금지되는 것이다.

3) 압류된 예탁증권등이 전환사채에 관계된 것인 경우에 채무자가 한국예탁결제원에 대하여 신청하여 전환권을 행사하는 것 및 압류된 예탁증권등이 신주인수권증서, 신주인수권증권 또는 신주인수권부사채에 관계된 것인 경우에 채무자가 한국예탁결제원에 대하여 신청하여 신주인수권을 행사하는 것 등도 압류에 의해 금지되는 행

669) 주식배당의 성질을 이익배당의 일종으로 보는 견해(이익배당설)에 의하면 종전 압류의 효력이 미치지 않을 것이지만, 그 성질을 주식분할로 보는 견해(주식분할설)에 따르면 종전 압류의 효력이 이에 미치게 될 것이다.

위라고 할 것이다.

5. 현금화절차

가. 현금화절차의 개요

1) 현금화를 위한 명령

가) 법원은 압류채권자의 신청에 따라 압류된 예탁증권등지분에 관하여 법원이 정한 값으로 지급함에 갈음하여 압류채권자에게 양도하는 명령(다음부터 “예탁증권등지분 양도명령”이라 한다) 또는 추심에 갈음하여 법원이 정한 방법으로 매각하도록 집행관에게 명하는 명령(다음부터 “예탁증권등지분 매각명령”이라 한다)을 하거나 그 밖에 적당한 방법으로 현금화하도록 명할 수 있다(민집규 제179조 제1항).

이는 채권집행에 있어서 추심이 곤란한 채권의 현금화방법에 대하여 정한 민사집행법 제241조에 대응하는 것으로서, 대체결제제도에 의한 주권등 유가증권의 유통제도를 이용한 현금화가 가능하도록 규정을 마련한 것이다.

집행법원이 집행관에 대하여 예탁증권등을 추심에 갈음하여 매각하도록 하는 데에 있어서는, 예탁증권등이 계좌에 입금된 채로 매각을 명할 수도 있고, 아니면 주권등 유가증권의 반환을 받아 이를 매각하게 할 수도 있다고 본다. 그리고 「그 밖에 적당한 방법」으로는 예탁자에 대하여 예탁증권등지분의 매각을 명하는 방법을 생각해 볼 수 있다.

나) 위와 같은 현금화방법 중 어느 방법에 의할 것인가는 채권자의 신청에 따라 집행법원이 결정하게 된다(민집규 제179조 제1항). 다만 집행법원이 집행관에 대하여 예탁증권등을 추심에 갈음하여 매각하도록 하는 데에 있어서 예탁증권등이 계좌에 입금된 채로 매각을 명하는가 그렇지 않고 주권 등 유가증권의 반환을 받아 매각하게 명하는가는 압류채권자의 신청이 아니라 명령의 발령에 있어서 집행법원이 스스로의 판단에 따라 결정하는 것이고 이에 대한 채권자의 신청권은 없다고 볼 것이다.

다) 압류가 경합하고 있는 경우 경합하는 각 압류채권자는 각자 집행법원에 대하여 위 명령의 발령을 신청할 수 있다고 해야 한다.

2) 명령의 발령

가) 발령에 있어서 고려해야 할 사항

(1) 압류된 예탁증권등에 대하여 질권설정이 선행되어 있는 경우에는 위에서 본 바와 같이 질권자가 주권등 유가증권의 반환을 받거나 또는 유질계약을 실행하는 권

리는 강제집행에 의한 압류가 있어 방해받지 않는다고 해석되므로 집행법원은 질권 설정이 된 부분(질권 계좌에 기재되어 있는 부분)에 대하여는 압류를 함에 그치고 질권이 소멸하는 것을 기다려 강제집행절차를 진행시켜야 한다.

(2) 압류된 예탁증권등에 대하여 체납처분에 의한 압류가 선행하고 있는 경우에는 집행법원은 체납압류가 되어 있는 부분에 대하여 위 명령을 발할 수 없다고 보아야 할 것이다.

(3) 압류된 예탁증권등에 대하여 처분금지가처분이 선행되어 있는 경우에 집행법원이 가처분집행이 되어 있는 부분에 대하여 강제집행절차를 진행시킬 수 있는가 여편가에 대하여 견해가 나뉘어질 수 있다. 생각건대 집행법원은 선행가처분이 있으면 가처분이 집행된 부분에 대하여는 압류를 함에 그치고 가처분집행의 취하·취소를 기다려 강제집행절차를 진행시키는 것이 타당하다고 본다.

(4) 압류된 예탁증권등에 대하여 다른 채권자에 의한 압류가 선행하고 있는 경우에는 집행법원으로서 위 명령에 의한 현금화를 이종으로 하지 않도록 주의해야 한다. 압류된 예탁증권등에 대하여 다른 채권자에 의한 압류 또는 가압류의 집행이 선행하고 있는 경우에는 예탁증권등 양도명령을 발할 수 없으므로(민집규 제182조 제2항, 민집 제229조 제5항), 예탁증권등지분 매각명령에 의하여 현금화절차를 진행해야 한다.

(5) 집행법원은 압류된 예탁증권등 공유지분의 매득금에서 압류채권자에 우선하는 채권 및 절차비용을 변제하고 잉여가 생기는 경우가 아니라고 인정된 때는 예탁증권등지분 매각명령을 발해서는 안되고(민집규 제182조 제2항, 제165조 제1항), 예탁증권등지분 매각명령의 신청을 각하해야 한다.

(6) 집행법원은 예탁증권등지분 양도명령에 있어서 양도가액을 정하고, 예탁증권등지분 매각명령에 있어서 매각가액에 대한 지시(최저매각가액의 지정 등)를 행하지만, 민사집행규칙 제182조 제2항에 의해 준용되는 제163조, 제181조 제1항 각 규정의 취지에 비추어보면 예탁증권등지분 양도명령 발령일의 시장가격 이상의 가액에서 양도가액을 정하고, 예탁증권등지분 매각명령에 있어서 매각일의 시장가격 이상의 가액에서 매각할 것을 명하는 것이 상당하다.

나) 일부에 대한 현금화 명령

예탁증권등 집행에 있어서 압류목적물인 예탁증권등의 공유지분은 그(유가)증권·종류마다 1개의 권리라고 해석되므로 압류명령에 있어서 압류의 범위를 한정하지 않

는 한 압류의 효력은 채무자 계좌에 예탁된 당해(유가)증권·종류의 예탁증권등 공유지분 전부에 미치는 것으로 된다. 또한 압류명령에 있어서 압류의 범위를 한정하는 경우(일부 압류를 하는 경우)에도 주식등 가액 변동을 고려하여 압류범위를 결정하게 되므로 통상 청구채권액보다도 다액 범위의 공유지분을 압류하게 될 것이다.

위 현금화명령은 압류된 예탁증권등의 공유지분 일부를 대상으로 하여 발하는 것이 가능하다고 해석되는바, 부동산강제집행에 있어서 민사집행법 제124조의 취지에 비추어보면 예탁증권등 집행에 있어서도 압류되어 있는 공유지분 중 일부의 현금화에 의해 채권자의 채권 및 집행비용 전부를 만족시킬 수 있는 경우에는 압류되어 있는 예탁증권등 공유지분 중 일부를 대상으로 하여 현금화명령을 발해야 한다고 본다.

다) 채무자심문의 불요

예탁증권등 집행에 있어서 집행법원이 현금화명령을 발함에 있어서는 채무자를 심문할 필요가 없다(민집규 제182조 제1항, 민집 제226조).

예탁증권등 집행에 있어서 예탁증권등지분 양도명령 또는 예탁증권등지분 매각명령에 의한 현금화는 모두 예탁증권등의 권리에 맞는 통상의 현금화방법이고 현금화방법의 선택이 어떤가에 의해서 채무자에게 불이익이 생긴다고 보기 어려우므로 명령의 발령에 있어서 채무자의 심문이 필요하지 않는 것으로 되어 있는 것이다.

3) 불복신청

현금화명령의 신청을 기각 또는 각하하는 결정에 대하여는 위 신청을 한 압류채권자가, 현금화명령에 대하여는 채무자와 함께 제3채무자에 준하는 지위에 있는 한국예탁결제원 또는 예탁자가(예탁증권등지분 양도명령에 대하여는 경합하는 압류·가압류의 집행 또는 배당요구를 한 채권자도) 각 즉시항고를 할 수 있다(민집규 제179조 제2항).

위 현금화명령은 확정되지 않으면 효력이 생기지 않는 것으로 되어 있다(민집규 제179조 제3항).

4) 대체청구

예탁증권등지분 양도명령이 확정된 때에는 법원사무관등은 제1항의 예탁결제원 또는 예탁자에 대하여 양도명령의 대상인 예탁증권등지분에 관하여 압류채권자의 계좌로 계좌대체의 청구를 하여야 한다(민집규 제180조 제2항). 위 규정에 따른 계좌대체청구를 받은 예탁결제원 또는 예탁자는 그 취지에 따라 계좌대체를 하여야 한다(민집규 제180조 제3항).

채무자가 예탁자인 경우에 집행관은 제1항의 예탁증권등지분 매각명령을 받은 때에는 투자매매업자 등(채무자가 투자매매업자 등인 경우에는 그 채무자를 제외한 다른 투자매매업자 등)에 그 명의의 계좌를 개설하고, 예탁결제원에 대하여 압류된 예탁증권등지분에 관하여 그 계좌로 계좌대체의 청구를 하여야 한다(민집규 제181조 제2항). 위 규정에 따라 집행관으로부터 계좌대체청구를 받은 예탁결제원은 그 청구에 따라 집행관에게 계좌대체를 하여야 한다(민집규 제181조 제3항). 위 규정에 따른 매각위탁을 받은 투자매매업자 등은 위탁의 취지에 따라 그 예탁증권등지분을 매각한 뒤, 매각한 예탁증권등지분에 관하여는 매수인의 계좌로 계좌대체 또는 계좌대체의 청구를 하고 매각대금에서 조세, 그 밖의 공과금과 위탁수수료를 뺀 나머지를 집행관에게 교부하여야 한다(민집규 제181조 제4항). 집행관이 위 제1항 규정에 따른 매각위탁과 제2항의 규정에 따른 계좌대체청구를 하는 경우에는 예탁증권등지분 매각명령 등본과 그 확정증명을, 제2항의 규정에 따른 계좌대체청구를 하는 경우에는 그 명의의 계좌가 개설되어 있음을 증명하는 서면을 각기 붙여야 한다(민집규 제181조 제5항).

이는 예탁증권등 공유지분의 경우 계좌 대체가 행해지면 비로소 공유지분의 이전이 완료되므로 부동산집행에 있어서 법원사무관등에 의한 등기촉탁(민집 제144조), 채권집행에 있어서 매각명령시의 집행관에 의한 채권양도의 통지(민집 제241조 제5항) 등과 동일하게 집행기관으로서 권리이전을 위해서 필요한 행위를 해야 하는 것으로 규정한 것이다.

5) 매수인 등의 권리 취득

예탁증권등지분 양도명령이 확정되어 효력이 생긴 때는 압류채권자는 위 명령의 대상으로 되어 있는 공유지분에 대해 자기 계좌로의 대체를 받아, 예탁증권등지분 매각명령에 의한 매각이 행해진 때는 매수인은 당해 공유지분에 대해 자기 계좌로의 대체를 받거나 또는 주권 등의 반환을 받게 된다.

증권대체결제제도에 있어서 공유지분의 이전에 대하여는 계좌부의 기재가 효력발생요건이라 할 것이고(민집규 제180조 제2항, 상법 제336조 제1항 참조), 주권등 교부에 의한 주식 등의 이전에 대하여는 주권 등의 교부가 효력발생요건이므로(주권에 대해 상법 제336조 제1항, 신주인수권증서에 대해 제420조의3 제1항, 신주인수권증권에 대해 상법 제516조의6 제1항), 양도를 받은 압류채권자 또는 매수인은 자기의 계좌부에 대체의 기재가 된 때 또는 주권 등의 반환을 받은 때에 예탁증권등 공

유지분 또는 주권 등에 표창된 권리를 취득하게 된다.

주권 등 유가증권에 대하여는 선의취득(주권에 대해 상법 제359조, 신주인수권 증서에 대해 상법 제420조의3 제2항, 신주인수권증권에 대해 상법 제516조의6 제2항, 그 밖의 유가증권에 대해 상법 제65조, 민법 제514조)이 인정되어 있는바, 증권 대체결제제도에 있어서 대체에 의한 공유지분의 이전에 대하여도 동일하게 선의취득이 인정된다고 볼 것이다. 따라서 양도를 받은 압류채권자 또는 매수인이 자기의 계좌에의 대체를 받거나 또는 주권 등의 반환을 받은 때는 위 대체 또는 반환시에 악의 또는 중과실이 없는 한 당해 공유지분 또는 주권 등을 선의취득하게 된다.

6) 매각대금 등의 제출

예탁증권등지분 매각명령에 기초하여 매각의 절차를 종료한 때는 집행관은 신속하게 매각대금 및 매각에 관계된 조서를 집행법원에 제출해야 한다(민집규 제182조 제2항, 제165조제 4항).

나. 예탁증권등지분 양도명령

1) 예탁증권등지분 양도명령은 채권집행에 있어서 양도명령(민집 제241조 제1항 제1호)에 대응하는 것으로, 예탁증권등지분 양도명령이 확정되면 압류채권자의 청구채권 및 집행비용은 위 명령에 관계된 공유지분이 존재하는 한 집행법원이 정한 양도가액으로 변제된 것으로 간주된다(민집규 제182조 제2항, 민집 제231조).

2) 집행법원이 예탁증권등지분 양도명령의 발령의 가부를 판단하기 위하여는 선행처분의 유무를 알 필요가 있고, 또 예탁증권등지분 양도명령의 내용(명령의 대상이 된 공유지분의 범위, 양도가액)을 결정하기 위하여 압류의 대상인 예탁증권등의 종류, 수량적 내용을 알 필요가 있다. 이들 사정은 압류명령발령시에는 분명하지 않고, 대체결제회사 또는 예탁자로부터의 진술에 의하여 비로소 분명하게 되므로 집행법원은 위와 같은 진술에 의하여 선행처분의 유무 및 압류의 대상인 예탁증권등의 존부, 종류, 내용 등이 분명해진 후에 예탁증권등지분 양도명령을 발령해야 할 것이다.

3) 전술한 바와 같이 압류된 예탁증권등 공유지분 가운데 일부를 대상으로 하여 예탁증권등지분 양도명령을 발할 수 있고, 또 압류목적물인 예탁증권등에 대하여는 일정 단위(예컨대, 주식에 대하여는 1주 단위)로 분할하는 것이 가능하므로 집행법원은 압류채권자의 청구채권 및 집행비용에 대응하는 범위(주식수)의 공유지분을 대상으로 하여 예탁증권등지분 양도명령을 발할 수 있게 된다.⁶⁷⁰⁾

4) 예탁증권등지분 양도명령은 채무자 및 제3채무자에 준하는 지위인 한국예탁결

제원 또는 예탁자에게 송달된다(민집규 제182조 제1항, 민집 제227조 제2항).

채권집행에 있어서 전부명령 및 양도명령의 제3채무자의 송달이 확정일자 있는 증서에 의한 채권양도통지(민법 제450조 제2항)으로서 당해 채권의 압류채권자에 의 이전에 대한 대항요건으로서 역할을 겸하고 있는 것임에 대해, 증권대체결제제도에 있어서 공유지분의 이전은 계좌부의 대체기재가 효력발생요건이라 할 것이므로(민집규 제180조 제2항, 상법 제336조 제1항 참조), 예탁증권등지분 양도명령의 한국예탁결제원 또는 예탁자에 대한 송달에는 당해 공유지분의 압류채권자에서의 이전에 대한 대항요건으로서의 의미는 없고 단지 예탁증권등지분 양도명령을 신청한 압류채권자와 다른 채권자와의 경합이 생길 수 있는 시적한계를 확정하는 의미를 가지는 것(민집규 제182조 제2항, 민집 제229조 제5항)에 불과하다고 볼 것이다.

5) 예탁증권등지분 양도명령이 한국예탁결제원 또는 예탁자에게 송달될 때까지 예탁증권등지분 양도명령의 대상으로 되어 있는 공유지분에 대하여 다른 채권자가 압류·가압류의 집행 또는 배당요구(교부청구도 동일)을 한 때는 예탁증권등지분 양도명령은 그 효력이 생기지 않는다(민집규 제182조 제2항, 민집 제229조 제5항). 채권집행에 있어서 전부명령, 양도명령 등과 동일한 취지이다.

예탁증권등지분 양도명령이 한국예탁결제원 또는 예탁자에게 송달될 때까지 위 명령의 대상으로 된 공유지분에 대하여 체납처분에 기한 압류가 된 때도 예탁증권등지분 양도명령은 효력이 생기지 않는다고 볼 것이다.

6) 예탁증권등지분 양도명령이 확정되었다고 하여 위 명령이 당연히 효력이 발생하였다고 말하기는 어렵지만, 집행법원의 법원사무관등으로서의 예탁증권등지분 양도명령의 효력이 제대로 발생되어 있는지 어떤지를 알 수 없는 경우가 대부분이다. 따라서 법원사무관등으로서의 집행법원의 입장에서 볼 때 위 양도명령이 확정되었을 경우 예탁증권등지분 양도명령이 그 효력이 생겼는지 아니면 민사집행규칙 제182조 제2항, 민사집행법 제229조 제5항이 적용되어 효력이 생기지 않았는지 여부를 조사하지 않고서 한국예탁결제원 또는 예탁자에 대하여 대체청구를 하게 되며, 위 대체청구를 받은 한국예탁결제원 또는 예탁자는 예탁증권등지분 양도명령의 송달 전에 다른 채권자의 압류·가압류의 집행 또는 배당요구(교부청구)나 체납압류가 되어 있지 않은가를 조사하여 위 송달 전에 다른 채권자의 압류등이 되어 있지 않은 것을 확인한 후

670) 따라서 예탁증권등지분 양도명령에 대하여는 민사집행규칙 제182조 제2항, 제164조가 적용되지만, 실제로 명령의 발령에 있어서 이와 같이 일정단위를 기준으로 양도명령이 발하여진다면 압류채권자에게 차액을 납부시키는 사례는 많지 않을 것이다.

위 대체청구에 응해야 할 것이다(민집규 제180조 제2항, 제3항).

다. 예탁증권등지분 매각명령

1) 서

예탁증권등지분 매각명령은 집행관에 대하여 압류된 예탁증권등 공유지분의 매각을 명하는 것이다.

투자자가 채무자이고 예탁자가 투자매매업자 등인 경우에는 예탁자에 대한 예탁증권등지분 매각명령에 의해 현금화하는 것이 가장 합리적일 것이지만, 예탁자가 채무자인 경우에는 예탁자계좌부를 관리하는 한국예탁결제원에 대해 매각을 명하는 것은 한국예탁결제원이 행할 업무가 자본시장법상 한정되어 있어서 곤란한 점이 있고, 그렇다고 하여 채무자인 예탁자 자신에게 매각을 명하는 것도 적당하지 않다. 또한 투자자가 채무자라도 투자자계좌부를 관리하는 예탁자가 투자매매업자 등 이외의 자, 예컨대 은행과 같은 경우에는 자본시장법상의 문제도 있으며 또 한국거래소를 통한 매각도 실제상 가능하지 않으므로 이와 같은 예탁자에 대하여 매각을 명하는 것도 적절한 것은 아니다. 이러한 이유로 인하여, 집행관에 대하여 매각을 명하는 형태의 현금화가 필요하게 되는 것이다.

2) 채무자가 투자자인 경우

집행법원이 집행관에 대하여 예탁증권등지분 매각명령을 하는 경우에 채무자가 투자자인 때에는 채무자의 계좌를 관리하는 투자매매업자 등에 대하여 매각일의 시장 가격이나 그 밖의 적정한 가액으로 매각을 위탁할 것을 명하여야 한다(민집규 제181조 제1항).

위 규정에 따른 매각위탁을 받은 투자매매업자 등은 위탁의 취지에 따라 그 예탁증권등지분을 매각한 뒤, 매각한 예탁증권등지분에 관하여는 매수인의 계좌로 계좌대체 또는 계좌대체의 청구를 하고 매각대금에서 조세, 그 밖의 공과금과 위탁수수료를 뺀 나머지를 집행관에게 교부하여야 한다(민집규 제181조 제4항).

집행관이 제1항의 규정에 따른 매각위탁을 하는 경우에는 예탁증권등지분 매각명령등본과 그 확정증명을 붙여야 한다(민집규 제181조 제5항).

이 경우 집행법원이 명하는 매각명령의 주문례는 아래와 같다.

위 당사자간 ○○지방법원 2018타채○○호 예탁증권 압류명령에 의하여 압류된 별지⁶⁷¹⁾ 기재의 예탁증권을 매각할 것을 명한다.

집행관은 채무자의 계좌를 관리하는 투자매매업자에 대해 매각일의 시가나 그 밖의 적정한 가액으로 위 예탁증권을 매각할 것을 위탁하여야 한다.

3) 채무자가 예탁자(투자매매업자 등, 은행)인 경우

채무자가 예탁자인 경우 집행법원이 집행관에 대하여 예탁증권등지분 매각명령을 발할 때에는 집행관으로 하여금 당해 채무자(예탁자)를 제외한 다른 투자매매업자 등에 대하여 매각일의 시장가격이나 그 밖의 적정한 가액으로 당해 예탁증권등지분의 매각을 위탁할 것을 명하여야 한다(민집규 제181조 제1항).

위 명령을 받으면 집행관은 투자매매업자 등(채무자가 투자매매업자 등인 경우에는 그 채무자를 제외한 다른 투자매매업자 등)에 그 명의의 계좌를 개설하고, 예탁결제원에 대하여 압류된 예탁증권등지분에 관하여 그 계좌로 계좌대체의 청구를 하여야 하고(민집규 제181조 제2항), 집행관으로부터 계좌대체청구를 받은 예탁결제원은 그 청구에 따라 집행관에게 계좌대체를 하여야 한다(민집규 제181조 제3항).

위 매각위탁을 받은 증권회사는 위탁의 취지에 따라 당해 예탁증권등지분을 매각한 뒤 매각한 예탁증권등지분에 관하여는 매수인의 계좌로 계좌대체 또는 계좌대체의 청구를 하고, 매각대금에서 조세, 그 밖의 공과금과 위탁수수료를 뺀 나머지를 집행관에게 교부하여야 한다(민집규 제181조 제4항). 집행관이 위 각 규정에 따른 매각위탁과 계좌대체청구를 하는 경우에는 예탁증권등지분 매각명령등본과 그 확정증명을, 또 계좌대체청구를 하는 경우에는 그 명의의 계좌가 개설되어 있음을 증명하는 서면을 각기 붙여야 한다.

이 경우 위 매각명령의 주문례를 적어보면 다음과 같다.

위 당사자간 ○○지방법원 2018타채○○호 예탁증권 압류명령에 의하여 압류된 별지 기재의 예탁증권등 공유지분을 매각할 것을 명한다.

집행관은 채무자를 제외한 다른 투자매매업자에 대해 매각일의 시가나 그 밖의 적정한 가액으로 위 예탁증권등 공유지분을 매각할 것을 위탁하여야 한다.

671) 이 경우 별지 기재에는 예탁증권등 공유지분이 표시될 것이다.

6. 채권집행규정 등의 준용

가. 서

예탁증권등 집행에 관한 민사집행규칙의 규정은 집행의 개시(민집규 제176조), 압류명령(민집규 제177조) 및 현금화방법(민집규 제179조, 제180조, 제181조)에 대하여 특칙을 마련한 외에는 채권집행 및 그 밖의 재산권에 대한 집행의 규정을 준용하고 있다(민집규 제182조).

여기에서는 특히 설명을 요하는 점에 대하여 잠시 살펴보기로 한다.

나. 집행법원

집행법원에 대하여는 민사집행규칙 제182조 제1항이 민사집행법 제224조를 준용하고 있다.

따라서 1차적으로는 채무자의 보통재판적 소재지를 관할하는 지방법원이 관할 집행법원이 되고, 위 보통재판적이 없는 때에는 2차적으로 압류되는 예탁증권등 공유지분의 소재지를 관할하는 지방법원이 관할 집행법원으로 된다. 위 공유지분의 소재지는 민사집행법 제224조 제2항 본문이 준용되고 있는 것에 의하여 예탁자가 채무자인 경우는 한국예탁결제원의 보통재판적 소재지이고, 투자자가 채무자인 경우는 예탁자의 보통재판적 소재지가 될 것이다.

다. 한국예탁결제원·예탁자에 대한 진술 최고

압류채권자는 예탁결제원 또는 예탁자로 하여금 압류명령의 송달을 받은 날부터 1주 안에 서면으로 ① 압류명령에 표시된 계좌가 있는지 여부 ② 제1호의 계좌에 압류명령에 목적물로 표시된 예탁증권등지분이 있는지 여부 및 있다면 그 수량 ③ 위 예탁증권등지분에 관하여 압류채권자에 우선하는 권리를 가지는 사람이 있는 때에는 그 사람의 표시 및 그 권리의 종류와 우선하는 범위 ④ 위 예탁증권등지분에 관하여 다른 채권자로부터 압류·가압류 또는 가처분의 집행이 되어 있는지 여부 및 있다면 그 명령에 관한 사건의 표시·채권자의 표시·송달일과 그 집행의 범위 ⑤ 위 예탁증권등지분에 관하여 신탁재산인 뜻의 기재가 있는 때에는 그 사실 등을 진술하게 할 것을 법원에 신청할 수 있다(민집규 제178조).

집행법원은 제1항의 진술을 명하는 서면을 제3채무자에게 송달하여야 하고(민집규 제182조 제1항, 민집 제237조 제2항), 제3채무자가 진술을 게을리 한 때에는 법

원은 제3채무자에게 제1항의 사항을 심문할 수 있다(민집규 제182조 제1항, 민집 제237조 제3항).

한국예탁결제원 또는 예탁자가 위 신청에 따른 최고에 대하여 고의 또는 과실에 의해 진술을 하지 않은 때 또는 불실의 진술을 한 때는 이것에 의해 생긴 손해를 배상할 책임을 부담한다고 볼 것이다.

라. 집행법원에 의한 배당등의 실시

예탁증권등지분 매각명령에 기초하여 민사집행규칙 제181조 제1항에 따른 매각 위탁을 받은 투자매매업자 등은 위탁의 취지에 따라 그 예탁증권등지분을 매각한 뒤, 매각한 예탁증권등지분에 관하여는 매수인의 계좌로 계좌대체 또는 계좌대체의 청구를 하고 매각대금에서 조세, 그 밖의 공과금과 위탁수수료를 뺀 나머지를 집행관에게 교부하여야 하고(민집규 제181조 제4항), 집행관이 위와 같이 교부받은 현금화된 금전을 집행법원에 제출하면 배당절차가 진행되게 된다(민집규 제182조 제1항, 민집 제247조 제1항 제3호).

예탁증권등 공유지분 집행에 있어서 집행법원이 실시하는 배당등 절차는 채권집행 및 그 밖의 재산권에 대한 집행에 있어서 행하는 집행법원의 배당등 절차와 기본적으로 동일하다.

배당등을 받을 채권자의 범위는 집행관이 투자매매업자 등으로부터 매각대금의 교부를 받을 때까지 압류·가압류의 집행을 한 채권자 또는 위와 같이 집행관이 매각대금을 교부받은 후 집행법원에 그것을 제출할 때까지 배당요구(교부청구)를 한 채권자이다.

7. 보호예수된 유가증권에 대한 집행

가. 한국예탁결제원에 임치된 주권으로서 예탁된 것이 아니고 보호예수된 주권은 투자자가 자기 소유의 유가증권을 유통시키지 않고 안전하게 별도로 분리하여 보관하기 위하여 한국예탁결제원에 보관을 시킨 것을 말한다.

즉 보호예수제도는 보호예수의뢰인이 한국예탁결제원을 사금고처럼 사용하기 위한 것이고, 예탁자가 반환청구할 때 같은 종류, 같은 수량의 유가증권으로 반환하는 것이 아니라 보호예수된 것과 동일한 유가증권으로 반환하는 것일 뿐 아니라, 보호예수한 자만이 보호예수증서와 상환으로 반환을 청구하여 스스로 권리행사를 하여야 하므로 보호예수는 개별임치계약으로 보아야 한다.

따라서 보호예수된 주권은 일반 예탁증권등에 대한 집행방법에 따를 것이 아니고, 유체물인도청구권에 대한 집행방법인 민사집행법 제242조, 제243조에 따라야 하며, 이 경우 보호예수증서는 같은 법 제234조에 의하여 채무자로부터 수취하여야 한다.

나. 또한 채무자 소유의 주권이 발행회사를 통하여 보호예수된 경우 발행회사를 제3채무자로 하여(한국예탁결제원이 제3채무자가 되는 것이 아님을 주의) 채무자의 발행회사에 대한 주권교부청구권 또는 주권반환청구권을 압류하되 압류되는 주식의 표시를 보호예수된 주권이라고 적어서 특정하거나 또는 채무자의 발행회사에 대한 ‘보호예수주권 반환청구권’ 자체를 압류하고(다만 이는 압류명령에 있어서의 표현의 차이일 뿐 어느 방법에 의하든 이어지는 집행절차는 동일하다), 민사집행법 제243조에 의하여 집행관이 주권을 인도받은 후 유체동산으로 집행하거나 또는 위 반환청구권 자체를 특별현금화하면 될 것이다.

다. 채무자가 유가증권의 소유자 겸 발행회사로서 보호예수한 경우에는 한국예탁결제원을 제3채무자로 하여 채무자의 보호예수유가증권반환청구권을 압류·현금화할 수 있을 것이다.

X. 특허권 등에 대한 집행

1. 서설

특허권, 디자인권, 실용신안권, 상표권⁶⁷²⁾ 및 저작권 등 지적재산권은 독립한 재산권으로서 민사집행법 제251조에서 정한 그 밖의 재산권에 대한 집행의 대상이 된다.

그런데 특허권 등이 공유인 때에는 다른 공유자의 동의 없이는 양도할 수 없는 데(특허법 제99조 제2항, 디자인보호법 제96조 제2항, 실용신안법 제28조, 상표법 제54조 제5항), 이 경우에 공유지분이 집행의 대상으로 될 수 있는가가 문제로 된다. 이에 대해 특허법의 위 조항은 특허권 등 공유지분의 집행적격까지 부정하는 취지는 아니고 다만 현금화단계에서 공유자의 동의 없이는 현금화할 수 없다는 취지로 보는 견해도 있으나,⁶⁷³⁾ 판례는 ‘특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할

672) 별지서식 [3-20] 가압류로부터 본압류로 이전하는 상표권압류 및 현금화명령신청과 [3-22] 상표권압류명령신청 등 참조(제3장 말미 수록)

673) 東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 446.

수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 갖는 것이고,⁶⁷⁴⁾ 또한 특허법이 위와 같이 공유지분의 자유로운 양도 등을 금지하는 것은 다른 공유자의 이익을 보호하려는 데 그 목적이 있다'고 보아 각 공유자의 공유지분은 다른 공유자의 동의를 얻지 않는 한 압류의 대상이 될 수 없다는 입장이다.⁶⁷⁵⁾ 따라서 특허권 등에 대하여 압류를 신청하기 위해서는 공유자의 동의서(인감증명서 또는 본인서명사실확인서가 붙어 있어야 한다)를 함께 제출하여야 할 것이다.⁶⁷⁶⁾

특허권, 실용신안권, 디자인권 등에 대한 전용실시권 및 통상실시권은 사업과 함께 하는 경우 및 특허권자 등의 동의가 있는 경우에 한하여 이전할 수 있는바(특허법 제100조 제3항, 제102조 제5항, 디자인보호법 제97조 제3항, 제49조 제3항, 실용신안법 제28조, 다만 어느 것이나 재정에 의한 통상실시권을 제외한다), 실시하는 사업 자체를 집행의 대상으로 할 수는 없으므로(영업이 집행적격을 가지지 않는다는 것에 관하여는 집행의 대상을 살펴볼 때에 언급한 바 있다), 결국 그 전용실시권 및 통상실시권은 특허권자 등의 동의 또는 승낙이 있는 경우에만 집행의 대상으로 될 수 있다고 해석하여야 한다. 상표권의 전용사용권과 통상사용권도 위와 동일하다(상표법 제55조, 제57조).

특허권 등이 설정등록에 의하여 발생하는 권리임에 대하여, 저작권은 창작한 때부터 발생하며(저작권법 제10조 제2항), 등록은 다만 처분이나 처분제한을 위한 대항요건에 불과하므로(저작권법 제54조), 저작권이 등록되었느냐 여부는 집행상 문제가 되지 아니한다.

2. 압류절차

가. 신청

1) 특허권 등과 같은 지적재산권에 대한 압류명령의 신청은 일반의 채권압류에 준하여 이루어지므로 특허권 등의 집행에서는 채무자의 보통재판적이 있는 곳을 관할하는 지방법원(민집 제224조 제1항)이 제1차적 관할 집행법원이다.

674) 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결 참조

675) 대법원 2012. 4. 16.자 2011마2412 결정. 다만 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결은 특허권이 공유일 때 각 공유자에게 공유물분할청구권이 인정되고, 이때에는 현물분할이 아닌 경매에 의한 대금분할을 해야 한다고 판시하고 있다.

676) 이때 특허권 등의 공유자가 끝내 동의를 해주지 않을 경우 어떻게 할 것인가. 채권자로서는 민법의 채권자대위규정에 의하여 채무자를 대위하여 다른 공유자를 상대로 공유에 관계된 특허권의 분할을 소구(訴求)하여 그에 따라 분할된 후 이를 집행할 수 있을 것이다.

다만 채무자의 보통재판적이 없는 때에는 압류할 채권이 있는 곳이라고 할 수 있는 그 등록 등을 하는 곳을 관할하는 지방법원도 제2차적 관할 집행법원이 된다(민집규 제175조 제2항, 민집 제251조 제1항, 제224조 제2항). 즉 권리의 이전에 등기 또는 등록을 요하는 그 밖의 재산권에 대한 집행의 관할은 등기·등록을 하는 곳을 관할하는 지방법원으로 한다는 규정(민집규 제175조 제2항)은 제2차적 관할에 관한 보충규정인 것이다.

2) 압류명령의 신청서에는 채권집행의 예에 따라 채권자·채무자와 그 대리인의 표시, 집행권원의 표시, 강제집행의 목적으로 하는 재산의 표시 및 구하는 강제집행의 방법을 적는다.

3) 또한 특허권, 실용신안권, 디자인권의 실시권, 상표권의 사용권 및 출판권 등과 같이 제3채무자가 있는 것에 대한 압류명령의 신청에는 제3채무자도 표시한다(민집규 제159조 제1항).

강제집행의 목적으로 하는 재산의 표시는 특허권 등의 경우에는 등록번호 외에 출원인, 공고일, 등록일, 명칭(특허권·실용신안권의 경우에는 발명·고안에 관한 사항, 디자인권·상표권의 경우에는 그 명칭, 실시권 또는 사용권에서는 나아가 그 범위), 권리자의 이름과 주소를 표시하는 등 등록원부의 등록사항란에 적혀 있는 사항을 가지고 특정하고, 저작권 등의 경우에는 명칭(제호, 그것이 없거나 불명한 때에는 그 취지), 저작권자 등의 이름 또는 명칭(사망한 때에는 그 취지 및 날짜), 창작날짜, 저작물의 처음 발행 또는 공연날짜, 저작물의 종류, 내용(거래대상으로서의 내용은 복제권, 2차적 저작물의 이용에 관한 권리로 되어 있다) 또는 형태, 등록되어 있는 때에는 등록번호 및 등록일 등으로 특정한다.

또한 특허권 등은 그 권리 이전에 등록이 필요하므로 그 신청서에는 집행력 있는 정본 외에 권리에 관한 등록원부의 등본이나 초본을 붙여야 한다(민집규 제175조 제1항).

나. 압류명령

1) 내용

가) 압류명령에는 권리의 압류와 동시에 채무자에 대하여 압류된 권리에 관한 이전 등의 일체의 처분을 금지한다.

특허권, 실용신안권 및 디자인권의 실시권, 상표권의 사용권 및 출판권 등 제3채무자가 있는 것에 대한 압류명령에는 제3채무자에 대하여 채무자가 하는 권리처분에 대하여 승낙 그 밖의 협력을 금지한다.

압류명령의 주문례는 다음과 같다.

채무자가 가지는 별지 기재의 특허권을 압류한다.

채무자는 위 특허권에 관하여 매매, 양도 그 밖에 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.

나) 압류명령은 채무자(및 제3채무자 또는 이에 준하는 자가 있는 때에는 제3채무자)에게 송달하여야 한다(민집 제251조, 제227조 제2항). 소관관청에 송달할 필요는 없다.

다) 특허권 등의 처분제한은 특허청에 비치된 등록원부에 등록을 하여야 효력을 발생하므로(특허법 제101조, 실용신안법 제21조, 디자인보호법 제39조, 상표법 제56조, 제58조), 압류명령을 발령함과 동시에 법원사무관등은 직권으로 촉탁서에 재판의 등본을 첨부하여 당해 권리에 관한 등록 등의 사무를 취급하는 관서인 특허청장에게 압류등록을 촉탁하여야 한다(민집규 제175조 제5항, 민집 제94조, 특허권 등의 등록령 제17조).⁶⁷⁷⁾

저작권의 경우에는 처분제한등록은 효력발생의 요건이 아니고 대항요건에 불과하므로(저작권법 제54조), 문화체육관광부장관에 대한 압류등록의 촉탁은 법원사무관등이 직권에 의하여 할 필요는 없고 압류채권자의 신청이 있는 경우에 한하여 하면 될 것이다.

라) 그리고 등록권리자로는 압류채권자를, 등록의무자로는 채무자 즉 특허권자 등을 적는다. 특허청장 등은 압류기입등록을 한 후 그 등록원부 등본을 법원에 송부하여야 한다(민집규 제175조 제5항, 민집 제95조).

특허권 등에 대하여 압류의 효력발생 전에 담보권 설정의 등록이 되어 있는 때에는 법원사무관등은 담보권자에게 압류사실을 통지하고 그 담보권의 피담보채권의 현존액을 신고할 것을 최고하여야 한다(민집규 제175조 제4항).

2) 효력

제3채무자가 없는 재산권에 대한 압류명령은 채무자에게 송달되면 족하고, 그 송달시에 압류의 효력이 생긴다.

특허권 등은 제3채무자 없는 재산권에 해당한다. 특허를 받을 권리에 관하여는 특허청 내지 문화관광부가 제3채무자에 해당한다는 견해가 있어 보이나, 이것도 제3채무자 없는 재산권으로 보아야 할 것이다.⁶⁷⁸⁾ 특허권의 공유지분에 관하여는 다른 공유자가, 전용실시권 및 통상실시권에 대하여는 특허권자 등이 각각 제3채무자에 해당한다.

압류에 의하여 제한을 받는 것은 처분행위뿐이기 때문에 특허권 등이 압류된 후에도 채무자는 그 발명을 실시할 수 있다.⁶⁷⁹⁾ 그러나 압류가 된 뒤에는 전용실시권

677) 별지서식 [3-23] 특허권압류 등록촉탁서 참조(제3장 말미 수록)

678) 홍광식(주572), 329.

679) 安倉孝弘, “その他の財産權に對する執行”, 裁判實務大系 民事執行訴訟法, 440.

이나 통상실시권을 타인에게 설정 또는 허락할 수는 없다. 특허권 등의 소멸 그 밖의 사정으로 권리의 이전이 불가능하게 된 때에는 법원은 집행절차를 취소하여야 한다(민집규 제175조 제5항, 민집 제96조). 이 경우에 법원사무관등은 특허청장 등에게 압류기입등록의 말소를 촉탁하여야 한다(민집규 제175조 제5항, 민집 제141조).

3. 현금화절차

가. 특허권 등의 지적재산권은 부동산과 같은 유통성이 없으므로 현금화에 있어서 다양하고 유연한 방법이 인정되어야 하나, 채권집행의 경우와 달리 추심이나 전부와 같은 방법은 취할 수 없기에 채권자는 민사집행법 제251조에 의한 특별현금화로써 매각하거나(매각명령) 또는 채권자에게 양도하거나(양도명령), 아니면 관리인을 선임하여 관리를 명하는 명령을 신청할 수 있다. 다만 관리명령의 경우에는 관리인의 선임이나 관리방법 등에 대하여 해결할 점이 아직 많아 거의 이용되고 있지 않다.

나. 또한 출원 전의 특허를 받을 권리 및 노우하우(know-how)는 그 내용이 공개되면 전적으로 가치를 상실하는 성질을 가지는 것이므로 그 현금화방법으로서는 권리내용의 공개를 피하는 것을 불가결의 조건으로 한다.

여러 가지 현금화방법 중 이러한 조건을 충족하는 것은 집행법원이 정한 가액으로 채권자 또는 제3채무자에의 양도를 명하는 방법이 가장 적당할 것이다.⁶⁸⁰⁾

다. 저작재산권과 저작권접권은 그 전부 또는 이를 구성하는 개개의 권리를 분리하여 양도하거나(저작권법 제45조, 제88조) 또는 설정적 양도에 해당하는 이용허락을 하는 등(저작권법 제46조, 제88조)의 현금화처분을 할 수 있다.

그러나 저작권접권은 저작자의 일신에 전속하는 것이므로(저작권법 제14조 제1항), 집행의 대상이 되지 아니한다.

라. 양도명령 등에 의한 양도나 매각절차가 종료한 때에는 법원사무관등은 특허청장등에게 권리의 이전등록과 압류기입등록 및 소멸할 부담의 말소등록을 촉탁하여야 한다(민집규 제175조 제5항, 민집 제144조).

4. 특허출원권 등에 대한 집행

가. 특허출원권의 경우

1) 특허법상 특허를 받을 수 있는 권리(이른바 특허출원권)이 강제집행의 대상으

680) 東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 445.

로 될 수 있는가에 대하여는, ① 특허를 받을 권리가 양도가능한 재산적 권리라는 점, 이 권리에 대한 강제집행을 금지하는 취지의 규정이 관계법령상 보이지 않는다는 점 등을 들어 긍정하는 견해와 ② 강제집행에 의하여 발명이 공개되고 특허를 받을 권리로서의 가치가 상실된다는 점, 민사집행법 제195조 제12호에 「공표되지 아니한 저작 또는 발명에 관한 물건」이 압류금지물로서 규정되어 있는 취지 및 압류에 관한 공시방법이 없다는 점 등을 이유로 이를 부정하는 견해, 그리고 ③ 출원의 전후로 강제집행의 가부를 나누는 절충적 견해 등이 나타나고 있다.⁶⁸¹⁾

2) 새로운 기술적 아이디어를 법적으로 보호받는 방법으로서, 발명자(또는 발명자로부터 위 권리를 승계한 자)는 이를 영업비밀로서 보호받거나 또는 특허권으로 보호받는 방법 중 하나를 선택할 수 있다.

발명자는 발명의 완성에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득한다. 그런데 특허법에서 특허를 받을 수 있는 권리(특허출원권)는 발명의 완성으로부터 특허를 출원하여 특허를 부여받기 전까지 각각의 상태에 대응하여 변화하는 권리로서,⁶⁸²⁾ 그 각 단계에 따라 특허법이 규정하거나 그 해석상 인정되는 내용과 성격을 별개로 가지고 있다고 볼 수 있으므로 이를 하나의 권리로 보아 그 성격이나 내용을 논하는 것은 적절하지 않다.

또한 위 권리는 공권과 사권의 성격을 함께 가지고 있다는 것이 통설적 견해이다. 그리고 이 권리의 법적 성질·내용에 관하여 고전적인 논쟁이 있기는 한데, 어느 학설이나 이를 양도성 있는 재산적 권리라고 보는 점에서는 일치하고 있는 것 같다.

3) 발명자가 발명에 대하여 갖는 특허출원권 중 특허출원 전의 특허출원권은 영업비밀에 대한 권리와 유사한 측면을 가지고 있다. 반면 특허출원 후 특허출원자는 특허청장에 대하여 ① 특허출원의 심사를 요구할 권리 ② 특허법상의 특허요건을 충족한 것을 조건으로 특허사정을 받을 권리 ③ 특허사정 후 등록료의 납입 및 등록에 의하여 특허권을 창설 받을 권리 등을 갖게 되는데, 이들 권리는 단순한 「기대권」이라기 보다는 특허법상 특허청장에게 구체적인 행위를 요구할 수 있는 「청구권」의 성격을 가진다고 볼 수 있다.⁶⁸³⁾

특허출원 후 특허출원자가 가지는 발명 자체에 대한 권리도 그 시점에 따라 살펴볼 필요가 있다. 즉 출원 공개 전에는 당해 발명이 '영업비밀'로서의 성격을 완전히 잃는 것이 아

681) 이상 학설의 대립에 관한 논의는 홍광식(주572), 328, 참조

682) 특허 출원 전의 특허출원권, 특허 출원 후 출원 공개 전의 특허출원권 및 출원 공개 후의 특허출원권으로 구분 가능하다.

683) 이와 달리 특허출원 전의 경우 권리자는 특허청장에게 아무런 구체적인 행위를 요구할 권리를 갖지 못하고 단지 특허출원을 조건으로 하는 잠재적인 기대권을 갖는데 불과하다.

니므로 이에 관한 특허출원자의 권리는 노우하우(know how) 등 영업비밀에 대한 권리와 유사한 한편 특허권자는 앞서 본 특허청장에 대한(채권적) 권리도 함께 갖게 된다.

나아가 특허출원 후 발명이 공개된 후에는 특허출원자의 권리 성격이 상당히 달라지게 된다. 즉 이때에는 발명이 더 이상 비밀상태의 노우하우(know how)나 영업비밀이 아니므로 발명 자체에 대하여 특허출원자는 영업비밀로서의 법적 보호를 누릴 수 없다. 따라서 출원 공개 후에는 발명 자체에 대하여 지배권 유사의 재산권을 행사할 수 없고 단지 발명의 사용에 대하여 제3자로부터 금지를 당하지 않을 소극적 권능만을 갖게 되므로 특허출원 공개 후 특허등록 전까지는 현실적으로 앞서 본 특허청장에 대한 채권적 권리들만을 행사할 수 있을 뿐이다. 그런데 이러한 특허출원자의 단순한 기대권에 그치는 것이 아니라 특허청장에게 구체적 행위를 요구할 수 있는 재산적 가치 있는 청구권이고 공법상의 채권에 해당한다고 볼 수 있다.

순수한 공법상의 권능이나 기대권에 불과한 영업허가권 등은 집행의 대상이 되지 아니하고,⁶⁸⁴⁾ 건설업면허나 여객자동차운수사업면허권 등은 사업의 양도에 따라 이전되는 것이므로 그 면허만을 그 밖의 재산권으로서 집행의 대상으로 삼기 어렵다고 보아야 할 것이나,⁶⁸⁵⁾ 공법상 행정기관을 대상으로 하는 채권이라고 하더라도 독자적으로 양도 가능한 채권의 경우에는 압류할 수 있다고 보아야 한다. 즉 특허법 제37조는 특허출원권만의 양도를 명문으로 허용하고 있고, 같은 법 제38조 제4항은 특허출원 후의 특허출원권 양도의 효력발생요건으로 특허청장에 대한 신고를 규정하고 있는바, 이처럼 특허출원권은 그 자체의 양도성이 특허법에 의해 인정되고 있고 재산적 가치 있는 공법상의 채권임이 명백하므로 위 영업허가권, 건설업면허 등과는 그 법적 성격이 다르다고 보아야 한다.

또한 특허를 받을 수 있는 권리의 재산권으로서의 측면에 착안하여 채권자·채무자 사이의 이익형량이라는 실제적 견지에서 볼 때에도 긍정설이 타당하고, 특히 출원공고 후 이른바 가보호(假保護)의 권리는 특허권과 거의 같은 내용의 효력을 가지므로 부정설이 이에 대한 집행의 가능성까지 부정하는 취지이라면 이는 부당하다. 부정설의 최대의 논거라고 생각되는 강제집행에 의한 발명의 공개라는 문제는 출원 후의 권리에 관하여는 고려할 필요가 없는 것이고 출원 전의 권리에 관하여도 현금화방법의 단계에서 피할 수 없는 것도 아니다. 압류의 공시방법이 없다는 점은 물론 채권자의 집행절차상의 지위를 불안정하게 하는 것이지만, 그것을 이유로 이미 불이익을 알고서 하는 집행

684) 어업허가에 대하여 대법원 2010. 4. 29. 선고 2009다105734 판결 참조.

685) 대법원 1994. 12. 15.자 94마1802, 1803 결정; 대법원 1996. 9. 12.자 96마1088 결정; 대법원 2007. 12. 28. 선고 2005다38843 판결 등

의 신청까지 배척하는 것은 오히려 불합리하다고 할 것이다. 따라서 약간의 논의가능성은 있으나 이러한 점을 감안하면 일응 긍정설이 타당하다 할 것이다.⁶⁸⁶⁾ 687)

4) 따라서 특허출원권은 민사집행법상 그 밖의 재산으로서 채권집행의 예에 의하여 강제집행할 수 있다 할 것이다.⁶⁸⁸⁾ 집행법원은 경매에 대신하여 집행법원이 정한 가액으로 채권자에게 양도할 것을 명하거나 적당한 방법으로 현금화할 것을 명할 수 있고, 이 방법에 의하여 강제집행에 의한 공개라고 하는 상황을 피할 수 있을 것이다.

특히 출원 전의 특허출원권의 경우에는 위 방법 외에는 그 집행방법을 상정하기 어렵다. 실제로 집행을 하려면 대상의 특징이 필요한데, 출원 전의 특허출원권의 경우 노우하우(know how)와 같이 특징이 매우 어려울 수 있고, 공시수단도 없기 때문에 불안정을 피할 수 없다. 또한 압류만으로 채권자가 출원을 할 수 없음은 물론이고, 채권자에 대한 양도명령 후에야 채권자 명의로 출원할 수 있을 것이다.

이와 관련하여 출원 후의 특허출원권이 양도된 경우 이에 관한 특허법상의 규정이 없어서 앞서 본 출원 전의 특허출원권의 경우와 동일한 상황이 발생할 것으로 보이나, 출원 후의 특허출원권의 경우에는 이미 절차가 특허청에서 진행 중이므로 특허청이 이에 관한 공시규정을 마련하는 등의 조치를 강구할 필요가 있다.

그리고 특허권은 특허출원권이 변화된 결과물이라고 할 수 있으므로 특허출원권에 대한 압류 또는 가압류는 이 권리에 기초한 특허권에도 당연히 그 효력이 미친다고 해석하여야 할 것이다. 다만 이 경우 법상의 공시방법이 없는 것 때문에 특허등록 후 특허권자로부터 위 특허권을 양도받거나 그 밖에 담보권을 설정 받는 자는 불측의

686) 東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 449.

687) 특허출원권에 대하여 압류 또는 가압류를 하는 것이 허용되지 않는다면, 채권자에게는 피보전권리 보전의 방법으로 발명 그 자체에 대한 재산권을 압류하는 방법밖에 남지 않게 되는데, 출원 공개 후의 특허출원권은 사실상 특허청장에 대한 청구권으로서의 성격만 남을 뿐 발명 그 자체에 대한 지배권으로서의 성격이 미약하므로 설사 발명에 대한 압류 또는 가압류가 허용되더라도 권리보전의 의미가 희박하다. 앞서 본 바와 같이 특허법은 특허출원 전후를 불문하고 특허출원권만의 양도를 인정하고 있으므로 만일 채권자가 특허청장을 제3채무자로 하는 특허출원권의 압류가 불가능하여 발명에 대한 재산권의 압류 또는 가압류만을 한 후 채무자가 특허출원권을 제3자에게 양도해 버리면 제3자는 유효하게 특허출원권을 취득하고 결과적으로 특허권을 취득하는 것도 가능하게 되므로 위 압류 또는 가압류는 무용지물이 되어 버릴 것이다. 그리고 출원 공개 전에는 발명에 대한 재산권의 압류 또는 가압류가 노우하우(know how) 또는 영업비밀에 대한 압류의 성격을 가질 수 있으나, 출원 공개 후에는 당해 발명이 노우하우(know how) 또는 영업비밀의 성격을 거의 상실하기 때문에 이에 대한 압류 또는 가압류는 아무런 의미가 없게 되는 것이다.

688) 다만 이 경우 특허청장을 제3채무자로 하여 압류 또는 가압류신청을 할 수 있는지 여부가 문제될 수 있다. 즉 종래 재산권상의 청구의 경우에는 국가나 지방자치단체를 당사자로 보는 것이 일반적 견해이므로 가 경우도 대한민국이 제3채무자가 되어야 하고 특허청장은 제3채무자가 될 수 없다는 견해도 나올 수 있다는 것이다.

손해를 입을 가능성이 있으므로 이에 관하여는 향후 제도적으로 보완할 필요가 있다.

나. 노우하우(know how)에 대한 집행

이른바 노우하우(know how)에 대한 강제집행의 가부에 대하여도 출원 전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리와 같이 이를 긍정해야 할 것이나,⁶⁸⁹⁾ 이를 부정하는 견해도 있다.

XI. 기타 권리의 경우

1. 지상권·전세권·임차권 등 용익권, 리스이용권 등에 대한 집행

지상권, 전세권,⁶⁹⁰⁾ 임차권과 같이 부동산을 목적으로 하나 부동산 자체를 집행 대상으로 할 수 없는 것은 그 밖의 재산권에 대한 집행의 방법으로 집행하여야 한다.⁶⁹¹⁾

임차권은 임대인의 동의가 없으면 양도할 수 없으므로(민법 제629조), 압류신청 시에는 임대인의 동의서를 붙여야 한다. 임차권압류명령에 있어서는 임대인이 제3채무자가 된다. 대주(貸主)의 승낙이 있는 경우 사용차권(使用借權, 민법 제610조)의 집행도 마찬가지이다.

리스이용권도 독립한 재산권이나 목적물이 제3자의 사용수익을 위하여 양도가능한 때에만 압류할 수 있다.⁶⁹²⁾

채권자는 위와 같은 권리의 현금화를 위하여 양도명령, 매각명령이나 그 밖의 특별현금화를 신청할 수 있다. 위 권리 중 등기를 요하는 것에 대하여는 압류시점에 압류기입등기의 촉탁을 하고 현금화가 종료한 때에는 권리의 이전등기와 압류기입등기의 말소촉탁을 하여야 한다.

다만 전세권에 대하여 저당권 등의 담보권이 설정된 경우 그 전세권의 전세기간이 만료되지 않았다면 그 실행은 민사집행법 제264조 소정의 부동산경매절차에 따라야 하고(존속기간이 남아 있는 전세권 자체를 매각하는 것임), 전세권의 존속기간이 만료된 경우에는 민법 제370조, 제342조 및 민사집행법 제273조에 의하여 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 채권집행(추

689) 東京地裁債權執行等手續研究會(주115), 442.

690) 별지서식 [3-18] 담보권실행을 위한 전세권압류 및 양도명령신청 참조(제3장 말미 수록)

691) 일본 민사집행법 제43조 제2항은 등기된 지상권 및 영소작권(永小作權)과 이들 권리의 공유지 분은 부동산으로 본다고 규정하여 부동산집행방법에 의하도록 하고 있다.

692) Sten/Jonas, §857 Rdnr. 26, 30, 31, 33.

심명령 또는 전부명령)의 방법이나 제3자가 전세금반환채권에 대하여 실시한 강제집행 절차에서 배당요구를 하는 등의 방법으로 자신의 권리를 행사하여야 한다.⁶⁹³⁾

2. 각종 허가권, 면허권 등에 대한 집행

권리집행의 대상이 되는 것은 사법(私法)상의 권리에 한하고 공법상의 권능인 때⁶⁹⁴⁾에는 애초부터 집행의 대상이 되지 아니한다. 또 일반적으로 어느 사업을 경영할 권리와 같은 포괄적 재산은 강제집행의 목적으로서 적합하지 않으므로 위와 같은 권리 중 집행의 대상이 되는 것은 거의 없다.

그러나 권리의 설정·이전 등에 있어서 공법상의 규제를 받더라도 기본적으로 사법의 적용을 받는 재산권, 예컨대 공유수면의 점용 및 공작물설치허가로 인하여 생긴 권리의 이전은 이에 대한 관할관리청의 허가가 있기 전이라도 당사자간에는 약정에 따른 채권적인 권리의무가 발생한다.⁶⁹⁵⁾

각종의 사업면허, 영업허가에 대한 권리, 예컨대 자동차운송사업면허나 건설업면허,⁶⁹⁶⁾ 목욕탕영업허가 또는 주유소영업허가, 고압가스판매업허가 등 면허권 내지 허가권이 그 밖의 재산권집행의 대상이 되는지가 문제로 된다.

판례는, 자동차운수사업면허에 관하여, 자동차운수사업법의 관계 규정에 따르면 인가를 받아 자동차운수사업의 양도가 적법하게 이루어지면 그 면허는 당연히 양수인에게 이전되는 것일 뿐, 자동차운수사업을 떠난 면허 자체는 자동차운수사업을 합법적으로 영위할 수 있는 자격에 불과하므로 자동차운수사업자의 자동차운수사업면허는 법원이 강제집행의 방법으로 이를 압류하여 현금화하기에 적합하지 않다고 보았고,⁶⁹⁷⁾ 건설업면허에 관하여도, 건설업법 제6조, 제7조, 제9조, 제16조의2, 제13조, 제15조

693) 대법원 1995. 9. 18.자 95마684 결정【결정요지】전세권에 대하여 설정된 저당권은 민사소송법 제724조 소정의 부동산경매절차에 의하여 실행하는 것이나, 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권의 용익물권적 권능이 소멸하기 때문에 더 이상 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행할 수 없게 되고, 이러한 경우는 민법 제370조, 제342조 및 민사소송법 제733조에 의하여 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 추심명령 또는 전부명령을 받거나(이 경우 저당권의 존재를 증명하는 등기부등본을 집행법원에 제출하면 되고 별도의 채무명령이 필요한 것이 아니다), 제3자가 전세금반환채권에 대하여 실시한 강제집행절차에서 배당요구를 하는 등의 방법으로 자신의 권리를 행사할 수 있을 뿐이다.; 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006다29372, 29389 판결

694) 소송상의 권능, 신청권, 상소권 등이 이에 해당한다.

695) 대법원 1966. 5. 31. 선고 66다497 판결

696) 건설업을 양도하여 건설업면허를 이전하고자 하는 자는 양도인과 양수인이 공동으로 국토해양부장관에게 건설업 양도인가 신청을 하여야 한다(건설산업기본법 제17조 제1항).

697) 대법원 1996. 9. 12.자 96마1088 결정; 대법원 2007. 12. 28. 선고 2005다38843 판결

의 규정에 의하면 건설부장관의 인가를 받아 건설업의 양도가 적법하게 이루어지면 건설업면허는 당연히 양수인에게 이전되는 것일 뿐, 건설업을 떠난 건설업면허 자체는 건설업을 합법적으로 영위할 수 있는 자격에 불과한 것으로서 양도가 허용되지 아니하는 것이라 할 것이므로 결국 건설업자의 건설업면허는 법원이 강제집행의 방법으로 이를 압류하여 현금화하기에는 적합하지 아니하다고 판시⁶⁹⁸⁾하였다.^{699) 700) 701)}

식품위생법 제39조 제2항, 제29조 제2항 또는 공중위생관리법 제3조 제2항은 민사집행법에 따른 경매, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 환가나 국세징수법·관세법 또는 지방세기본법에 따른 압류재산의 매각 및 그 밖에 이에 준하는 절차에 따라 영업시설의 전부를 인수한 자로서 그 지정요건을 갖춘 자는 그 영업자의 지위를 승계한다고 규정하고 있으나,⁷⁰²⁾ 위 규정의 경우 영업 자체는 권리집행의 대상으로 할 수 없어서 영업허가권도 포함하지 않은 영업시설만을 대상으로 하는 동산강제집행에 있어서 매수인에게 바로 영업자의 지위승계를 인정할 수 있는지는 문제이며, 구체적으로 적용되는 경우를 상정하기도 어렵다.⁷⁰³⁾

재산권으로서 권리가 금전적 가치를 가지고 있더라도 그 성질상 타인에게 양도할 수 없는 경우에는 이전에 의하여 현금화할 수 없고 또 타인이 대신 행사할 수 없는 경우에도 집행에 의하여 추심하기 어렵기 때문에 압류할 수가 없다. 면허권·허가권 등의 권리가 비록 재산적 가치를 가지고 거래 현실에서 재산권으로서 취급되고 있다 하더라도 위 면허권 등에 대한 양도의 효력이 법적으로 보호되는가에 대하여는 명확하게

698) 대법원 1994. 12. 15.자 94마1802, 1803 결정

699) 日東京高決 昭和 47(1972). 4. 10.(判時 667, 33) 【결정요지】면허를 받은 부정기항공운송사업면허(不定期航空運送事業免許) 및 항공기사용사업의 영업권, 즉 양 사업을 경영하는 권리 자체의 압류를 구하는 경우 일반적으로 이러한 포괄적 재산은 강제집행의 목적에 적합하지 않고 영업권에 관하여 항공법 규정은 사업의 면허를 받은 자가 사업을 자기의 이름으로 타인에게 경영하게 할 수 없고 또 사업의 양도는 운수대신(運輸大臣)의 인가가 있는 때에 효력을 발생하는 취지를 정하고 있기 때문에 법원이 이를 현금화하기에는 적합하지 않는 권리로서 현금화나 이를 목적으로 하는 압류가 허용될 수 없다.

700) 다만 허가권 중에서도 대물적 허가의 효과는 물적 사정에 변경이 없는 한 이전성이 인정되는 것이니 당해 물건 또는 사업의 양도 등 이전에 따라 그 사업에 부수하여 허가받은 지위를 승계하는 불특정인에게도 미치며, 양도금지된 허가권 등의 양도를 목적으로 하는 계약의 사법적 효력도 그 양도가 금지되어야 하는 사정 등 그 법률관계의 성질에 비추어 개개의 경우에 따라 판단할 수 밖에 없으므로 허가권 등의 재산적 가치를 고려하여 강제집행의 길을 열어야 한다는 견해가 제시되고 있다(권오곤, “허가권의 양도를 목적으로 하는 계약”, 민사판례연구XI, 552-553, 참조).

701) 건설업법은 이후 건설산업기본법으로 바뀌었는데, 건설산업기본법은 건설업법과 달리 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토해양부장관에게 등록을 하여야 한다고 규정하고 있다(건설산업기본법 제9조 제1항).

702) 폐지된 공중위생법 제8조 제2항도 같은 취지의 규정을 두고 있었다.

703) 홍광식(주572), 325-326.

정리된 바 없다. 앞서 본 바와 같이 행정관청에 대한 공법상의 권리가 독자적으로 현금화에 적합하는 것인지에 관하여는 여전히 법률적으로 해결하기 어려운 문제이다.

3. 가등기상의 권리

가. 가등기는 원래 순위 확보에 그 목적이 있지만, 그 대상이 되는 물권변동청구권은 성질상 양도될 수 있는 재산권이고 가등기로 인하여 공시되어 공시방법까지 마련되어 있으므로 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 가등기상 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기 형식으로 경료할 수 있다.⁷⁰⁴⁾

나. 부동산등기청구권이 조건부·시기부(始期附) 기타 반대급부에 걸린 등의 이유로 등기의무의 조속한 실현이 곤란한 사정이 있는 때에는 그 청구권에 관하여 민사집행법 제241조를 유추하여 특별현금화방법을 취할 수 있다는 견해가 있는 반면, 부동산청구권에 대한 강제집행은 채무자의 제3채무자에 대한 부동산의 인도청구권 또는 소유권이전등기청구권을 압류하여 당해 부동산에 관하여 보관인에게 그 점유의 이전을 받고 혹은 채권자명의로 그 소유권이전등기를 받은 후에 채무자의 소유에 속하는 당해 부동산을 강제경매 또는 강제관리의 방법에 의하여 현금화하고 그 매각대금 또는 관리로 인한 수익금을 가지고 집행채권인 채권자의 금전채권의 변제를 받게 하는 방법으로 하는 것이므로 위 부동산청구권의 강제집행에 관하여는 위 제241조의 준용은 없는 것이라 할 것이어서 위 청구권 자체를 동조의 특별현금화방법에 의하여 현금화할 수 없다는 견해가 대립되어 있는 것으로 보인다.

그 가운데 후자의 견해에 의할 경우 위와 같이 가등기되어 있는 청구권은 시기부(始期附) 또는 정지조건부인 장래의 부동산소유권이전청구권으로서 유체동산이나 부동산이 아님은 물론 금전채권도 아니며 민사집행법 제244조에서 규정하는 조건 없는 현재의 부동산권리이전청구권에도 해당하지 않는다 할 것이므로 결국 본조에서 말하는 그 밖의 재산권에 해당한다고 보게 될 것이다.⁷⁰⁵⁾

704) 대법원 1998. 11. 19. 선고 98다24105 전원합의체 판결【판결요지】가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물권변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다고 보아야 한다.

705) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 690.; 강창웅, “부동산인도 및 권리이전청구에 대한 집행”, 강제집행 및 임의경매에 관한 제문제(上) 35집, 555-556.

다. 가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물권변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다.⁷⁰⁶⁾

따라서 가등기상의 권리로서 압류명령의 대상이 될 수 있는 것으로는 소유권이 전청구권가등기상의 소유권이전등기청구권, 조건부소유권이전가등기상의 조건부 소유권이전등기청구권 등이 있다.

라. 가등기상의 권리에 대한 집행의 관할도 제1차적으로는 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원이고, 등기를 하는 곳(민집규 제175조 제2항)은 제2차적 관할에 불과하다. 이 경우 제3채무자로서는 가등기의 본등기의무자를 적어야 할 것이다.

706) 대법원 1998. 11. 19. 선고 98다24105 전원합의체 판결【판결요지】가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물권변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다고 보아야 한다.

제8절 채권과 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행

I. 서

1. 채권을 목적으로 하는 담보권의 실행 또는 물상대위권의 행사 및 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권의 실행은 원칙적으로 이러한 권리에 대한 강제집행에 준하여 이루어진다.

여기서 채권이란 금전의 지급 또는 선박이나 동산의 인도를 목적으로 하는 채권을 말하고,⁷⁰⁷⁾ 그 밖의 재산권이란 부동산·선박·동산·채권 이외의 재산권을 말한다.

2. 채권 및 그 밖의 재산권에 담보권의 실행에 대하여는 종래 그 중 질권에 관해서만 실체법상의 채권추심권이 있고, 그 밖에는 절차상 채권 등 집행에 의한 배당 절차에서 우선권에 의하여 권리의 만족을 얻을 수 있었다. 담보권 중 우선특권의 실행에 관해서는 실체법적인 규정은 없고, 구 경매법에도 아무런 규정이 없었으나, 민사집행법은 개정 전의 민사소송법과 마찬가지로 민사집행법 제273조에서 실체법과 별도로 절차상 질권 및 우선특권, 물상대위권의 행사로서의 요건을 정하고 우선특권에 관해서도 그 우선변제권을 실현하기 위한 절차의 내용을 명확하게 하고 있다.

채권을 목적으로 하는 담보권으로서의 질권이 있고, 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권에는 특허권 등의 지적재산권 질권이 있다.

권리질권은 질권자가 질권의 목적이 된 채권 그 밖의 재산권을 직접 청구하거나(민법 제353조), 민사집행법이 정한 집행방법에 의하여 이를 행사할 수 있다(민법 제354조). 성질상 지명채권과 지시채권에 대한 질권의 경우에는 그 채권을 직접 청구할 수 있을 것이나,⁷⁰⁸⁾ 그 밖의 재산권, 예컨대 특허권 등이나 사원의 지분권 등을 목적으로 하는 질권의 경우는 그 재산권을 직접 청구할 수는 없으므로 강제집행의 방법에 의할 수밖에 없다.

707) 다만 동산집행의 대상인 어음·수표·화물상환증 등의 유가증권에 화체되어 있는 것을 제외한다.

708) 대법원 2005. 2. 25. 선고 2003다40668 판결【판결요지】질권의 목적이 된 채권이 금전채권인 때에는 질권자는 자기채권의 한도에서 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있고, 채권질권의 효력은 질권의 목적이 된 채권의 지연손해금 등과 같은 부대채권에도 미치므로 채권질권자는 질권의 목적이 된 채권과 그에 대한 지연손해금채권을 피담보채권의 범위에 속하는 자기채권액에 대한 부분에 한하여 직접 추심하여 자기채권의 변제에 충당할 수 있다.